



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº RJ2014/12838 (19957.000591/2015-39)

Data do julgamento: 25/06/2019

Diretor Relator: Henrique Balduino Machado Moreira

Acusados: Eike Fuhrken Batista

Luiz Eduardo Guimarães Carneiro

Reinaldo José Belotti Vargas

José Roberto Penna Chaves Faveret Cavalcanti

Roberto Bernardes Monteiro

Paulo de Tarso Martins Guimarães

Ementa: Omissão de informações relevantes para a compreensão da situação financeira e patrimonial da OGX Petróleo e Gás Participações S.A. por ex-administradores da companhia. Infração aos artigos 142, inciso III, 153, 176, c/c o 177, §3º, da Lei nº 6.404/76 e aos artigos 14, 26 e 29 da Instrução CVM nº 480/09. Multas e absolvições.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da CVM, com fundamento no art. 11 da Lei nº 6.385/76, decidiu:

1. Por maioria de votos:

1.1. Aplicar ao acusado **Eike Fuhrken Batista**, na qualidade de presidente do conselho de administração da OGX, a penalidade de **multa** pecuniária, no valor de **R\$ 350.000,00** (trezentos e cinquenta mil reais), por infração aos artigos 142, inciso III, e 153 da Lei nº 6.404/76, ao, tendo conhecimento das incertezas relacionadas à viabilidade econômica da exploração dos Campos de Tubarão Tigre, Gato e Areia, deixar de adotar as providências compatíveis com a relevância e natureza da matéria, de modo a assegurar que as demonstrações financeiras intermediárias evidenciassem tais informações relevantes para a compreensão da situação financeira e patrimonial da Companhia; e

1.2. Aplicar ao acusado **Luiz Eduardo Guimarães Carneiro**, na qualidade de diretor-presidente da OGX, a penalidade de **multa** pecuniária, no valor de **R\$400.000,00** (quatrocentos mil reais), por infração aos artigos 153, 176, c/c o 177, §3º, da Lei nº 6.404/76 e 14, 26 e 29 da Instrução CVM nº 480/09 ao, tendo conhecimento das incertezas relacionadas à viabilidade econômica da exploração dos Campos de Tubarão Tigre, Gato e Areia, fazer elaborar demonstrações financeiras de encerramento do exercício de 31.12.12 e demonstrações financeiras intermediárias relativas aos períodos encerrados em 30.09.12 e 31.03.13, omitindo tais informações relevantes para a compreensão da situação financeira e patrimonial da Companhia, em inobservância ao disposto no item 4.43 do Pronunciamento Técnico CPC 00(R1) e nos itens 125, 129 e 131 do Pronunciamento Técnico CPC 26(R1), aprovados, respectivamente, por meio das Deliberações CVM 675/11 e 676/11.

2. Por unanimidade de votos:

2.1. Aplicar ao acusado **Roberto Bernardes Monteiro**, na qualidade de diretor-financeiro da OGX, a penalidade de **multa** pecuniária, no valor de **R\$500.000,00** (quinhentos mil reais), por infração aos artigos 153, 176, c/c o 177, §3º, da Lei nº 6.404/76 e 14, 26 e 29 da Instrução CVM nº 480/09 ao, tendo conhecimento das incertezas relacionadas à viabilidade econômica da exploração dos Campos de Tubarão Tigre, Gato e Areia, fazer elaborar demonstrações

financeiras de encerramento do exercício de 31.12.2012 e demonstrações financeiras intermediárias relativas aos períodos encerrados em 30.09.2012 e 31.03.2013, omitindo tais informações relevantes para a compreensão da situação financeira e patrimonial da Companhia, em inobservância ao disposto no item 4.43 do Pronunciamento Técnico CPC 00 (R1) e nos itens 125, 129 e 131 do Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1), aprovados, respectivamente, por meio das Deliberações CVM 675/11 e 676/11;

2.2. **Absolver** os acusados **Reinaldo José Belotti Vargas e José Roberto Penna Chaves Faveret Cavalcanti** da acusação de violação aos artigos 153, 176, c/c o 177, § 3º, da Lei nº 6.404/76 e 14, 26 e 29 da Instrução CVM nº 480/09; e

2.3. Pela **extinção de punibilidade** para o acusado **Paulo de Tarso Martins Guimarães**, em **razão do seu falecimento** no curso do processo.

A Sessão de Julgamento do presente processo foi iniciada em 27 de maio de 2019, ocasião em que o Diretor Relator Henrique Machado, votou pela condenação de (i) **Eike Fuhrken Batista**, na qualidade de presidente do conselho de administração da OGX, à penalidade de **multa** pecuniária de **R\$ 350.000,00** (trezentos e cinquenta mil reais); (ii) **Luiz Eduardo Guimarães Carneiro**, na qualidade de diretor- presidente da OGX, à penalidade de **multa** pecuniária de **R\$400.000,00** (quatrocentos mil reais); (iii) aplicar ao acusado **Roberto Bernardes Monteiro**, na qualidade de diretor-financeiro da OGX, a penalidade de **multa** pecuniária de **R\$500.000,00** (quinhentos mil reais); (iv) **absolver** os acusados **Reinaldo José Belotti Vargas e José Roberto Penna Chaves Faveret Cavalcanti**; e (v) pela **extinção de punibilidade** para o acusado **Paulo de Tarso Martins Guimarães**, em **razão do seu falecimento** no curso do processo. Após a leitura do voto do Relator, o Presidente Marcelo Barbosa pediu vista dos autos, e suspendeu a sessão.

Estavam presentes os advogados Darwin Corrêa, representante do acusado Eike Fuhrken Batista e Renata Moritz Serpa Coelho, representante dos acusados José Roberto Penna Chaves Faveret, Luiz Eduardo Guimarães Carneiro, Reinaldo José Belotti Vargas e Roberto Bernardes Monteiro.

Presentes também os Diretores Henrique Balduino Machado Moreira, Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Flavia Martins Sant'Anna Perlingeiro e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a sessão, bem como a Procuradora Luciana Dayer, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Ausente o Diretor Gustavo Gonzalez.

Em 25 de junho de 2019, na continuação da Sessão de Julgamento, o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, em sua manifestação, votou (i) pela absolvição de Luiz Carneiro da acusação de infração aos arts.153 e 176 c/c 177, §3º, da Lei nº 6.404/76 e dos arts.14, 26 e 29 da Instrução CVM nº 480/09; e (ii) pela absolvição de Eike Batista da acusação de infração aos arts. 142, III, e 153 da Lei nº 6.404/76. Por fim, com relação aos demais acusados deste processo, acompanhou as conclusões do voto do Diretor Relator pela absolvição dos acusados Eike Batista e Luiz Eduardo Guimarães Carneiro, bem como na aplicação da penalidade de multa pecuniária no valor de R\$500.000,00 (quinhentos mil reais) ao acusado Roberto Bernardes Monteiro.

Os diretores Carlos Alberto Rebello, Gustavo Machado Gonzalez e Flávia Perlingeiro acompanharam o voto do Diretor Relator, Henrique Machado.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 34 c/c o art. 29, ambos da Lei nº 13.506/17, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 229 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsortes tiverem diferentes procuradores.

Presente na continuação da sessão de julgamento a advogada *Renata Moritz*, representante dos acusados José Roberto Penna Chaves Faveret, Luiz Eduardo Guimarães Carneiro, Reinaldo José Belotti Vargas e Roberto Bernardes Monteiro.

Participaram da continuação da sessão de julgamento os Diretores Henrique Balduino Machado Moreira, Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Gustavo Machado Gonzalez, Flavia Martins Sant'Anna Perlingeiro e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a sessão, bem como a Procuradora Luciana Dayer, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Machado Gonzalez, Diretor**, em 05/08/2019, às 13:25, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Flavia Martins Sant Anna Perlingeiro, Diretor**, em 05/08/2019, às 20:23, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Diretor**, em 07/08/2019, às 09:56, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Henrique Balduino Machado Moreira, Diretor**, em 08/08/2019, às 22:53, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Santos Barbosa, Presidente**, em 12/08/2019, às 17:24, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **0802016** e o código CRC **A133EDC0**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **0802016** and the "Código CRC" **A133EDC0**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2014/12838

Reg. Col. nº 9756/2015

Acusados:

Eike Fuhrken Batista
Luiz Eduardo Guimarães Carneiro
Reinaldo José Belotti Vargas
José Roberto Penna Chaves Faveret Cavalcanti
Roberto Bernardes Monteiro
Paulo de Tarso Martins Guimarães

Assunto:

Omissão de informações relevantes para compreensão da situação financeira e patrimonial da OGX Petróleo e Gás Participações S.A. (atual Dommo Energia S.A.) por ex-administradores. Infração aos artigos 142, inciso III, 153, 176 c/c 177, § 3º, da Lei nº 6.404/76² e artigos 14, 26 e 29 da Instrução CVM nº 480/09.

Diretor Relator:

Henrique Machado

RELATÓRIO

I. OBJETO E ORIGEM

1. Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de Relações com Empresas (“SEP” ou “Acusação”) em face de Eike Fuhrken Batista (“Eike Batista”), na qualidade de presidente do conselho de administração da OGX Petróleo e Gás Participações S.A.¹ (“OGX” ou “Companhia”), por infração ao art. 142, inciso III, e art. 153 da Lei nº 6.404/76², e dos diretores Luiz Eduardo Guimarães Carneiro (“Luiz Carneiro”), Reinaldo José Belotti Vargas (“Reinaldo Vargas”) e José Roberto Penna Chaves Faveret Cavalcanti (“José Cavalcanti”), Roberto Bernardes Monteiro (“Roberto Monteiro”) e Paulo de Tarso Martins Guimarães (“Paulo

¹ Para fins deste documento, utilizar-se-á o nome notoriamente conhecido à época dos fatos, conforme acima identificado, sendo válido esclarecer que em assembleia de acionistas realizada em 06.12.2013 a denominação social da sociedade foi alterada para Óleo e Gás Participações S.A., tendo sido incorporada à Dommo Energia S.A., conforme fato relevante divulgado em 26.11.2018.

² Art. 142. Compete ao conselho de administração:

III - fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos;

Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Guimarães” que, em conjunto com os demais, são aqui denominados “Acusados”), por infração aos arts. 153 e 176 c/c 177, §3º, da Lei nº 6.404/76³ e 14, 26 e 29 da Instrução CVM nº 480/094.

2. O presente processo originou-se do Processo CVM nº RJ2013/7750, instaurado com o objetivo de analisar as demonstrações financeiras da Companhia em virtude da redução de seu valor de mercado observada desde os últimos meses de 2012 e que se acentuou ao longo do primeiro semestre de 2013.

3. Além deste processo, outros dois foram instaurados pela SEP para analisar supostas irregularidades envolvendo o mesmo contexto fático, tendo sido reconhecida a conexão entre os três processos⁵: (a) PAS CVM nº RJ2014/0578, processo em que se apura eventual uso de informação privilegia por Eike Batista, bem como suposta manipulação de preços das ações de emissão da OGX e da OSX Brasil S.A. (“OSX”); e (b) PAS CVM nº RJ2015/1421, em que se apura responsabilidade de ex-membros do conselho de administração da OSX por não terem tomado as providências necessárias para que as demonstrações financeiras evidenciassem informações relevantes para a compreensão da situação financeira e patrimonial da companhia.

II. FATOS E ACUSAÇÃO

II.1 HISTÓRICO

4. Fundada em 2007, a OGX participou, no mesmo ano, da nona rodada de licitações da Agência Nacional de Petróleo (“ANP”), adquirindo, além de outros, o bloco BM-C-41, na Bacia de Campos, no qual situavam-se, na parcela sul, as acumulações (reservas de petróleo)

³ Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício:

I - balanço patrimonial;

II - demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados;

III - demonstração do resultado do exercício;

IV – demonstração dos fluxos de caixa; e

V – se companhia aberta, demonstração do valor adicionado.

Art. 177, §3º. As demonstrações financeiras das companhias abertas observarão, ainda, as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários e serão obrigatoriamente submetidas a auditoria por auditores independentes nela registrados.

⁴ Art. 14. O emissor deve divulgar informações verdadeiras, completas, consistentes e que não induzam o investidor a erro.

Art. 26. As demonstrações financeiras de emissores nacionais devem ser:

I – elaboradas de acordo com a Lei nº 6.404, de 1976 e as normas da CVM; e

II – auditadas por auditor independente registrado na CVM.

Art. 29. O formulário de informações trimestrais - ITR é documento eletrônico que deve ser:

I – preenchido com os dados das informações contábeis trimestrais elaboradas de acordo com as regras contábeis aplicáveis ao emissor, nos termos dos arts. 25 a 27 da presente Instrução; e

II – entregue pelo emissor no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contados da data de encerramento de cada trimestre.

⁵ Em reunião do Colegiado de 07.07.2015, o presente processo e o PAS CVM nº RJ2015/1421 foram distribuídos por conexão ao PAS CVM nº RJ2014/0578.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

inicialmente chamadas de *Pipeline*, *Fuji* e *Illimani*, que posteriormente resultaram nos campos de Tubarão Tigre, Tubarão Gato e Tubarão Areia (“Campos”).

5. Em 2008, a Companhia abriu seu capital por meio de uma oferta pública inicial de ações (“IPO”), captando cerca de R\$6,7 bilhões, tendo o prospecto da oferta indicado o seguinte:

“(…) Tendo por base as informações originadas do Estudo de Viabilidade elaborado pela DeGolyer & MacNaughton, a estimativa média é de que os nossos Recursos Potenciais Riscados Líquidos nos blocos da Bacia de Campos somem 2,562 bilhões de Barris de Óleo. (...) diante do atual cenário de preços do petróleo e tendo em vista as tecnologias modernas de produção, acreditamos que nossos prospectos exploratórios na região apresentam oportunidades bastante atraentes e de relativo baixo risco exploratório (...)”.

6. Entre 2009 e 2011, a OGX divulgou diversos fatos relevantes e comunicados ao mercado sobre o desenvolvimento das operações no referido bloco, sendo alguns deles para comunicar a descoberta de hidrocarbonetos em seus reservatórios⁶. Acerca da acumulação de *Pipeline*, a SEP indicou algumas divulgações das quais se destacam, para fins deste processo, as informações a seguir:

- a) em 16.12.2009, a Companhia informou a descoberta de óleo durante a perfuração do poço OGX-2, com volume de óleo recuperável estimado entre 400 a 500 milhões de barris (fls. 597);
- b) em 22.12.2009, a Companhia divulgou nova estimativa do volume de óleo recuperável do poço OGX-2 entre 1 e 2 bilhões de barris (fls. 601);
- c) em 13.05.2010, ao divulgar a conclusão da perfuração dos poços OGX-6 e OGX-8, a Companhia comunicou também que identificou a conectividade entre os poços OGX-2A e OGX-6 (*Pipeline* e *Etna*), tratando-se de uma mesma acumulação com volume total de óleo recuperável estimado de 1,4 a 2,6 bilhões de barris (fls. 613-614);
- d) em 15.07.2011, no que se refere ao poço OGX-39HP, *Pipeline* horizontal, a Companhia divulgou (i) a conclusão da perfuração; (ii) o resultado indicando capacidade de produção de 10.000 barris por dia de óleo e (iii) identificação de boas condições de reservatório (fls. 641).

7. Em relação às acumulações *Fuji* e *Illimani*, destaca-se o seguinte:

- a) em 24.03.2010 e 31.03.2010, foram divulgadas detecções de hidrocarbonetos durante a perfuração do poço OGX-8 cuja acumulação foi denominada *Fuji* (fls. 611-612);

⁶ Os fatos relevantes publicados nesse período estão às fls. 596-604v, 611-618, 633-641.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

- b) em 13.05.2010, foi divulgada a (i) conclusão da perfuração do poço OGX-8 e (ii) a necessidade de novos dados para verificar se estavam “*diante de uma mesma acumulação*” referente à conectividade entre os poços OGX-3 e OGX-8 (fls. 613);
- c) em 24.01.2011, foi divulgada a presença de hidrocarbonetos na perfuração do poço 1-OGX-28D-RJS, cuja acumulação foi denominada *Illimani* (fls. 615).

8. Dentre as informações publicadas, vale destacar que em 13.03.2013 a OGX divulgou fato relevante no qual informou que submeteu à ANP a declaração de comercialidade das acumulações *Pipeline*, *Fuji* e *Illimani* da Bacia de Campos, tendo fornecido os seguintes dados referentes ao total estimado do volume *in situ*⁷ dos Campos (fls. 291):

Volume <i>in situ</i> estimado (mmboe ⁸) ⁹			
	P90	P50	P10
Tubarão Tigre	314	461	675
Tubarão Gato	50	71	101
Tubarão Areia	157	291	563
Total	521	823	1339

9. Em 01.07.2013, a OGX divulgou fato relevante comunicando ao mercado que “*a Companhia concluiu que não existe, no momento, tecnologia capaz de tornar economicamente viável o desenvolvimento dos campos de Tubarão Tigre, Tubarão Gato e Tubarão Areia*”, tendo advertido que as projeções anteriormente divulgadas não deveriam ser consideradas válidas, inclusive as que diziam respeito a metas de produção, fato que culminou em seu pedido de recuperação judicial, realizado em outubro de 2013 (fls.729-730).

10. No dia 03.07.2013, a Companhia publicou novo fato relevante, em aditamento ao divulgado dois dias antes, para, em cumprimento à determinação constante de ofício da GEA-4/SEP, apresentar maiores esclarecimentos com relação aos compromissos assumidos junto à OSX após a suspensão do desenvolvimento dos Campos (fls. 731-732).

II.2 ESTUDOS DE DESENVOLVIMENTO DOS CAMPOS

11. Em 24.07.2012, a Companhia contratou a Schlumberger Serviços de Petróleo Ltda. (“Schlumberger”) e, juntamente com profissionais das áreas de desenvolvimento da produção, de reservatório e de exploração da OGX, foi formado um grupo de trabalho (“Grupo de Trabalho” ou “GT”) com o objetivo de avaliar a viabilidade do desenvolvimento da produção das acumulações de *Pipeline*, *Fuji*, *Illimani*, além de *Osorno* (fls. 275-281).

⁷ “Volume estimado de petróleo existente no reservatório e expresso em condições ditas padrão, standard ou básicas” (fonte: <http://dicionariodopetroleo.com.br/dictionary/volume-de-oleo-in-situ/>, acesso em 15.02.2019).

⁸ Milhões de barris e óleo equivalente.

⁹ Os três cenários fazem referência aos percentuais de certeza quanto à produção.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

12. Foi obtida diretamente da Schlumberger uma minuta do estudo desenvolvido (denominado *Pipeline Task Force – Results*) e, segundo o sumário do documento, os estudos geológicos foram executados entre 24.07 e 21.09.2012. A Schlumberger informou, em resposta ao ofício enviado pela SEP¹⁰, que o “*documento se manteve em forma de minuta, não chegando a ser emitido um relatório final completo*” e foi entregue à OGX em 21.09.2012 (fls. 275-281).

13. Em 24.09.2012, o GT realizou uma apresentação à diretoria executiva da Companhia, da qual a SEP destacou as seguintes conclusões:

i) volume *in situ* de 676 milhões de barris de óleo equivalentes (boe) e de volume recuperável entre 49,5 milhões de boe (*cenário base*) e 77,7 milhões de boe (*cenário otimista*) para as acumulações¹¹; e

ii) para qualquer dos cenários traçados (base ou otimista), valor presente líquido (“VPL”) ¹² negativo.

14. Com relação a esse ponto, a Acusação lembrou que no Fato Relevante de 13.05.2010, a Companhia havia informado os seguintes volumes (fls. 613):

(...) a OGX estima um volume total de óleo recuperável para a acumulação formada entre os prospectos Pipeline e Etna (OGX-2A e OGX-6) de **1,4 a 2,6 bilhões de barris**. Já para a potencial estrutura formada entre os prospectos Waimea e Fuji (OGX-3 e OGX-8), estimamos um volume total de óleo recuperável de **600 a 1.100 milhões de barris** (...) (grifou-se)

15. Adicionalmente, a SEP ressaltou que chama a atenção que, considerando que os fatores de recuperação¹³ variavam de 0,3% a 16,1%, a Companhia tenha omitido as estimativas de volume recuperável¹⁴ no Fato Relevante divulgado em 13.03.2013, que informava acerca da declaração de comercialidade dos Campos.

16. Nesse tocante, a SEP sustenta que os dados do estudo confirmariam a inviabilidade econômica dos Campos sob quaisquer cenários, o que indicaria, no entender da Acusação, a necessidade de registrar a redução ao valor recuperável já no 3º ITR/2012, ou, no mínimo, a necessidade de divulgação, em notas explicativas, das incertezas relevantes quanto à viabilidade econômica da exploração dos Campos.

¹⁰ OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/nº 682/13.

¹¹ Esses valores consideram o prospecto de *Etna*.

¹² Método utilizado para determinar a viabilidade de um investimento em certo período de tempo.

¹³ “Razão entre o volume recuperável e o volume original de um fluido em um reservatório de hidrocarbonetos, ou seja, a fração ou o percentual do volume original que se espera produzir de um reservatório” (fonte: <http://dicionariodopetroleo.com.br/dictionary/fator-de-recuperacao/>, acesso em 20.02.2019).

¹⁴ Volume recuperável é a “[q]uantidade de óleo ou gás que se estima produzir de uma jazida de petróleo pelos métodos disponíveis” (fonte: <http://dicionariodopetroleo.com.br/dictionary/volume-recuperavel/>, acesso em 20.02.2019).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

17. Outro problema enfrentado pela OGX à época estaria relacionado ao desenvolvimento de uma unidade (WCPP) que tratasse do gás contaminante H₂S (sulfeto de hidrogênio) presente nos reservatórios, motivo pelo qual foi contratada a empresa Rameshini Associates Technology & Enginerring, LLC (“RATE”) para validação e detalhamento do projeto. Em fevereiro de 2013, a RATE concluiu que o projeto resultou em *“equipamentos de grandes dimensões e consequentemente elevados custos”*, sugerindo que *“fossem avaliadas outras tecnologias buscando a viabilidade do projeto”*, conforme correspondência enviada (fls. 307).

18. Na sequência das avaliações para concluir o conteúdo do fato relevante de 01.07.2013, a OGX afirmou que *“em março de 2013 foi entregue à Companhia o reprocessamento da sísmica dos reservatórios localizados nestes quatro campos [os três citados mais Tubarão Azul], feito pela empresa CGG Brasil, com dados mais precisos sobre as características da área, para permitir à OGX uma melhor avaliação do modelo geológico dos campos, tendo em vista os comportamentos distintos dos poços perfurados e concluídos para produção”* (fls. 113-119).

19. Em 28.06.2013, a gerência executiva de reservatórios e reservas, em conjunto com a gerência executiva de exploração da Companhia, apresentou ao conselho de administração um novo estudo, intitulado “Reavaliação dos Ativos da OGX na Bacia de Campos”, concluindo pela inviabilidade dos Campos. Os seguintes pontos do documento merecem destaque (fls. 292-306):

- (a) as primeiras análises da área de reservatórios, ainda em 2011, já sinalizavam volumes e compartimentação muito diferentes da interpretação inicial (fls. 300);
- (b) a Schlumberger teria confirmado o modelo da área de reservatórios indicando *“uma redução significativa do fator de recuperação, inicialmente estimado em torno de 20%, para algo inferior a 10%”*;
- (c) o estudo da Schlumberger teria estimado um volume recuperável de cerca de 80 milhões de barris no caso mais otimista, com um fator de recuperação de 12%, e de 50 milhões no caso mais provável, o que representa uma recuperação de 7,3%; e
- (d) o VPL do projeto seria de mais de um bilhão de dólares negativo.

II.3 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DIVULGADAS NO PERÍODO

20. No período compreendido entre **31.12.2007¹⁵ até 03.07.2013¹⁶**, a Companhia divulgou um conjunto considerável de informações relacionadas aos Campos, sendo relevante reproduzir duas tabelas elaboradas pela SEP com informações consolidadas constantes das notas explicativas de ‘Informações por Segmento’ [de negócios], item ‘Balanços por Segmento’ e ‘DRE por Segmento’, referentes aos exercícios de 2010 a 2013, incluindo ITRs do período (em R\$ mil):

¹⁵ 1ª DF após aquisição das concessões exploratórias em diversas bacias, na de Campos entre outras.

¹⁶ Data da divulgação complementar ao Fato Relevante de 01.07.2013, quando foi anunciado o *impairment* de alguns dos mais importantes Campos de exploração (fls. 569-751).

**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Bacia de Campos	30.06.2013	31.03.2013	31.12.2012	30.09.2012	31.12.2011	31.12.2010
Ativo circulante	73.413	-	123.867	101.589	70.674	-
Ativo ã circulante	-	-	181.953	179.171	83.342	19.338
Imobilizado	3.597.341	7.119.708	7.063.521	6.462.770	4.412.666	-
Intangível	537.081	707.338	819.611	822.105	826.105	2.798.435
Ativo Total	4.134.422	7.827.046	8.188.752	7.565.635	5.392.787	2.817.773
Passivo circulante	153.008	-	-	814.911	288.521	23.366
Passivo ã circulante	90.208	-	111.009	75.967	96.382	-
Passivo 3ºs Total	243.216	-	111.009	590.878	384.903	23.366

Saldos do Imobilizado e Intangível de 30.06.2013 estornando venda não efetivada de 40% de Tubarão Martelo.

Bacia de Campos	30.06.2013	31.03.2013	31.12.2012	30.09.2012	31.12.2011	31.12.2010
Receita Líquida	404.982	254.634	325.393	150.686	-	-
CPV	(302.522)	(171.056)	(254.833)	(136.427)	-	-
Lucro Bruto	102.460	83.578	70.560	14.259	-	-
Despesa Exploração	(969.362)	(486.915)	(208.359)	(114.416)	(87.783)	(16.958)

Na apresentação das informações por segmentos operacionais os principais itens alocados aos segmentos são: (a) recebíveis nas *joint-ventures*; (b) intangíveis; (c) imobilizado de E&P; (d) provisão para obrigação de abandono; (e) receita líquida de vendas; (f) custo dos produtos vendidos (leasing, O&M, logística, depreciação/amortização, royalties); (g) despesas de exploração (aquisição, processamento e interpretação de dados sísmicos, estudos geológicos/geofísicos e baixas de poços secos, áreas subcomerciais e custos afundados).

21. Com relação aos valores apresentados, a SEP ressaltou que a queda nos valores contabilizados nas rubricas de ativo imobilizado e intangível de 31.03 para 30.06.2013 reflete o registro da provisão para redução ao valor recuperável dos valores correspondentes aos campos de Tubarão Azul, Tubarão Tigre, Tubarão Gato e Tubarão Areia.

22. Por sua vez, os valores para as receitas líquidas divulgados em notas explicativas às demonstrações financeiras correspondem, para o Campo de Tubarão Azul, único a produzir entre aqueles que vieram a ser objeto de *impairment* (Tubarão Azul, Tubarão Tigre, Tubarão Gato e Tubarão Areia), a 2,39 milhões de barris em 2012, das quais somente 1,6 milhões transitaram pelas contas de resultado (fls. 717) e a 2,27 milhões de barris em 2013 (fls. 751).

II.4 MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DOS ACUSADOS

23. Considerando os fatos narrados, a SEP questionou os Acusados¹⁷ acerca dos motivos do não reconhecimento contábil da perda por redução ao valor recuperável dos ativos em questão quando da elaboração e divulgação das demonstrações financeiras referentes aos períodos encerrados em 30.09 e 31.12.2012 e 31.03.2013, fato que veio a ocorrer somente por ocasião da

¹⁷ Ofícios/CVM/SEP/GEA-5/nºs 46 a 51/2014 (fls. 316-329).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

divulgação do Formulário 2º ITR/13, três trimestres, portanto, após a tomada de conhecimento dos fatos supracitados (fls. 455-485).

24. Os Acusados afirmaram que o GT foi criado em julho de 2012 e teria tido como objetivo superar as divergências existentes entre as áreas de exploração e de reservatórios da OGX, sendo essa última conservadora em suas expectativas quanto aos volumes de óleo *in situ* e recuperável dos Campos. O intuito seria “*avaliar a oportunidade de desenvolvimento da produção das acumulações de Pipeline, Fuji, Illimani e Osorno*”, tendo sido coordenado pela OGX, com membros das áreas de desenvolvimento da produção, reservatório e exploração, além de técnicos especialistas em reservatórios carbonáticos (caso dos Campos sob análise) enviados pela Schlumberger.

25. Foi ressaltado que a Schlumberger não teria a tarefa de averiguar os volumes de óleo *in situ* e recuperável ou de realizar uma análise econômico-financeira dos Campos, e sim propor soluções capazes de maximizar a recuperação de óleo dessas acumulações, e seus técnicos teriam apenas dado suporte às avaliações, testes e simulações realizadas pela OGX naqueles reservatórios. Portanto, o GT não teria chegado a conclusões quanto aos volumes, e sim adotado como premissa o modelo elaborado pela área de reservatórios, que resultou em um volume *in situ* de 676 milhões de barris, dado que refletia a pior das hipóteses.

26. Com o término das primeiras análises, o GT apresentou os resultados em 24.09.2012, com base nos dados obtidos a partir dos poços com pior desempenho, com a ressalva de que seriam inconclusivos, sendo necessárias novas análises¹⁸. Afirmaram que “*se projeções não podem se basear, exclusivamente, no melhor dos resultados, de outro lado, também não é cientificamente aceitável que se descartem os bons resultados, adotando-se os piores deles*” e, por isso, a Companhia teria solicitado estudos adicionais (fls. 483).

27. Foi ressaltado que em março de 2013, vencida o período exploratório concedido pela ANP do bloco onde estavam os Campos, restando à Companhia a devolução ou a declaração de comercialidade, e a segunda opção teria sido escolhida de modo a conceder aos técnicos prazo adicional para obter e analisar novos dados. O período dos estudos teria transcorrido de 24.07.2012 a 21.06.2013 e, dessa forma, os Acusados afirmaram que não teria sido possível registrar as perdas por ajuste ao valor recuperável dos ativos nas demonstrações financeiras apontadas pela Acusação, pois naquele momento “*inexistia um conjunto de informações sólidas e reais apto a alterá-las*” (fls. 459).

¹⁸ De acordo com a resposta apresentada por Luiz Carneiro, tais medidas seriam: “(i) verificar o efeito da injeção de água na produção e recuperação final daqueles reservatórios, (ii) incorporar ao projeto sugestões dos especialistas da Schlumberger e os resultados da perfuração e produção a ser realizada no poço TBAZ-1 (Tubarão Azul), (iii) utilizar a modelagem de sistema de fraturas e dupla porosidade então eleita no campo de Tubarão Azul para que fosse ela devidamente validada com ajuste histórico de produção; e (iv) concluir a análise de viabilidade técnica da WCPP” (fls. 464).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

28. Nessa linha, também foi argumentado que embora as projeções fossem ruins, o reconhecimento contábil da perda do ativo dependeria da realização dos testes pedidos pelo GT, na forma como estabelece a seção 932 do US-GAAP¹⁹ de “*Extractive Activities – Oil and Gas*”, utilizado pela Companhia, uma vez que o *International Financial Reporting Standard* (“IFRS”) 6 estaria em revisão e o *framework* do IFRS indicaria que nesse caso fosse utilizada a norma mais avançada em vigor.

29. Adicionalmente, o acusado José Cavalcanti ressaltou que havia uma divergência interna tão grande que tornaria “*impossível qualquer pronunciamento da Companhia sobre esses ativos antes que houvesse uma uniformização interna de entendimento*” (fls. 473), que teria ocorrido no final do segundo semestre de 2013. Além disso, argumentou que a construção pela OSX do navio-plataforma OSX-2, que seria utilizado nos Campos, teria prosseguido de forma regular após setembro de 2012 e, portanto, caso houvesse certeza da inviabilidade econômica dos mesmos, a decisão lógica seria a interrupção da construção do FPSO de modo a preservar o caixa da Companhia.

30. Além disso, o referido acusado alegou que (i) o FPSO seria um equipamento customizado e, quão mais cedo se definisse onde seria empregado, menores seriam os custos de adaptação do projeto às novas condições da operação; e (ii) em 01.07.2013, data de divulgação da inviabilidade dos Campos, estaria em curso a negociação para a venda do Campo de Tubarão Martelo, que não foi concluída. Dessa forma, caso já existisse omissão em divulgar informações, não haveria motivo para divulgar tal fato na referida data, pois tal divulgação levaria a potencial compradora a desistir da aquisição.

31. Luiz Carneiro afirmou que somente com a perfuração e acompanhamento do comportamento da produção do poço TBAZ-1, o processamento, cruzamento e análise dos dados constantes de todos os estudos, testes e simulações, durante o primeiro semestre de 2013, que se teria concluído pela inexistência de tecnologia capaz de tornar economicamente viável a exploração dos Campos. Apesar da existência de óleo na região, a descontinuidade dos reservatórios teria tornado sua extração extremamente complexa, levando a inviabilidade econômica de sua exploração, ainda que a Companhia tenha tentado reduzir os custos do projeto inicial.

32. Eike Batista alegou, em particular, que (i) registrar uma perda nos ativos relacionados aos referidos campos, baseando-se no cenário pessimista do GT para depois, eventualmente, revertê-la ao constatar-se sua viabilidade comercial, desestabilizaria o mercado; e (ii) todas as divulgações realizadas pela Companhia acompanhariam longo texto com ressalvas diretas e expressas acerca dos riscos envolvidos na atividade petrolífera (fls. 455-461).

¹⁹ *Generally Accepted Accounting Principles (United States)*.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

II.5 CONCLUSÕES DA SEP

33. Pelo exposto, a SEP concluiu que, quando da divulgação do Formulário 3º ITR/2012 (em 08.11.2012), administradores da Companhia já possuíam elementos para que se tivesse reconhecida a perda do valor recuperável dos ativos ou, ao menos, para que se procedesse à divulgação, em notas explicativas, das incertezas relacionadas à viabilidade econômica da exploração dos Campos. Isso porque, no entender da Acusação, ao menos a partir da apresentação pelo GT ocorrida em 24.09.12, os administradores já dispunham de uma informação relevante, nos termos do art. 2º da Instrução CVM nº 358/02²⁰, dado o potencial de vir a definir as perspectivas da OGX em face das conclusões de tal relatório, ainda que se defenda que tais conclusões seriam preliminares.

34. A SEP ressaltou que, apesar da previsão constante dos arts. 157, §5º da Lei nº 6.404/76²¹ e 6º da Instrução CVM nº 358/02²², no sentido de que administrador poderá deixar de divulgar informação relevante caso entenda que sua revelação porá em risco o “*interesse legítimo da companhia*”; no que se refere às demonstrações financeiras, as normas contábeis aplicáveis, por outro lado, estabelecem que qualquer informação considerada relevante para a avaliação da posição patrimonial e financeira, do desempenho e das mutações na posição financeira da entidade deve ser divulgada.

35. Além disso, ao fazer tal divulgação, devem ser observados os princípios contidos nos artigos 14 a 19 da Instrução CVM nº 480/09, notadamente no que diz respeito à necessidade de divulgação de informações verdadeiras, completas, consistentes e que não induzam o investidor a erro.

36. Com relação aos procedimentos para a determinação do valor dos ativos, a Acusação pontuou que o Pronunciamento Técnico CPC 01 (R1) – Redução ao Valor Recuperável de Ativos (“CPC01(R1)”), em seu item 12, estabelece que a entidade deve “*avaliar se há alguma indicação de que um ativo possa ter sofrido desvalorização*”, devendo para isso considerar, no mínimo, indicações fornecidas por fontes externas ou internas e, dentre estas últimas, a alínea ‘g’:

²⁰ Art. 2º Considera-se relevante, para os efeitos desta Instrução, qualquer decisão de acionista controlador, deliberação da assembléia geral ou dos órgãos de administração da companhia aberta, ou qualquer outro ato ou fato de caráter político-administrativo, técnico, negocial ou econômico-financeiro ocorrido ou relacionado aos seus negócios que possa influir de modo ponderável: I - na cotação dos valores mobiliários de emissão da companhia aberta ou a eles referenciados; II - na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter aqueles valores mobiliários; III - na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titular de valores mobiliários emitidos pela companhia ou a eles referenciados.

²¹ Art. 157, § 5º. Os administradores poderão recusar-se a prestar a informação (§ 1º, alínea e), ou deixar de divulgá-la (§ 4º), se entenderem que sua revelação porá em risco interesse legítimo da companhia, cabendo à Comissão de Valores Mobiliários, a pedido dos administradores, de qualquer acionista, ou por iniciativa própria, decidir sobre a prestação de informação e responsabilizar os administradores, se for o caso.

²² Art. 6º. Ressalvado o disposto no parágrafo único, os atos ou fatos relevantes podem, excepcionalmente, deixar de ser divulgados se os acionistas controladores ou os administradores entenderem que sua revelação porá em risco interesse legítimo da companhia.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

“evidência disponível, proveniente de relatório interno, que indique que o desempenho econômico de um ativo é ou será pior que o esperado” (grifos no original).

37. A SEP reconheceu que, considerando a natureza dos ativos (de exploração e avaliação), os quais não geravam ainda fluxos de caixa, haveria certa dificuldade em determinar com precisão o volume de reservas recuperáveis e calcular valor justo ou em uso de modo a comparar com o valor contábil, ou seja, realizar o teste de recuperabilidade, conforme estabelece o CPC01(R1).

38. Alertou que o Pronunciamento do IASB, IFRS 6 – *Exploration for and Evaluation of Mineral Resources*²³, determina que a redução ao valor recuperável seja avaliada de acordo com as mudanças observadas nas circunstâncias, estabelecendo premissas para esse tipo de avaliação, tais como se há dados disponíveis suficientes para indicar que, embora o desenvolvimento da área provavelmente acontecerá, é improvável que o valor contábil seja recuperado por completo através da venda ou do desenvolvimento. Além disso, a SEP mencionou trechos de pronunciamentos contábeis²⁴ que determinam a divulgação de informação relevante em notas explicativas, ainda que a mesma não tenha atingido os critérios para o seu reconhecimento contábil.

²³ Norma ainda não traduzida pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis.

²⁴ CPC 00 – R1 (Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro):

“4.43. Um item que possui as características essenciais de elemento, mas não atende aos critérios para reconhecimento pode, contudo, requerer sua divulgação em notas explicativas, em material explicativo ou em quadros suplementares. Isso é apropriado quando a divulgação do item for considerada relevante para a avaliação da posição patrimonial e financeira, do desempenho e das mutações na posição financeira da entidade por parte dos usuários das demonstrações contábeis”.

CPC 26 – R1 (Apresentação das Demonstrações Contábeis):

“125. A entidade deve divulgar, nas notas explicativas, informação acerca dos pressupostos relativos ao futuro e outras fontes principais de incerteza nas estimativas ao término do período de reporte que possuam risco significativo de provocar ajuste material nos valores contábeis de ativos e passivos ao longo do próximo exercício social. Com respeito a esses ativos e passivos, as notas explicativas devem incluir detalhes elucidativos acerca:

(a) da sua natureza; e

(b) do seu valor contábil ao término do período de reporte”.

“129. As divulgações descritas no item 125 devem ser apresentadas de forma a ajudar os usuários das demonstrações contábeis a compreender os julgamentos que a administração fez acerca do futuro e sobre outras principais fontes de incerteza das estimativas. A natureza e a extensão da informação a ser divulgada variam de acordo com a natureza dos pressupostos e outras circunstâncias. Exemplos desses tipos de divulgação são os que seguem:

(a) a natureza dos pressupostos ou de outras incertezas nas estimativas;

(b);

(c) a solução esperada de incerteza e a variedade de desfechos razoavelmente possíveis ao longo do próximo exercício social em relação aos valores contábeis dos ativos e passivos impactados; e

(d)”.

“131. Por vezes, é impraticável divulgar a extensão dos possíveis efeitos de um pressuposto ou de outra fonte principal de incerteza das estimativas ao término do período de reporte. Nessas circunstâncias, a entidade deve divulgar que é razoavelmente possível, com base no conhecimento existente, que os valores dos respectivos ativos ou passivos ao longo do próximo exercício social tenham que sofrer ajustes materiais em função da observação de uma realidade distinta em relação àqueles pressupostos assumidos. Em todos os casos, a entidade deve divulgar a natureza e o valor contábil do ativo ou passivo específico (ou classe de ativos ou passivos) afetado por esses pressupostos”. (grifos no original)



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

39. Desse modo, a SEP avaliou que, por um lado, as normas que tratam de divulgação de informações relevantes facultam, em tese, aos administradores deixar de divulgar a informação caso entendam que *“sua revelação porá em risco interesse legítimo da companhia”* e, por outro lado, no momento de divulgação das demonstrações financeiras, as informações relevantes que sejam do conhecimento da administração, que possam ser identificadas como risco significativo de provocar ajuste material nos valores contábeis de ativos e passivos ao longo do exercício social seguinte, devem necessariamente ser contempladas nas notas explicativas.

40. Portanto, não caberia, quando da divulgação dessas demonstrações financeiras, a alegação da necessidade de sigilo até que confirmasse com absoluta certeza a total inviabilidade dos campos. No entender da Acusação, admitir essa alegação corresponderia a *“admitir a divulgação de demonstrações financeiras com informações sabidamente incompletas, com o potencial de induzir o investidor a erro e expressamente contrárias às normas contábeis mencionadas”*.

41. Quantos aos argumentos apresentados pelos Acusados em manifestação preliminar, a área técnica reforça que as alegações não alteraram suas conclusões, pois os elementos acostados aos autos indicariam haver incertezas relevantes quanto à viabilidade econômica dos campos em um momento bastante anterior à apresentação dos estudos do GT de 24.09.2012²⁵, sendo a própria constituição do GT, em julho de 2012, um forte indicativo dessas incertezas. Assim, afirma que *“não se pode desconsiderar que, em 24.09.2012, foram levadas formalmente ao conhecimento de administradores da Companhia informações cuja relevância, pela natureza e materialidade dos dados apontados, é inquestionável”*.

42. No entender da Acusação, as alegações de Eike Batista no sentido de que (i) registrar uma perda baseando-se no “cenário pessimista do GT” para depois, eventualmente, revertê-la ao constatar-se sua viabilidade comercial, “desestabilizaria o mercado”, e (ii) teria constado nos documentos da Companhia as devidas ressalvas acerca dos riscos envolvidos não são suficientes para eximir os administradores do dever de divulgação de informações relevantes, de forma completa e consistente, nas demonstrações financeiras.

43. Afirma que as principais informações que vinham sendo divulgadas ao mercado por administradores da Companhia, por meio de fato relevante, a respeito dos Campos, sem prejuízo do *disclaimer* padrão, eram, em regra, bastante positivas²⁶, o que demonstraria que *“as divulgações*

²⁵ A Acusação lembra que documento interno da Companhia de Junho/2013, na seção que trata dos campos TTGA, mencionou que desde “[a]s primeiras análises da Área de Reservatórios, ainda em 2011, já sinalizavam volumes e compartimentação muito diferentes da interpretação inicial”.

²⁶ A título exemplificativo, reproduzo algumas declarações citada pela SEP (i) no Fato Relevante de 15.04.2011, o presidente do Conselho de Administração e CEO, Eike Batista, bem como o então diretor geral e de exploração, P. M., demonstravam entusiasmo com as perspectivas da Companhia, o que se observa, por exemplo, com as seguintes declarações: “... vêm comprovar o extraordinário sucesso de nossa estratégia de atuação ...” e “... demonstrando capacidade técnica e gerencial para descobrir bilhões de barris em acumulações ...”; (ii) Fato Relevante de 09.02.2011, referente ao teste de formação em poço horizontal, OGX-26HP, confirma-se a vazão potencial de 40 mil barris por dia (§ 48 retro), tendo o Diretor Geral da Companhia declarado tratar-se *“de um dos melhores testes de produção que já vi em minha vida”*.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

positivas foram realizadas prontamente, após os primeiros indícios favoráveis à tese de que as áreas de concessão eram de grande potencial. As mesmas agilidade e presteza não foram observadas na divulgação das dificuldades e incertezas que surgiram ao longo do período mencionado”.

44. Além disso, o fato de a OSX ter dado prosseguimento à construção do FPSO OSX-2, em que pesem as incertezas relacionadas aos Campos para os quais essa plataforma estaria sendo desenvolvida, conforme alegado por José Cavalcanti, também não teria o condão de rebater as conclusões apresentadas, sendo tal fato merecer de apuração. O referido acusado apontou, ainda, que se a intenção fosse segurar a divulgação da informação, o momento propício para divulgá-la seria após a conclusão da participação no Campo de Tubarão Martelo²⁷, argumento que na visão da SEP considera que o comprador não teria opções disponíveis diante de tal situação e, ainda, que a omissão de informações seria uma estratégia válida para desenvolver negócios.

45. De modo a atestar a responsabilidade pela irregularidade verificada, com base no art. 176 que prevê que “*ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as (...) demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício*”, a SEP apurou que, à época dos fatos, a diretoria executiva da Companhia era composta pelos seguintes membros, que teriam tido acesso aos referidos relatórios (fls. 490-491):

Composição da Diretoria Executiva

Diretor	Cargo
Luiz Eduardo Guimarães Carneiro	Diretor Presidente
Reinaldo José Belotti Vargas	Diretor de Produção
José Roberto P. C. Faveret Cavalcanti	Diretor Jurídico
Roberto Bernardes Monteiro	Diretor Financeiro e DRI
Paulo de Tarso Martins Guimarães	Diretor de Exploração

46. Em seguida, a área técnica verificou que os referidos diretores teriam assinado as demonstrações financeiras referentes aos períodos findos em 30.09.2012, 31.12.2012 e 31.03.2013 e, além disso, teriam declarado que discutiram, reviram e concordaram com a opinião expressa dos auditores independentes e com as referidas demonstrações financeiras (fls. 775-780).

47. Relativamente a Eike Batista, o acusado seria o único administrador da OGX presente na reunião da diretoria executiva da OSX, realizada em 15.04.2013 para discutir uma atualização no plano de negócios daquela sociedade (fls. 760/7). Nessa reunião, teria sido definido um ajuste na “*tripulação do OSX-2 para condição de fundeio temporário na Ásia*” (fls. 762-v), plataforma

²⁷ Sobre esse ponto, a Acusação comenta que após divulgar o *impairment* dos campos em 01.07.13, teria circulado na imprensa que a potencial compradora valia-se desse fato para postergar a decisão, apresentando novas exigências de garantias à Companhia e o negócio não avançou (Fato Relevante de 18.11.13).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

essa que seria utilizada no desenvolvimento dos Campos, conforme o fato relevante de 01.07.2013, não tendo sido informada a razão aparente, naquele momento, para tal decisão.

48. Quando questionados, a OSX e o C.E.S.B. (presidente da OSX à época da citada reunião) esclareceram²⁸, em 23.10.2013, que *“todos os cerca de 60 empregos gerados visando o início de operação do FPSO OSX-2 permanecem preservados até o momento”*.

49. Esses fatos levaram a Acusação a concluir que, ao menos a partir de 15.04.2013, data da citada reunião, Eike Batista já possuiria a informação de que a plataforma OSX-2 poderia não ser utilizada nos Campos, considerando, inclusive, a inviabilidade econômica dos mesmos, indicada no relatório da Schlumberger de 21.09.2012, objeto de apresentação do GT de 24.09.2012.

50. Na visão da SEP, na condição de acionista controlador e presidente do conselho de administração e, até 27.04.2012, diretor presidente da Companhia, não seria razoável supor que Eike Batista não tivesse tomado conhecimento das incertezas existentes quanto ao potencial dos Campos e dos divergentes pontos de vista quanto ao referido potencial entre as áreas de exploração e de reservatórios da OGX.

51. Primeiramente porque em 2011, quando a área de reservatórios identificou que as análises *“já sinalizavam volumes e compartimentação muito diferentes da interpretação inicial ...”*²⁹ (fls. 521), Eike Batista ocupava o cargo de diretor presidente da Companhia, ou seja, as dificuldades enfrentadas pela OGX no planejamento do desenvolvimento dos Campos já teriam começado quando ainda exercia a presidência da Companhia.

52. Além disso, em sua manifestação preliminar, o acusado não declarou ter tomado conhecimento dos temas ali abordados somente por ocasião da RCA de 28.06.2013 (fls. 459), apenas afirmou ter solicitado o auxílio da Companhia para responder ao Ofício devido ao conteúdo técnico das questões (fls. 456), o que, por si só, não invalida a conclusão de que estivesse a par dos acontecimentos acima relatados, ocorridos durante o período compreendido entre julho de 2012 a fevereiro de 2013.

53. Dessa forma, dado que os referidos estudos versavam sobre um tema crucial para determinar a viabilidade econômica e financeira futura da Companhia e cujos primórdios remontavam ao período em que era o diretor presidente, não seria consistente, para a Acusação, a hipótese de que o acionista controlador e presidente do conselho de administração não tivesse sido mantido a par e/ou buscado manter-se informado, como era de seu dever legal e estatutário como conselheiro, a respeito dos resultados dos estudos, os quais se revelariam adversos quando da

²⁸ Em resposta aos OFÍCIOS/CVM/SEP/GEA-3/Nºs 679 e 680/13, enviados dia 07.10.2013 (ofícios às fls. 769-771 e respostas às fls. 772v-774v).

²⁹ A SEP ressalta que essas mesmas análises, bem como a divergência de opinião verificadas entre as Áreas supracitadas, vieram a contribuir para a decisão de constituição do GT, o que resultou nos estudos efetuados e coordenados pelo mesmo GT em conjunto com a Schlumberger e posteriormente com a RATE.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

apresentação efetuada pelo GT à Diretoria Executiva em 24.09.2012, condição adversa essa que teria sido reiterada quando da apresentação do estudo da RATE em fevereiro de 2013.

III. RESPONSABILIDADES

54. Diante dos fatos apresentados, e considerando o conjunto de informações constantes dos autos, a SEP propôs a responsabilização de:

- (a) Eike Batista, na qualidade de presidente do conselho de administração da OGX, por infração aos arts. 142, inciso III, e 153 da Lei nº 6.404/76, ao, tendo conhecimento, ao menos a partir de 15.04.2013, das incertezas relacionadas à viabilidade econômica da exploração dos Campos, deixar de adotar as providências compatíveis com a relevância e natureza da matéria, de modo a assegurar que as demonstrações financeiras intermediárias que serviram de base para o preenchimento do Formulário 1º ITR/2013 (divulgado em 09.05.2013) evidenciassem tais informações relevantes para a compreensão da situação financeira e patrimonial da Companhia, fato que caracterizou a inobservância ao disposto no item 4.43 do Pronunciamento Técnico CPC 00(R1) e nos itens 125, 129 e 131 do Pronunciamento Técnico CPC 26(R1), aprovados, respectivamente, por meio das Deliberações CVM 675/11 e 676/11;
- (b) Luiz Carneiro, na qualidade de diretor presidente da OGX, por infração aos arts. 153 e 176 c/c 177, § 3º, da Lei nº 6.404/76 e aos arts. 14, 26 e 29 da Instrução CVM nº 480/09 ao, tendo conhecimento das incertezas relacionadas à viabilidade econômica da exploração dos Campos, fazer elaborar demonstrações financeiras de encerramento do exercício de 31.12.2012 e demonstrações financeiras intermediárias relativas aos períodos encerrados em 30.09.2012 e 31.03.2013, omitindo tais informações relevantes para a compreensão da situação financeira e patrimonial da Companhia, em inobservância ao disposto no item 4.43 do Pronunciamento Técnico CPC 00(R1) e nos itens 125, 129 e 131 do Pronunciamento Técnico CPC 26(R1), aprovados, respectivamente, por meio das Deliberações CVM 675/11 e 676/11;
- (c) Reinaldo Vargas, na qualidade de diretor de produção da OGX, por infração aos arts. 153 e 176 c/c 177, § 3º, da Lei nº 6.404/76 e aos arts. 14, 26 e 29 da Instrução CVM nº 480/09 ao, tendo conhecimento das incertezas relacionadas à viabilidade econômica da exploração dos Campos, fazer elaborar demonstrações financeiras de encerramento do exercício de 31.12.2012 e demonstrações financeiras intermediárias relativas aos períodos encerrados em 30.09.2012 e 31.03.2013, omitindo tais informações relevantes para a compreensão da situação financeira e patrimonial da Companhia, em inobservância ao disposto no item 4.43 do Pronunciamento Técnico CPC 00(R1) e nos itens 125, 129 e 131 do Pronunciamento Técnico CPC 26(R1), aprovados, respectivamente, por meio das Deliberações CVM 675/11 e 676/11;



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

- (d) José Cavalcanti, na qualidade de diretor jurídico da OGX, por infração aos arts. 153 e 176 c/c 177, § 3º, da Lei nº 6.404/76 e aos arts. 14, 26 e 29 da Instrução CVM nº 480/09 ao, tendo conhecimento das incertezas relacionadas à viabilidade econômica da exploração dos Campos, fazer elaborar demonstrações financeiras de encerramento do exercício de 31.12.2012 e demonstrações financeiras intermediárias relativas aos períodos encerrados em 30.09.2012 e 31.03.2013, omitindo tais informações relevantes para a compreensão da situação financeira e patrimonial da Companhia, em inobservância ao disposto no item 4.43 do Pronunciamento Técnico CPC 00(R1) e nos itens 125, 129 e 131 do Pronunciamento Técnico CPC 26(R1), aprovados, respectivamente, por meio das Deliberações CVM 675/11 e 676/11;
- (e) Roberto Monteiro, na qualidade de diretor financeiro e de relações com investidores da OGX, por infração aos arts. 153 e 176 c/c 177, § 3º, da Lei nº 6.404/76 e aos arts. 14, 26 e 29 da Instrução CVM nº 480/09 ao, tendo conhecimento das incertezas relacionadas à viabilidade econômica da exploração dos Campos, fazer elaborar demonstrações financeiras de encerramento do exercício de 31.12.2012 e demonstrações financeiras intermediárias relativas aos períodos encerrados em 30.09.2012 e 31.03.2013, omitindo tais informações relevantes para a compreensão da situação financeira e patrimonial da Companhia, em inobservância ao disposto no item 4.43 do Pronunciamento Técnico CPC 00(R1) e nos itens 125, 129 e 131 do Pronunciamento Técnico CPC 26(R1), aprovados, respectivamente, por meio das Deliberações CVM 675/11 e 676/11; e
- (f) Paulo Guimarães, na qualidade de diretor de exploração da OGX, por infração aos arts. 153 e 176 c/c 177, § 3º, da Lei nº 6.404/76 e aos arts. 14, 26 e 29 da Instrução CVM nº 480/09 ao, tendo conhecimento das incertezas relacionadas à viabilidade econômica da exploração dos Campos de Tubarão Tigre, Gato e Areia, fazer elaborar demonstrações financeiras de encerramento do exercício de 31.12.2012 e demonstrações financeiras intermediárias relativas aos períodos encerrados em 30.09.2012 e 31.03.2013, omitindo tais informações relevantes para a compreensão da situação financeira e patrimonial da Companhia, em inobservância ao disposto no item 4.43 do Pronunciamento Técnico CPC 00(R1) e nos itens 125, 129 e 131 do Pronunciamento Técnico CPC 26(R1), aprovados, respectivamente, por meio das Deliberações CVM 675/11 e 676/11.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

IV. MANIFESTAÇÃO DA PFE

55. Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada (“PFE”)³⁰ entendeu estarem preenchidos os requisitos constantes dos art. 6º e art. 11, ambos da Deliberação CVM nº 538/08³¹.

V. DEFESAS

56. Devidamente intimados, Eike Batista e Roberto Monteiro apresentaram suas razões de defesa de forma individual (fls. 1.007-1.067 e 912-956, respectivamente), enquanto Luiz Carneiro, Reinaldo Vargas, José Cavalcanti e Paulo Guimarães apresentaram defesa conjunta (fls. 957-1.006).

57. Os Acusados reiteraram os argumentos apresentados nas manifestações preliminares, tendo ratificado a tese de que inexistiria, antes de 01.07.2013, informação dotada de certeza e credibilidade a ser divulgada ao mercado ou refletida nas demonstrações financeiras. Além disso, foram trazidas alegações comuns a todas as defesas, resumidas a seguir:

- (a) existiria legítimo interesse da Companhia a ser preservado enquanto tais estudos estavam sendo desenvolvidos, inexistindo, portanto, qualquer irregularidade na elaboração e divulgação das demonstrações contábeis da OGX referentes ao 3º ITR/12, ao exercício encerrado em 31.12.2012 e ao 1º ITR/13;
- (b) na administração anterior havia uma divergência entre duas áreas internas da OGX quanto às estimativas de volume de óleo recuperável nas acumulações dos Campos, e justamente por esse motivo teria sido proposta uma reestruturação no comando da Companhia;
- (c) no final do mês de junho de 2012, Luiz Carneiro assumiu o cargo de diretor presidente e solicitou ao novo gerente executivo de reservatórios uma avaliação criteriosa de alguns *assets* da Companhia, que teria gerado o relatório “valoração dos ativos bacias

³⁰ PARECER/Nº 324/2014/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU, de 08.11.14 (fls. 818-827).

³¹ Art. 6º. Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7º, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual deverão constar:

I – nome e qualificação dos acusados;

II – narrativa dos fatos investigados que demonstre a materialidade das infrações apuradas;

III – análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos acusados, fazendo-se remissão expressa às provas que demonstrem sua participação nas infrações apuradas;

IV – os dispositivos legais ou regulamentares infringidos; e

V – proposta de comunicação a que se refere o art. 10, se for o caso.

Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação, conforme o caso.

Parágrafo único. Considerar-se-á atendido o disposto no caput sempre que o acusado:

I – tenha prestado depoimento pessoal ou se manifestado voluntariamente acerca dos atos a ele imputados; ou

II – tenha sido intimado para prestar esclarecimentos sobre os atos a ele imputados, ainda que não o faça.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

de Campos e Parnaíba” (julho/12), o qual “*questionava alguns dados considerados até então como verdadeiros*”³²;

- (d) de posse desse relatório, Luiz Carneiro teria convocado a nova diretoria da OGX e dado ciência do seu conteúdo, tendo recomendado a criação do GT com o objetivo de “*avaliar a oportunidade de desenvolvimento da produção das acumulações de Pipeline, Fuji, Illimani e Osorno*”, sugestão que alegaram ser sido aprovada por unanimidade;
- (e) os profissionais da Schlumberger não teriam sido contratados para fazer análises de natureza econômica ou financeira acerca da exploração dos Campos, pois, além do GT não ter esse intuito, tal contratada não prestaria serviço de certificação de reserva;
- (f) o trabalho do GT, apresentado à diretoria em 24.09.12, utilizou o projeto de engenharia existente considerando um cenário pessimista, o qual revelou um volume in place menor do que o considerado até então, e “*não passou de um teste de robustez dos ativos e seus resultados não devem ser tratados sequer como conclusões preliminares*”; além disso, o estudo teria sugerido uma série de providências a serem tomadas antes de apresentar números definitivos;
- (g) o setor de exploração e produção de petróleo seria volátil e incerto, motivo pelo qual a todo momento surgiriam opiniões técnicas divergentes. Posto isso, seria necessário uma série de estudos e testes para que o entendimento de certo profissional fosse definitivamente demonstrado. O administrador que divulgasse ao mercado informações suspeitas sem a necessária análise criteriosa instauraria “*uma situação absolutamente inadmissível*”;
- (h) até o final de junho de 2013, não haveria profissional da OGX ou das sociedades contratadas que fosse capaz de atestar qual era a real situação dos Campos; portanto, até o referido mês, quando foi concluído o trabalho de reavaliação de ativos, inexistia uma informação relevante que devesse ser divulgada ao mercado como entendeu a SEP, fosse sob a forma de fato relevante ou por meio das demonstrações financeiras;
- (i) vários fatos seriam incompatíveis com premissa equivocada da SEP de que já existiria certo grau de certeza quanto à inviabilidade econômica dos Campos antes 01.07.2013, como (a) a recomendação do GT para que fossem tomadas diversas ações para determinar a real situação dos Campos, cabendo destacar o comportamento do terceiro poço de Tubarão Azul; (b) as divergências entre técnicos das áreas de exploração e de reservatórios (a diretoria de exploração possuía uma visão muito diferente em relação aos cenários utilizados no *power point* na reunião de 24.09.2012), o que demonstraria que a OGX não estava preparada para uma tomada de decisão sobre esses ativos; (c) a continuidade do trabalho da RATE e os demais estudos posteriormente realizados; (c)

³² A defesa menciona que o documento consta às fls. 2.514-2530 do PAS RJ2014/6517.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

a declaração de comercialidade enviada à ANP em março de 2013; e (d) o fato de, em setembro de 2012, o conselho de administração da OSX ter decidido pela manutenção da construção do OSX-2;

- (j) o termo de acusação teria trazido dois tratamentos diferentes conferidos pela legislação societária no que se referia ao dever dos administradores de divulgar informação relevante: o primeiro sobre a publicação de fatos relevantes, e o segundo sobre a elaboração de informações financeiras; para o primeiro haveria uma exceção para o dever de pronta divulgação, sendo que para o segundo não haveria tal tolerância;
- (k) haveria divergência de opiniões dentro da SEP, uma vez que no termo de acusação referente ao PAS CVM nº RJ2014/6517 a acusação teria afirmado que (a) os dados negativos apurados em setembro de 2012 ainda necessitavam de comprovação, (b) os resultados do GT significavam, ainda que preliminarmente, a inviabilidade econômica dos Campos. Dessa forma, a SEP teria reconhecido que os dados negativos apresentados pelo GT eram preliminares e, portanto, necessitavam de estudos mais aprofundados, então não poderia no presente processo exigir o impairment dos ativos ainda no 3º ITR/12;
- (l) a inclusão de notas explicativas sobre as incertezas relacionadas à viabilidade econômica dos campos de Tubarão Tigre, Areia e Gato no 3º ITR/12, DF12 e 1º ITR/13 colocaria em risco interesse legítimo da OGX, uma vez que desqualificaria o projeto de exploração em curso antes mesmo de serem obtidos os resultados definitivos dos estudos e projeções que ocorriam em paralelo, pois, se de um lado a reunião do GT, a solicitação de estudos à RATE e a realização do reproprocessamento da sísmica das acumulações em questão denotam que haviam incertezas sobre a viabilidade dos Campos, do outro, seria certo que esses mesmos fatos evidenciariam que a Companhia acreditava que os problemas vislumbrados até aquele momento poderiam ser transpassados, motivo pelo qual prosseguiu com a Declaração de Comercialidade junto à ANP em março de 2013;
- (m) não obstante existam dispositivos dos pronunciamentos contábeis que determinem a divulgação de informação relevante em notas explicativas às demonstrações financeiras ainda que a mesma não tenha atendido aos critérios para efetuar o seu reconhecimento contábil, há permissivo legal para que as informações relevantes não sejam divulgadas ao mercado quando isso puder colocar em risco interesse legítimo da companhia, além da norma regulamentar que faculta a divulgação de projeções e estimativas, as quais, se divulgadas, devem ser revisadas em até um ano (art. 20, caput, c/c §2º da ICVM 480³³);

³³ Art. 20. A divulgação de projeções e estimativas é facultativa. (...) § 2º As projeções e estimativas devem ser revisadas periodicamente, em intervalo de tempo adequado ao objeto da projeção, que, em nenhuma hipótese, deve ultrapassar 1 (um) ano.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

- (n) as demonstrações financeiras em questão não estariam eivadas de quaisquer irregularidades, tendo sido preparadas pelos contadores da Companhia, submetidas aos auditores independentes, que não fizeram qualquer ressalva, e aprovadas pela diretoria e pelo conselho de administração, portanto todo o procedimento de elaboração e aprovação desses documentos teria sido feito em conformidade com os arts. 176 e 177 da Lei nº 6.404/76.

V.1 DEFESA CONJUNTA DE LUIZ CARNEIRO, REINALDO VARGAS, PAULO GUIMARÃES E JOSÉ CAVALCANTI

58. Além dos argumentos resumidos no item anterior, especificamente com relação a esses acusados a defesa sustentou que os diretores não tinham competência estatutária para elaborar as demonstrações financeiras da Companhia. A regra contida no art. 176 da Lei nº 6.404/76 deveria ser interpretada à luz do art. 143, inciso IV da mesma lei³⁴, que estabelece que o estatuto social deve delimitar o âmbito de atuação específica de seus diretores, fixando as atribuições e poderes de cada um³⁵.

59. Luiz Carneiro, Reinaldo Vargas, Paulo Guimarães e José Cavalcanti eram, respectivamente, diretores presidente, de produção, de exploração e jurídico da OGX e, portanto, conforme previa o estatuto social da OGX, teriam atribuições distintas daquelas conferidas ao diretor financeiro³⁶, não lhes competindo diligenciar assuntos específicos relativos às demonstrações financeiras da Companhia.

60. Além disso, a defesa alegou que a peça acusatória não teria descrito adequadamente e individualizado a conduta dos acusados nas alegadas práticas irregulares, estando ausentes na denúncia a descrição da ação ou omissão cometida e a demonstração de nexo de causalidade.

61. Ademais, não haveria dúvida quanto à improcedência da Acusação na medida em que (i) vigoraria a responsabilidade individual do administrador, (ii) a SEP não teria comprovado qualquer irregularidade cometida por estes diretores de forma efetiva e perpetrada, e (iii) tais administradores não possuiriam competência estatutária específica para diligenciar a elaboração das demonstrações financeiras.

62. Em seguida, a defesa afirmou que as demonstrações financeiras em questão não estariam eivadas de quaisquer irregularidades, uma vez que todo o procedimento de elaboração e aprovação desses documentos teria sido feito em conformidade com os arts. 176 e 177 da Lei nº 6.404/76.

³⁴ Art. 143. A Diretoria será composta por 2 (dois) ou mais diretores, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo conselho de administração, ou, se inexistente, pela assembléia-geral, devendo o estatuto estabelecer: (...)

IV - as atribuições e poderes de cada diretor.

³⁵ A defesa citou trecho do voto da Diretora Ana Dolores no PAS CVM nº 2014/918, julgado em 04.11.2014.

³⁶ Afirmam que seria o diretor responsável, segundo o estatuto, por fazer elaborar as demonstrações financeiras da Companhia.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

63. A defesa afirmou, ainda, que os acusados não teriam infringido o dever de diligência, pois teriam atendido aos subdeveres específicos que o compõem, a saber: (i) dever de se qualificar (todos seriam plenamente qualificados para exercer seus respectivos cargos); (ii) dever de bem administrar (os acusados sempre teriam atuado de modo a atingir os interesses da Companhia e, com relação às demonstrações financeiras, teriam atuado de forma diligente, pois não haveria razão para efetuar a baixa dos ativos e, portanto, não caberia a revelação de dados inconclusivos por meio de notas explicativas); (iii) dever de se informar e de investigar (diante das divergências internas, solicitaram estudos que pudessem embasar as decisões relativas aos Campos, o que demonstraria que procuravam se informar adequadamente para tomar decisões de forma embasada e consciente); (iv) dever de vigiar (pelo exposto, não haveria dúvidas de que acompanhavam os negócios da Companhia e, quanto às informações financeiras, as discutiram e reviram, tendo concluído que não havia razão para questioná-las).

64. Igualmente, os acusados alegam que teriam cumprido fidedignamente com os deveres de atuar visando aos fins e no interesse da Companhia e de servi-la com lealdade, pois (a) teriam buscado soluções para dar continuidade à exploração dos Campos, (b) não se omitiram no exercício de suas atribuições e na proteção dos direitos da Companhia, promovendo todos os estudos possíveis antes de divulgarem que os Campos eram inviáveis. Além disso, argumentam que a CVM deveria analisar a conduta dos acusados sopesando todos os deveres a que estavam adstritos no exercício de suas funções, sem que um dever prevaleça sobre o outro (fazendo referência ao dever de informar).

65. Por fim, foi sustentado que, no âmbito administrativo, a responsabilidade objetiva e solidária não seria aplicável, pois vigoraria o postulado da culpa própria e concreta dos indiciados. Considerando que a área técnica não teria logrado êxito na demonstração de culpa dos acusados, a peça acusatória teria se baseado na inaplicável teoria da responsabilidade objetiva e, portanto, eventual condenação seria despropositada e abusiva.

66. Diante do exposto, a defesa solicitou a absolvição dos acusados e, caso tal pedido não seja atendido, ressaltou-se que esta Autarquia deveria levar em consideração, para fins de dosimetria, que os acusados não são reincidentes.

V.2. DEFESA DE ROBERTO MONTEIRO (fls. 912-956)

67. A defesa de Roberto Monteiro alegou a ausência de má-fé na atuação do então diretor financeiro, pois o acusado teria atuado de forma diligente e de boa-fé, visando à consecução do objeto social e ao atendimento dos interesses da Companhia.

68. Além disso, o acusado não poderia ser responsabilizado pela irregularidade em questão uma vez que (i) o administrador possuiria poder discricionário na condução dos negócios da sociedade, (ii) o “princípio” da *Business Judgment Rule* conferiria proteção ao administrador que



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

agisse de boa-fé e no interesse da sociedade, e (iii) esta CVM já teria reconhecido que a verificação da prática de má-fé seria indispensável para a aplicação de penalidades³⁷.

69. No mais, a defesa solicitou a absolvição de Roberto Monteiro e pediu para que se levasse em consideração, em caso de punição, que o acusado não é reincidente.

V.3 DEFESA DE EIKE BATISTA (fls. 1.007-1.067)

70. Inicialmente, a defesa de Eike Batista alegou que a acusação seria inepta, pois não foram incluídos no polo passivo os demais membros do conselho de administração, o que configuraria violação aos princípios da legalidade e da indivisibilidade acusatória. Ademais, sustenta que *“não existe, absolutamente, norma legal que torna cada conselheiro, integrante de um órgão que decide por maioria (Lei das Sociedades Anônimas, art. 140, IV), responsável por atos que, colegiado o conselho, não podem gerar sua responsabilidade individual”* (fl. 1.016).

71. Na visão da defesa, não poderia o acusado responder isoladamente por uma atribuição do órgão colegiado e, sendo as demais infrações imputadas no presente processo meros desdobramentos de atribuições do próprio conselho de administração, a preliminar de ilegitimidade passiva abarcaria as demais imputações.

72. Quanto ao mérito, a defesa afirmou que o acusado não tinha capacitação técnica para acompanhar de perto os estudos e teria se cercado dos melhores profissionais. Além disso, afirmou que não detinha a informação sobre a inviabilidade econômica dos Campos nas ocasiões citadas pela acusação (em um primeiro momento, a SEP teria citado setembro de 2012, e depois teria afirmado que ao menos na reunião do conselho realizada em 15.04.2013), até porque não haveria essa certeza em nenhuma dessas oportunidades.

73. Afirmou que após a divulgação do fato relevante de 01.07.2013, a OGX teria adotado imediatamente as providências cabíveis para a atualização das projeções da Companhia, em observância aos prazos da Instrução CVM nº 480/09, tendo registrado já no 2º trimestre de 2013 a baixa daqueles ativos. Em que pese a SEP afirmar que a informação poderia ter sido divulgada por meio de nota explicativa, citando dispositivos do CPC 00-R1, item 4.3, e CPC 26-R1, itens 125, 129 e 131, no entender da defesa o conteúdo de tais itens seriam eivados de subjetividade, *“sendo razoável concluir que não há, explicitamente, a determinação dos elementos específicos que deveriam ser evidenciados”*.

74. Sustentou que não poderia se exigir do acusado a produção de prova negativa, no sentido de não dispor de elementos, antes de 01.07.13, para concluir pela inviabilidade econômica dos Campos. De modo a demonstrar o desconhecimento de Eike Batista com relação a questão, a defesa afirmou que:

³⁷ A defesa citou trecho do Inquérito Administrativo CVM nº 33/98, julgado em 20.07.00.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

- (a) o acusado não teria o conhecimento técnico necessário para acompanhar de perto os estudos realizados;
- (b) Eike Batista outorgou uma *Put* à OGX no valor de R\$ 1 bilhão em 2012 e comprou ações da companhia em março de 2013, atitudes que não teria tomado caso possuísse a dita informação relevante; e
- (c) o fundeio do OSX-2 na Ásia, definido na reunião de 15.04.2013, teria se dado por motivos exclusivamente econômicos, pois ainda não haveria qualquer definição quanto ao local preciso de sua permanência.

75. Outro ponto ressaltado pela defesa diz respeito à impossibilidade de condenar Eike duplamente por um mesmo fato, decorrente do princípio do *non bis in idem* que estabelece “a impossibilidade de, em decorrência do cometimento de um fato unitário, a pessoa, natural ou jurídica, ser apenada ou processada duplamente pelo Estado”. Assim, afirmou que “as múltiplas acusações desferidas pela SEP em vários processos administrativos sancionadores a partir dos mesmos fatos (controvérsia sobre a viabilidade econômica dos campos de petróleo) configura claro abuso de ação punitiva estatal”.

76. No mais, alegou que as normas contábeis mencionadas na Acusação seriam eivadas de subjetividade e a Resolução CFC nº 1.328/11³⁸ dispõe que as informações constantes nas notas explicativas devem “contemplar os fatores de integridade, autenticidade, sinceridade e relevância³⁹”. Isto posto, e considerando a incerteza quanto aos Campos, não haveria informação que pudesse ser classificada como relevante, não havendo necessidade de notas explicativas. Além disso, os pareceres dos auditores independentes não teriam identificado qualquer inconsistência nas demonstrações financeiras analisadas.

77. Quanto aos deveres de diligência dos administradores, não seria possível identificar qualquer violação, por parte do acusado, ao art. 153 da Lei nº 6.404/76, pois teriam sido preenchidos todos os requisitos necessários para se aferir o comportamento diligente do administrador⁴⁰.

78. A defesa sustentou, ainda, que o acusado teria sido o que mais investiu e o que mais perdeu com a derrocada das companhias do grupo, e sempre teria agido no melhor no interesse de ambas, não sendo possível “divisar culpa na conduta do acusado”.

79. Diante do exposto, a defesa solicitou (i) a distribuição por conexão do presente processo ao relator do PAS CVM nº RJ2014/578 ou a sua suspensão até o julgamento do referido processo; (ii) o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva; (iii) a não punição do acusado duas vezes pelo mesmo fato, notadamente o deduzido neste processo e no PAS CVM nº RJ2015/1421; (iv) a absolvição do acusado ou, em caso de condenação, a aplicação de pena não

³⁸ Regulamenta a Estrutura das Normas Brasileiras de Contabilidade.

³⁹ NBC T 6.2.3.1, “a”

⁴⁰ Os deveres indicados pela defesa seriam (i) se qualificar para o cargo; (ii) bem administrar; (iii) se informar; (iv) investigar; e (v) vigiar.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

superior à advertência e (iv) a produção de prova pericial contábil, de engenharia de petróleo e testemunhal.

VI. PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO

80. Em 16.05.2015, Luiz Carneiro, Reinaldo Vargas, Paulo Guimarães e José Cavalcanti apresentaram proposta de termo de compromisso na qual se comprometiam a efetuar pagamento individual no valor de R\$100.000,00 (cem mil reais) (fls. 1.274-1.275). Na mesma data, Roberto Monteiro apresentou proposta de termo de compromisso que consistia no pagamento de R\$200.000,00 (duzentos mil reais) (fls. 1276-1277).

81. Em 23.02.2016, o Colegiado desta Autarquia acompanhou o entendimento exarado no parecer do Comitê de Termo de Compromisso e deliberou pela rejeição das propostas apresentadas, pois entendeu que um posicionamento do órgão em sede de julgamento resultaria em um efeito paradigmático de maior relevância e visibilidade junto ao mercado (fls. 1.288-1.289).

VII. DA REDISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO

82. Em 26.07.2016, o presente processo foi sorteado para minha relatoria (fls. 1.302), em conexão com os processos sancionadores CVM nº RJ2014/0578 e nº RJ2015/1421, conforme mencionado anteriormente.

VIII. ATOS POSTERIORES À REDISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO

83. No dia 18.09.2018, foi protocolado expediente para comunicar o falecimento do acusado Paulo de Tarso Martins Guimarães (fls. 1.446-1.447;1.542-1.544).

84. Na mesma data, determinei, em razão do pedido de produção de provas feito por Eike Batista, a juntada de provas produzidas no PAS CVM nº RJ2014/0578, processo distribuído em conexão com o presente processo⁴¹, quais sejam, (i) documento intitulado “*Laudo Técnico Pericial de Engenharia de Petróleo e Geociências*” elaborado pela Hill International (“Laudo de Engenharia”)⁴²; e (ii) prova testemunhal na qual foram ouvidas pessoas indicadas conforme rol apresentado e quesitos formulados pelo acusado⁴³ (fls. 1.343-1.344).

85. Além disso, foi concedido prazo para que Eike Batista apontasse justificadamente as provas que pretendia produzir, na hipótese de tal prova ainda não ter sido juntada aos autos, devendo indicar, ainda, o rol das testemunhas que pretende convocar com seus respectivos endereços.

86. Em manifestação de 01.10.2018, Eike Batista requereu a juntada do documento intitulado “*Parecer Econômico sobre venda das ações da OGX e OSX realizadas por Eike Fuhrken*”

⁴¹ Reunião do Colegiado realizada em 07.07.2015.

⁴² Fls. 2.497-2.591 do PAS CVM nº RJ2014/0578.

⁴³ Fls. 2.761 do PAS CVM nº RJ2014/0578.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Batista entre maio e setembro de 2013” (fls. 1.456-1.457), elaborado pela Tendências Consultoria Integrada (“Tendências”) em agosto de 2014 (“Laudo Econômico”), alegando que tal documento “analisa com detalhes a conduta econômica do acusado e demonstra sua absoluta boa-fé com respeito às empresas do grupo X, notadamente OGX e OSX, o que coincide e corrobora o teor da defesa apresentada”, pedido deferido em 05.10.2018 (fls. 1.509).

VIII.1 PROVAS PRODUZIDAS

VIII.1.1 *Laudo de Engenharia (fls. 1.348-1.440)*

87. De maneira geral, o laudo concluiu que a Política de Divulgação e Uso de Informações para o Mercado da OGX seria correta e adequada sob a perspectiva da boa governança e refletiria as melhores práticas da indústria à época de sua elaboração.

88. A OGX teria se esforçado em promover, com base nos fatos de interesse da época, o *full disclosure* dos acontecimentos, tratando os fatos comunicados como relevantes. A Companhia também consideraria que a maioria deles trataria de informações que chegariam ao mercado de qualquer forma, uma vez que a ANP as disponibilizaria em seu site.

89. Conforme o laudo, seria possível, notadamente com as tecnologias mais recentes, efetuar estimativas de volumes de uma descoberta ainda durante a perfuração de um poço exploratório. Para isso, a OGX teria feito uso de tecnologias como o monitoramento em subsuperfície com LWD/MWD (*Logging While Drilling/Measuring While Drilling*).

VIII.1.2 *Oitiva de Testemunhas (fls. 1.441)*

90. Em 01.02.2017, foi realizada a oitiva das testemunhas arroladas pela defesa de Eike Batista no âmbito do PAS CVM nº RJ2014/578. Compareceram à CVM Antônio Nicolau, Raul Silva, Ernesto Guedes e Juliano Macedo. Este último substituiu, a pedido da defesa, Marcello Guimarães.

91. De maneira geral, os depoentes reafirmaram as informações trazidas pelas perícias e laudos protocolados por Eike Batista.

92. Neste sentido, Raul Silva, diretor da ICTS e responsável por liderar os trabalhos que resultaram no relatório apresentado pela defesa, ratificou o conteúdo do documento acerca (i) da situação de dívida de Eike Batista com os credores; (ii) dos investimentos de Eike Batista nas Companhias; (iii) do desenquadramento das garantias das obrigações referentes às dívidas; (iv) dos instrumentos disponíveis para execução das ações pelos credores; e (v) da totalidade dos recursos que foram direcionados ao pagamento de dívidas.

93. Referida testemunha afirmou que teria verificado a venda das ações por meio das notas de corretagem acostadas aos anexos e que toda a documentação apresentada teria sido suficiente para comprovar a relação entre o acusado e os credores. Ao final, também confirmou a informação



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

de que Eike Batista teria aportado recursos na OSX mesmo após as alienações (entre setembro e dezembro de 2013).

94. Ernesto Guedes, responsável pelo parecer econômico da Tendências Consultoria Integrada, analisou as alienações de ações das Companhias realizadas pelo acusado e corroborou com o conteúdo do parecer econômico. Quanto à participação acionária de Eike Batista na OGX e OSX, a testemunha confirmou que, entre setembro de 2012 e setembro de 2013, a participação do acusado pouco teria mudado mesmo após as alienações.

95. Além disso, sobre o endividamento do Grupo EBX, Ernesto Guedes respaldou o parecer no que diz respeito ao volume de dívida do grupo:

“(…) há uma constatação de que o grupo EBX e seu endividamento eram representativos no panorama do mercado bancário brasileiro (…) a conclusão disso é que um colapso súbito [das Companhias] com aceleração de suas dívidas traria algum tipo de consequência para economia e mercado financeiro”.

96. Ernesto Guedes declarou que o acordo entre a holding EBX e a MDC tratava-se de uma dívida no sentido econômico devido à existência de um *pool* de ações da OGX como garantia de cumprimento e que a perda de valor das ações teria suscitado o vencimento antecipado dessa dívida.

97. Quanto ao lapso temporal das conclusões do GT e o primeiro momento de alienação, Ernesto Guedes confirmou o entendimento de que já haveria passado muito tempo. Além disso, também confirmou que a venda apenas parcial das ações não indicaria comportamento oportunista de quem quer tirar proveito de informação privilegiada.

“(…) existem razões para a venda das ações que não simplesmente antecipar um fato relevante que seria divulgado alguns dias ou semanas depois, mas simplesmente prover recursos para resolver uma situação financeira delicadíssima (…) se o conhecimento do que ia ser divulgado no fato relevante vinha de alguns meses, essa venda poderia ter sido antecipada, inclusive sendo realizado um valor maior”.

98. Quanto à imputação de manipulação de preços, afirmou que o resultado concreto das divulgações no *Twitter* não teria ocasionado um aumento no preço das ações, tendo ocorrido exatamente o oposto. Não seria possível comprovar que tais divulgações influenciaram o mercado do jeito que a Acusação faz parecer.

99. Antônio Nicolau, responsável pelo estudo técnico da APSIS sobre a evolução da participação de Eike Batista nas Companhias, confirmou o conteúdo do laudo no que diz respeito à queda do valor das ações de emissão da OGX e OSX desde 2011.

100. Além disso, reforçou que a primeira alienação do acusado teria ocorrido com os valores em baixa e que o valor perdido por ele referente à desvalorização da cotação em bolsa das ações da OGX entre 24.09.2012 e 10.06.2013 foi de 10,748 bilhões de reais. Também declarou que ambas as vendas teriam servido para pagar os credores da holding EBX.

101. Por fim, certificou que Eike Batista teria realizado aportes nas Companhias entre os períodos de alienação.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

102. Juliano Macedo, geólogo corresponsável pela elaboração do Laudo de Engenharia de petróleo, também confirmou, de maneira geral, o conteúdo do documento.

103. A evolução da campanha exploratória (fase mais arriscada) da OGX teria seguido, segundo o depoente, o esperado, em termos técnicos, de uma empresa de exploração de óleo e gás.

104. Quanto ao resultado do GT, Juliano Macedo confirmou o entendimento de que em 25.09.2012 seria impossível confirmar a inviabilidade comercial dos Campos, uma vez que apenas em fevereiro 2013 saiu o reprocessamento da sísmica, que ajudou no melhor entendimento dos testes passados. Desse modo, só a partir desta última data os dados teriam sido trabalhados com mais detalhes pelos técnicos da OGX.

105. Todo esse processo de análise de fatores seria demorado. Segundo a testemunha, os primeiros testes não demonstrariam a presença de H₂S, ácido extremamente corrosivo que tornaria toda a exploração mais cara.

106. Juliano Macedo também declarou que os prazos impostos pela ANP seriam severos, de modo que teria sido esse o motivo que teria obrigado a OGX, cujos técnicos ainda rodavam testes, a declarar a comercialidade dos Campos. Nessa questão, toda a cronologia estaria correta. Seria normal que uma empresa de petróleo fizesse uma constante reavaliação de suas reservas, pois a indústria de óleo e gás é de muito risco.

107. Por fim, declarou, em forma de “comentário pessoal”, que:

“A indústria do petróleo é diferente de qualquer outra (...) o mercado brasileiro de ações não está acostumado com esse mercado [de petróleo] (...) O investidor não conhece o assunto (...) e você tem que saber ler as informações porque leigo em petróleo não pode ler da mesma forma. Quem é do ramo não se assustou [com o anúncio de que não seria economicamente viável o desenvolvimento dos Campos] (...) a maneira de você fazer a leitura [dos fatos relevantes] exige um certo conhecimento (...)”

VIII.1.3 Laudo Econômico (fls. 1.456-1.457)

108. Tal documento concluiu que a situação econômico-financeira das principais empresas do Grupo X seria muito grave à época dos fatos, com insuficiente capacidade de geração de caixa para manutenção de suas atividades e elevado endividamento.

109. A situação estaria se agravando ainda mais, pois a geração negativa de caixa nas principais empresas acarretaria elevação adicional do endividamento e o acúmulo de prejuízos resultaria em redução do patrimônio líquido, evidente ao se considerar de forma combinada (soma simples) as empresas de capital aberto do grupo.

110. As dívidas descritas não refletiriam completamente, em termos econômicos, o endividamento do grupo EBX, pois abrangeriam as empresas fechadas. Ademais, existiria um contrato do controlador do grupo e do fundo *Centennial Asset Brazilian Equity Fund LLX* com o MDC para captação de US\$ 2 bilhões na forma de participação de 5,63% em ativos detidos por



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Eike Batista direta ou indiretamente. Esse contrato poderia ser considerado um contrato de participação, mas, do ponto de vista econômico, constituiria uma dívida.

111. A ocorrência de default de dívidas garantidas da OSX resultaria em aumento do endividamento assumido pela OGX. Dado que, naquele momento, o endividamento da Companhia já seria de US\$ 3,97 bilhões, a incorporação de mais empréstimos e financiamentos ao seu passivo resultaria em um endividamento superior a US\$ 4 bilhões. Tal situação poderia acarretar antecipação de vencimento dos títulos emitidos pela OGX e, assim, comprometer sua liquidez.

112. Diante do elevado endividamento ao qual o grupo estaria exposto e dos prejuízos operacionais que já se apresentavam desde o início do ano, a venda das ações OGX e OSX ocorridas no período entre maio e junho e agosto a setembro de 2013 teria sido motivada pelo intuito de renegociar e adimplir os contratos mencionados, que já abrangeriam as ações alienadas por Eike Batista como garantia de pagamento aos credores.

113. A atuação do Acusado teria evitado que as posições acionárias em garantia fossem vendidas em sua totalidade, tendo ele preservado sua condição de acionista controlador tanto na OGX quanto na OSX até a presente data.

114. Ademais, o endividamento do Grupo EBX constituiria parte significativa do passivo das instituições do Sistema Financeiro Nacional (SFN)⁴⁴, sendo que o default do grupo acarretaria em graves consequências, com redução de liquidez e capacidade de empréstimos do sistema bancário brasileiro como um todo.

115. Alguns compromissos vencidos em maio e setembro de 2013, se não fossem cumpridos ou renegociados, implicariam em default, com repercussão para todo o grupo, pois suas empresas seriam submetidas aos efeitos da declaração pelos credores do vencimento antecipado cruzado (*cross default e acceleration default*) da quase totalidade das operações de créditos bancários e títulos mobiliários.

116. Em uma situação como essa, restaria aos credores e às empresas liquidar os ativos ou preservar as operações, permitindo a geração de recursos, nas atividades que se mostrassem economicamente viáveis e amenizassem as perdas. Essa última solução geralmente implicaria a repactuação dos empréstimos concedidos e a concessão de novos empréstimos ou aporte de recursos que permitissem a continuidade das atividades viáveis.

117. Haveria, portanto, um grande lapso temporal entre as conclusões parciais do GT que colocaram em dúvida o potencial dos poços de petróleo da Companhia e o momento em que Eike Batista vendeu ações. No mesmo período, a queda no preço das ações teria sido brutal, sendo resultado das próprias divulgações trimestrais e eventuais obrigatórias que eram feitas ao mercado.

⁴⁴ Do total registrado em maio de 2013, as dívidas e os avais contraídos pelo grupo com o Itaú totalizariam R\$ 5,1 bilhões, representando 6,2% do Patrimônio Líquido (PL) da instituição, enquanto o total contraído com o Bradesco corresponderia a 5,5% do seu PL, dado o endividamento de R\$ 3,6 bilhões do grupo com essa instituição. Em relação ao BTG, as dívidas seriam R\$ 2,5 bilhões, que representariam 23,6% do patrimônio líquido do banco.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

118. O momento e as circunstâncias em que Eike Batista vendeu ações e a destinação dada aos recursos financeiros obtidos permitiriam concluir que a conduta teve o objetivo econômico de cumprir obrigações e reestruturar dívidas existentes.

VIII.2 MANIFESTAÇÕES SOBRE AS PROVAS PRODUZIDAS

119. Em 30.11.2018, os acusados Luiz Carneiro, Reinaldo Belotti, José Faveret e Roberto Monteiro apresentaram manifestação sobre o Laudo de Engenharia, tendo ressaltado diversos pontos do documento e, ao final, concluem da seguinte forma (fls. 1.530-1.537):

Tendo em vista a perícia realizada, restou claro que a acusação formulada em face dos defendentes **não** merece prosperar, uma vez foi (sic) comprovado tecnicamente que somente ao final de junho de 2013 foram obtidos resultados conclusivos a respeito da inviabilidade dos Campos em questão. Dessa forma, somente a partir de então havia justificativa para o registro de perda do valor recuperável dos ativos. Ademais, (...) existia legítimo interesse da Companhia a ser preservado enquanto os estudos estavam sendo desenvolvidos, inexistindo, portanto, qualquer irregularidade na elaboração e divulgação das demonstrações contábeis da OGX referentes ao 3º ITR/2012, ao exercício encerrado em 31.12.2012 e ao 1º ITR/2013.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 27 de maio de 2019.

HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA
DIRETOR RELATOR



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2014/12838

Reg. Col. nº 9756/2015

Acusados:

Eike Fuhrken Batista
Luiz Eduardo Guimarães Carneiro
Reinaldo José Belotti Vargas
José Roberto Penna Chaves Faveret Cavalcanti
Roberto Bernardes Monteiro
Paulo de Tarso Martins Guimarães

Assunto:

Omissão de informações relevantes para compreensão da situação financeira e patrimonial da OGX Petróleo e Gás Participações S.A. (atual Dommo Energia S.A.) por ex-administradores. Infração aos artigos 142, inciso III, 153, 176 c/c 177, § 3º, da Lei nº 6.404/76 e artigos 14, 26 e 29 da Instrução CVM nº 480/09.

Diretor Relator:

Henrique Machado

VOTO

I. OBJETO

1. Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de Relações com Empresas (“SEP” ou “Acusação”) em face dos ex-administradores da OGX Petróleo e Gás Participações S.A.¹ (“OGX” ou “Companhia”) Eike Fuhrken Batista (“Eike Batista”), Luiz Eduardo Guimarães Carneiro (“Luiz Carneiro”), Reinaldo José Belotti Vargas (“Reinaldo Vargas”), José Roberto Penna Chaves Faveret Cavalcanti (“José Cavalcanti”), Roberto Bernardes Monteiro (“Roberto Monteiro”) e Paulo de Tarso Martins Guimarães (“Paulo Guimarães”, conjuntamente com os demais denominados “Acusados”), por terem, em síntese,

¹ Para fins deste documento, utilizar-se-á o nome notoriamente conhecido à época dos fatos, conforme acima identificado, sendo válido esclarecer que em assembleia de acionistas realizada em 06.12.2013 a denominação social da sociedade foi alterada para Óleo e Gás Participações S.A., tendo sido incorporada à Dommo Energia S.A., conforme fato relevante divulgado em 26.11.2018.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

omitido nas demonstrações financeiras da OGX informações relevantes para a compreensão da situação financeira e patrimonial da Companhia².

2. Em reunião do Colegiado realizada em 07.07.2015, foi reconhecida a conexão entre o PAS CVM nº RJ2014/0578³, o presente processo e o PAS CVM nº RJ2015/1421⁴, tendo os três sido redistribuídos para minha relatoria em 26.07.2016.

3. Ao analisar os três processos vê-se claramente que as condutas avaliadas estão ligadas pelas mesmas circunstâncias fáticas, a demonstrar a necessidade de se proceder à análise conjunta dos fatos contidos nestes processos, notadamente o progresso das informações relativas à dificuldade da Companhia em monetizar determinados campos de exploração de óleo e gás. O exame destes fatos em conjunto facilitará a compreensão da controvérsia encerrada em cada um dos processos, bem como revelará o desenrolar dos acontecimentos que resultaram no fato relevante sobre a inviabilidade da exploração comercial dos campos em julho de 2013, importante referência para a instauração de diversos processos de apuração nesta Autarquia.

4. Nesse contexto, antes de adentrar o mérito, entendo conveniente trazer um breve histórico do contexto fático que será objeto de análise nesse processo e nos outros dois distribuídos em conexão, como se segue.

II. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

5. Conforme detalhado no relatório, a OGX iniciou suas atividades em 2007, tendo adquirido, nesse mesmo ano, diversas áreas exploratórias de petróleo e gás natural, em especial o bloco BM-C-41, situado na Bacia de Campos, no qual situavam-se, na parcela sul, as acumulações (reservas de petróleo) inicialmente chamadas de *Pipeline*, *Fuji* e *Illimani*, que posteriormente resultaram nos campos de Tubarão Tigre, Tubarão Gato e Tubarão Areia (“Campos”).

6. Entre 2009 e 2011, a OGX divulgou diversos fatos relevantes e comunicados ao mercado sobre o desenvolvimento das operações no referido bloco, sendo alguns deles para comunicar a descoberta de hidrocarbonetos em seus reservatórios⁵. Acerca da acumulação de

² A SEP propôs a responsabilização de Eike Batista, na qualidade de presidente do conselho de administração da OGX, por infração ao art. 142, inciso III, e art. 153 da Lei nº 6.404/76, e os demais acusados, na qualidade de membros da diretoria, por infração aos arts. 153 e 176 c/c 177, §3º, da Lei nº 6.404/76 e 14, 26 e 29 da Instrução CVM nº 480/09.

³ Processo em que se apura eventual uso de informação privilegiada por Eike Batista, bem como suposta manipulação de preços das ações de emissão da OGX e da OSX Brasil S.A. (“OSX”).

⁴ Processo em que se apura responsabilidade de ex-membros do conselho de administração da OSX por não terem tomado as providências necessárias para que as demonstrações financeiras evidenciassem informações relevantes para a compreensão da situação financeira e patrimonial da companhia.

⁵ Os fatos relevantes publicados nesse período estão às fls. 596-604v, 611-618, 633-641.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Pipeline, a SEP indicou algumas divulgações das quais se destacam, para fins deste processo, as informações a seguir:

- a) em 16.12.2009, a Companhia informou a descoberta de óleo durante a perfuração do poço OGX-2, com volume de óleo recuperável estimado entre 400 a 500 milhões de barris (fls. 597);
- b) em 22.12.2009, a Companhia divulgou nova estimativa do volume de óleo recuperável do poço OGX-2 entre 1 e 2 bilhões de barris (fls. 601);
- c) em 13.05.2010, ao divulgar a conclusão da perfuração dos poços OGX-6 e OGX-8, a Companhia comunicou também que identificou a conectividade entre os poços OGX-2A e OGX-6 (*Pipeline* e *Etna*), tratando-se de uma mesma acumulação com volume total de óleo recuperável estimado de 1,4 a 2,6 bilhões de barris (fls. 613-614);
- d) em 15.07.2011, no que se refere ao poço OGX-39HP, *Pipeline* horizontal, a Companhia divulgou (i) a conclusão da perfuração; (ii) o resultado indicando capacidade de produção de 10.000 barris por dia de óleo e (iii) identificação de boas condições de reservatório (fls. 641).

7. Em relação às acumulações *Fuji* e *Illimani*, destaca-se o seguinte:

- a) em 24.03.2010 e 31.03.2010, foram divulgadas detecções de hidrocarbonetos durante a perfuração do poço OGX-8 cuja acumulação foi denominada *Fuji* (fls. 611-612);
- b) em 13.05.2010, foi divulgada a (i) conclusão da perfuração do poço OGX-8 e (ii) a necessidade de novos dados para verificar se estavam “diante de uma mesma acumulação” referente à conectividade entre os poços OGX-3 e OGX-8 (fls. 613);
- c) em 24.01.2011, foi divulgada a presença de hidrocarbonetos na perfuração do poço 1-OGX-28D-RJS, cuja acumulação foi denominada *Illimani* (fls. 615).

8. Em 2011, os resultados dos poços exploratórios e dos testes de formação realizados nos referidos Campos já indicavam possível compartimentação diferente da prevista inicialmente, evidenciada notadamente pelos contatos óleo-água e pelas diferentes propriedades de óleo encontradas nos poços. Naquele momento, a gerência executiva de reservatórios da OGX (“Área de Reservatórios”) já sinalizava volumes de óleo e gás muito diferentes da interpretação inicial divulgada ao mercado (fls. 292-306).

9. Em meados de 2012, a Companhia decidiu realizar uma grande revisão dos volumes e reservas existentes nos reservatórios da OGX, bem como das suas perspectivas de produção, dado o cenário de risco identificado pela Área de Reservatórios. Nessa linha, em 24.07.2012, a Companhia formou um Grupo de Trabalho (“GT” ou Grupo de Trabalho”) com profissionais das



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

áreas de exploração e de reservatórios da OGX e da empresa Schlumberger Serviços de Petróleo Ltda. (“Schlumberger”), que, no dia 24.09.2012, realizou uma apresentação à diretoria executiva da Companhia com as seguintes conclusões (fls. 101-109;115-245):

- i) volume *in situ*⁶ de 676 milhões de barris de óleo equivalentes (boe) e de volume recuperável⁷ entre 49,5 milhões de boe (*cenário base*) e 77,7 milhões de boe (*cenário otimista*) para as acumulações; e
- ii) para qualquer dos cenários traçados (base ou otimista), o valor presente líquido (“VPL”) ⁸ para a exploração dos Campos era negativo.

10. Outro problema apontado pelo GT para o desenvolvimento dos Campos estaria relacionado à necessidade de desenvolver unidade de produção capaz de tratar o gás contaminante H₂S (sulfeto de hidrogênio) encontrado nos reservatórios.

11. A análise feita pelo GT confirmou o modelo concebido pela Área de Reservatórios da OGX, o que reduziu sobremaneira o volume *in situ* total de óleo dos Campos para a faixa de 700 milhões de barris. Associada à redução do volume, o GT destacou ainda relevante redução do fator de recuperação, o que resultou num volume recuperável de 80 milhões de barris no caso mais otimista e 50 milhões no mais provável.

12. Além dos baixos volumes recuperáveis, o GT ressaltou que o projeto de exploração precisaria realizar a perfuração de 12 poços horizontais, com produção coletada e processada em uma unidade de produção denominada WCPP, muito diferente da WHP-1 projetada para a área, bem como de um FPSO para receber o óleo já descontaminado para o processamento final. Essas especificidades encontradas no projeto elevaram significativamente os custos de produção de petróleo na área, tendo o GT concluído pela inviabilidade econômica da exploração dos Campos.

13. Em fevereiro de 2013, a empresa Rameshini Associates Technology & Engineering, LLC (“RATE”), contratada pela OGX, entregou estudo afirmando que o projeto da Companhia para solucionar o alto teor de gás contaminante (H₂S) nos Campos resultou em equipamentos de grandes dimensões e elevados custos, tendo sugerido à Companhia que avaliasse outras tecnologias para monetizar o projeto.

14. Importante registrar que, ainda que o projeto de desenvolvimento dos Campos fosse viável, os técnicos da OGX afirmaram que a Companhia teria grande dificuldade de obter licenças para o seu desenvolvimento em função dos altos teores de gás contaminante encontrados

⁶ “Volume estimado de petróleo existente no reservatório e expresso em condições ditas padrão, standard ou básicas” (fonte: <http://dicionariodopetroleo.com.br/dictionary/volume-de-oleo-in-situ/>, acesso em 15.02.2019).

⁷ Volume recuperável é a “[q]uantidade de óleo ou gás que se estima produzir de uma jazida de petróleo pelos métodos disponíveis” (fonte: <http://dicionariodopetroleo.com.br/dictionary/volume-recuperavel/>, acesso em 20.02.2019).

⁸ Método utilizado para determinar a viabilidade de um investimento em certo período de tempo.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

nos poços e, por conseguinte, do alto risco para os trabalhadores e para o meio ambiente (fls. 300).

15. Em 13.03.2013, a OGX divulgou fato relevante no qual informou que submeteu à ANP a declaração de comercialidade das acumulações *Pipeline*, *Fuji* e *Ilimani*. Como mencionado anteriormente, a divisão da acumulação *Pipeline* resultou nos campos de Tubarão Tigre e Tubarão Gato, enquanto as acumulações *Fuji* e *Ilimani* receberam, conjuntamente, o nome de campo de Tubarão Areia. A tabela abaixo apresenta total estimado do volume *in situ*⁹ dos Campos divulgado pela Companhia (fls. 613):

Volume <i>in situ</i> estimado (mmbœ ¹⁰) ¹¹			
	P90	P50	P10
Tubarão Tigre	314	461	675
Tubarão Gato	50	71	101
Tubarão Areia	157	291	563
Total	521	823	1339

16. Ainda em março de 2013, a empresa CGG Brasil realizou o reproprocessamento da sísmica dos reservatórios da OGX com dados mais precisos sobre as características da área, notadamente o comportamento dos poços produtores de Tubarão Azul. A elaboração do novo modelo de reservatório confirmou a intensa compartimentalização e descontinuidade dos reservatórios dos Campos.

17. Em junho de 2013, a Área de Reservatórios da Companhia emitiu relatório, em conjunto com a área de exploração, intitulado “Reavaliação dos Ativos da OGX na Bacia de Campos” (“Relatório de Reavaliação de Ativos”), contendo uma análise de todos os ativos da OGX na Bacia de Campos, no qual a Companhia formalizou a inviabilidade econômica da exploração dos campos de Tubarão Tigre, Tubarão Gato e Tubarão Areia (fls. 292-306).

18. Em 01.07.2013, a OGX divulgou fato relevante no qual informou não dispor de tecnologia capaz de tornar economicamente viável o desenvolvimento dos campos de Tubarão Tigre, Tubarão Gato e Tubarão Areia (fls. 729-731).

III. ANÁLISE DO CASO CONCRETO

III.1 PRELIMINARES

19. Em sua defesa, Eike Batista alegou ser impossível condená-lo duplamente por um mesmo fato, decorrente do princípio do *non bis in idem*, sob o argumento de que “as múltiplas

⁹ “Volume estimado de petróleo existente no reservatório e expresso em condições ditas padrão, standard ou básicas” (fonte: <http://dicionariodopetroleo.com.br/dictionary/volume-de-oleo-in-situ/>, acesso em 15.02.2019).

¹⁰ Milhões de barris e óleo equivalente.

¹¹ Os três cenários fazem referência aos percentuais de certeza quanto à produção.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

acusações desferidas pela SEP em vários processos administrativos sancionadores a partir dos mesmos fatos (controvérsia sobre a viabilidade econômica dos campos de petróleo) configura claro abuso de ação punitiva estatal” referindo-se às acusações constantes dos PAS CVM nº RJ2014/12838 e RJ2015/1421¹².

20. Quanto ao tema, inicialmente cabe ressaltar que esta Autarquia já tem o entendimento pacificado¹³ no sentido de que, apesar da ausência de previsão legal sobre sua aplicação nos processos administrativos sancionadores, a adoção do *non bis in idem* se justifica em decorrência do princípio da segurança jurídica, como se extrai do voto do Diretor Eli Loria proferido no PAS CVM nº 03/2006, julgado em 01.12.2010:

No que respeita ao princípio do *non bis in idem*, sabe-se que não existe normatização a respeito de sua aplicação no âmbito do processo administrativo sancionador. Entretanto, entendo que o referido princípio é consentâneo com o princípio da segurança jurídica e, esta sim, deve ser resguardada em todas as esferas, inclusive na que pertine a esta Autarquia, conforme preceitua o art. 2º, caput, da Lei nº 9.784/99.

21. Nesse sentido, a diretora Ana Novaes, em voto proferido no PAS CVM nº 04/2010, destacou que “[s]ão três os pressupostos necessários para a configuração de uma hipótese de *non bis in idem*: (i) a identidade de sujeitos; (ii) a identidade de fatos; e (iii) a identidade de fundamentos entre acusações feitas em momentos distintos.”

22. No caso concreto, ainda que haja identidade de sujeitos, não se verifica identidade de fatos nem de fundamentos utilizados para as acusações, sendo os atos comissivos ou omissivos praticados e investigados distintos, ainda que relativos ao mesmo período de tempo e decorrentes de fatos semelhantes.

23. Em ambos os processos é proposta a responsabilização de Eike Batista por ter deixado de adotar as providências compatíveis com a relevância e a natureza da matéria, de modo a assegurar que as demonstrações financeiras evidenciassem informações relevantes para a compreensão da situação financeira e patrimonial, em um caso, da OGX, e no outro, da OSX.

24. Em outras palavras, os processos analisam a atuação do acusado sob diferentes perspectivas¹⁴, no exercício de duas funções distintas em sociedades distintas, cada qual com objeto social específico, sendo ao acusado imputada responsabilidade por razões que não se confundem, embora tendo sido ocasionadas pelo mesmo fato gerador, qual seja, a inviabilidade dos Campos.

25. Por tais razões, a preliminar não merece acolhida.

¹² Fls. 1.065-1.066, PAS CVM nº RJ2014/12838 e fls. 611-612, PAS CVM nº RJ2015/1421.

¹³ V. PAS CVM 04/2010, julgado em 23.09.2014.

¹⁴ Eike Batista é acusado a qualidade de presidente do conselho de administração da OGX neste processo e como presidente do conselho da OSX no âmbito do PAS CVM nº RJ2015/1421.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

26. Alegam também que a peça acusatória não teria descrito adequadamente a conduta dos acusados nas alegadas práticas irregulares, estando ausentes na denúncia a descrição da ação ou omissão cometida e a demonstração de nexo de causalidade.

27. Quanto a essa alegação, entendo não assistir razão aos acusados, pois o termo de acusação traz elementos que permitem a individualização da conduta de cada um, especificando as infrações a eles imputadas. Há uma descrição detalhada das informações que teriam sido omitidas nas demonstrações financeiras e que fizeram com que não correspondessem à verdadeira situação econômica da Companhia.

28. Constatadas as infrações a normas que regem a divulgação de informações em demonstrações financeiras, consta no documento a identificação dos administradores que, na visão da Acusação, teriam sido responsáveis por sua elaboração e/ou revisão e, por consequência, pelas omissões apontadas. Por esse motivo, entendo que o argumento suscitado não merece prosperar.

29. Por fim, cumpre reconhecer a extinção da punibilidade¹⁵ com relação ao acusado Paulo de Tarso Martins Guimarães, em razão do seu falecimento em 07.09.2018, conforme noticiado às fls. 1.446-1.447 e 1.542-1.544 dos autos.

III.2 MATERIALIDADE DO DELITO

30. Conforme afirmado pelos Acusados, havia uma divergência entre duas áreas técnicas da OGX acerca do volume de óleo recuperável nas acumulações *Pipeline*, *Fuji* e *Illimani*; a área de exploração e a área de reservatórios, sendo essa última conservadora em suas expectativas quanto aos volumes de óleo *in situ* e recuperável dos Campos. Afirmam que tal divergência teria motivado uma reestruturação da administração em junho de 2012, ocasião em que o acusado Luiz Carneiro assumiu o cargo de diretor presidente e alterou a estrutura organizacional da Companhia ao transferir a área de reservatórios, que antes se reportava diretamente ao diretor de exploração, para a presidência.

31. Ao assumir o cargo, Luiz Carneiro “*solicitou ao novo gerente executivo de reservatórios (...) uma avaliação criteriosa de alguns assets da Companhia, o que gerou o relatório ‘Valoração dos Ativos Bacias de Campos e Parnaíba’ (julho/12), o qual questionava alguns dados considerados até então como verdadeiros (...)*” (fls. 962). Afirma a defesa que Luiz Carneiro convocou a nova diretoria da OGX e deu ciência do resultado da análise, tendo recomendado a criação de um grupo de trabalho com o objetivo de “*avaliação de oportunidade de desenvolvimento da produção das acumulações de Pipeline, Fuji, Illimani e Osorno, sugestão esta que foi aprovada por unanimidade*” (fls. 282v).

¹⁵ Com base no disposto nos arts. 107, I, do Código Penal, art. 52 da Lei nº 9.784/99 c/c art. 27 da Deliberação CVM nº 538/08.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

32. Esse histórico inicial é particularmente importante porque demonstra que havia uma dissensão dentro da própria Companhia quanto às estimativas de produção das acumulações, ou seja, as provisões que eram divulgadas aos investidores, as mais positivas dentre as possíveis, não eram unanimidade entre os técnicos. Isso pode ser comprovado pelo já citado documento produzido pela Companhia em junho de 2013, o Relatório de Reavaliação de Ativos, em que consta que já em 2011 as análises da área de reservatórios já haviam sinalizado “*volumes e compartimentação muito diferentes da interpretação inicial*”.

33. No referido relatório, os técnicos da Companhia relatam o histórico, cujo teor entendendo relevante reproduzir (fls. 521):

Durante a fase exploratória foram perfurados e testados nestas áreas vários poços no carbonato Albiano, a maioria deles apresentando altos teores de H₂S, embora bastante variáveis. Este fato sugeria a possibilidade de termos áreas com teores de H₂S baixos, como foi o caso de Tubarão Azul. Além desta contaminação, os testes evidenciaram baixos índices de produtividade. Entretanto, o modelo de reservatório vigente até então era de que a produtividade seria muito maior com a utilização de poços horizontais, em função do sistema de fraturas, tomando como referência o caso positivo do poço horizontal de Tubarão Azul, o 9-OGX-26HP-RJS, que também tinha apresentado baixo IP no teste de poço vertical.

Apesar da contaminação com H₂S e dos baixos índices de produtividade, ter encontrado óleo nos diversos poços perfurados levou a uma estimativa bastante elevada de volume in-place de óleo, na faixa de dois bilhões de barris, o que permitiria a viabilização de um projeto mais caro, fruto da grande extensão areal e da tecnologia e material necessários para trabalhar com H₂S.

Nesta área, os **resultados dos poços exploratórios e dos testes de formação realizados já indicavam que a compartimentação poderia ser um complicador adicional**, evidenciada por contatos óleo-água e propriedades de óleo diferentes em diversos blocos. **As primeiras análises da Área de Reservatórios, ainda em 2011, já sinalizavam volumes e compartimentação muito diferentes da interpretação inicial**. Decidiu-se então pela contratação de uma consultoria externa, no caso a Schlumberger, que aportou técnicos com experiência em reservatórios carbonáticos de todo o mundo. (grifou-se)

34. Ou seja, desde 2011 a Companhia já sabia que havia problemas em potencial relacionados aos altos teores de H₂S e baixos índices de produtividade e, em que pese tal constatação, tomou como referência o cenário positivo de um dos poços do campo de Tubarão Azul (9-OGX-26HP-RJS) para calcular uma estimativa “bastante elevada” dos volumes de óleo, apesar de os resultados dos poços exploratórios e dos testes de formação já terem indicado, conforme apontado, que a compartimentação poderia ser um complicador adicional.

35. Dessa forma, a administração tomou como base as estimativas mais positivas da área de exploração para fins de divulgação ao mercado e, tendo em vista o entendimento divergente da área de reservatórios, mais conservadora, decidiu pela contratação de uma consultoria externa, no caso a Schlumberger, tendo formado um Grupo de Trabalho, conforme já detalhado no início deste voto.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

36. Na apresentação de suas conclusões à diretoria executiva da Companhia no dia 24.09.2012, o GT apontou um volume *in situ* de 676 milhões de boe e um volume recuperável que variava entre 49,5 milhões de boe (*caso base*) a 77,7 milhões de boe (*caso otimista*). Tomando por base as informações do fato relevante de 13.05.2010, em que foi divulgado que as acumulações de *Etna* e *Pipeline*, somadas, continham entre 1,4 a 2,6 bilhões de barris de óleo recuperáveis, as estimativas de volume de óleo recuperável confirmadas pelo GT representavam diminuição nas previsões iniciais em, no mínimo, 94%.

37. Com relação a esse ponto, os Acusados alegam que à Schlumberger não teria sido dada a tarefa de averiguar os volumes de óleo *in situ* e recuperável ou de realizar uma análise econômico-financeira dos Campos, e sim propor soluções capazes de maximizar a recuperação de óleo dessas acumulações, e seus técnicos teriam apenas dado suporte às avaliações, testes e simulações realizadas pela OGX naqueles reservatórios. Nesse sentido, o GT não teria chegado a conclusões quanto aos volumes, e sim adotado como premissa o modelo elaborado pela área de reservatórios, que refletiria a pior das hipóteses.

38. Sustentam que o GT teria apresentado os resultados com base nos dados obtidos a partir dos poços com pior desempenho, com a ressalva de que seriam inconclusivos, sendo necessárias novas análises, tendo afirmado que “*se projeções não podem se basear, exclusivamente, no melhor dos resultados, de outro lado, também não é cientificamente aceitável que se descartem os bons resultados, adotando-se os piores deles*” e, por isso, a Companhia teria solicitado estudos adicionais (fls. 483).

39. Não assiste razão aos Acusados.

40. Na verdade, no documento em que são sumarizadas as conclusões do GT, é mencionada, dentre as atividades que foram realizadas, a “*elaboração do conceito de produção, estimativa de prazos, ajuste na previsão de produção, estimativas de custo e prazo e análise econômica*” (fls. 283v), o que derruba a tese defendida pelos Acusados.

41. Outros trechos do Relatório de Reavaliação de Ativos permitem afirmar que os argumentos de defesa tentam distorcer o real objetivo dos estudos conduzidos pelo grupo. Na verdade, a Companhia contratou uma consultoria especializada em carbonatos similares para, diante da divergência interna quanto à real viabilidade dos Campos, verificar, juntamente com os técnicos da OGX, se o modelo levantado pela área de reservatórios era apenas conservador e pessimista ou, se na verdade, tratava-se de um cenário realista:

Essa análise foi então realizada pela Schlumberger (...) e praticamente confirmou o modelo concebido pela Área de Reservatórios, com um volume in place total de óleo na faixa de 700 milhões de barris. Associado à redução do volume, tivemos também uma redução significativa do fato de recuperação, inicialmente estimado em 20% para algo inferior a 10%. Esse estudo resultou num volume recuperável de cerca de 80 milhões de barris no caso mais otimista, com um fator de recuperação de 12%, e de 50 milhões de barris no caso mais provável, o que representa uma recuperação de 7,3%. Nessas avaliações já se considerou o resultado do poço horizontal 9-OGX-39HP-RJS



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

perfurado na área que, diferentemente do 9-OGX-26HP-RJS em Tubarão Azul, apresentou também um baixo índice de produtividade, comprovando que, a exemplo do bloco sudoeste de Tubarão Azul, o reservatório é de baixa permeabilidade e não existe um sistema de fraturas competente para alavancar a produtividade. (grifou-se)

42. Além de ter confirmado o modelo elaborado pela área de reservatórios, o GT identificou, em três diferentes cenários de CAPEX, VPLs negativos. Dito de outra forma, ao analisar o retorno econômico para a Companhia diante do investimento em três tipos distintos de plataformas para operar os Campos (FPSO de 75 kbblpd, FPSO de 60 kbblpd e OSX-1 adaptada), verificou-se que em todas as alternativas o retorno era negativo, tanto no cenário base como no otimista.

43. Portanto, é possível afirmar que no dia 24.09.2012, a administração da OGX já possuía a informação de que o entendimento da área de reservatórios havia sido confirmado e que, portanto, a estimativa inicial, divulgada ao mercado, não mais se mantinha e deveria ser alterada, confirmando, desde então, a existência de uma informação relevante ainda não divulgada ao mercado.

44. Os Acusados sustentam que nesse momento não haveria certeza ainda quanto à inviabilidade dos Campos, com base nas seguintes premissas: (a) a recomendação do GT para que fossem tomadas diversas ações para determinar a real situação dos Campos, cabendo destacar o comportamento do terceiro poço de Tubarão Azul; (b) as divergências entre técnicos das áreas de exploração e de reservatórios (a diretoria de exploração possuía uma visão muito diferente em relação aos cenários utilizados no *power point* apresentado na reunião de 24.09.2012), o que demonstraria que a OGX não estava preparada para uma tomada de decisão sobre esses ativos; (c) a continuidade do trabalho da RATE e os demais estudos posteriormente realizados; (d) a declaração de comercialidade enviada à ANP em março de 2013; e (e) o fato de, em setembro de 2012, o conselho de administração da OSX ter decidido pela manutenção da construção do OSX-2.

45. Quanto a esses argumentos, inicialmente cabe ressaltar que o fato de o GT ter recomendado ações adicionais não prejudica a conclusão de que a administração tinha conhecimento de que as estimativas feitas pela área de exploração não mais se sustentavam. Diante da confirmação das estimativas chamadas de pessimistas, o trabalho seguinte seria aprofundar estudos e fazer testes de modo a tentar encontrar alternativas que pudessem tornar a exploração viável diante das dificuldades encontradas.

46. Nesse mesmo sentido foi a contratação da análise da RATE e demais estudos posteriores, vistos mais como uma tentativa de reduzir prejuízos, e não como uma prova de que as condições ruins não haviam sido confirmadas.

47. A decisão pela não interrupção da construção do OSX-2 e pelo envio da declaração de comercialidade dos Campos enviada à ANP em março de 2013, assim como outros atos



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

ordinários das atividades de uma Companhia de exploração de petróleo, da mesma forma, não são capazes de demonstrar que a Companhia acreditava que a exploração econômica dos Campos era plenamente possível da forma como inicialmente prevista.

48. Ao longo de 2012, a visão chamada de pessimista dos engenheiros de reservatórios foi sendo confirmada, mas ainda assim a Companhia tentava achar uma alternativa que tornasse viável a exploração. Em março de 2013, com o estudo da RATE e as novas sísmicas, já se tinha certeza de que não era economicamente viável a exploração, mas a Companhia decidiu postergar a divulgação deste fato até julho de 2013.

49. Neste particular, a própria Companhia afirmou no Relatório de Reavaliação de Ativos (2013) que *“as comercialidades destas áreas foram declaradas com a perspectiva de até setembro deste ano se apresentar uma proposta para a ANP de postergação do desenvolvimento das mesmas, com o objetivo de se encontrar alguma solução tecnológica mais barata”* (fls. 301).

50. Ou seja, a essa altura a administração já estava ciente de que o desenvolvimento não era possível, e mesmo assim declarou a comercialidade a fim de postergar a suspensão do desenvolvimento dos Campos, tendo optado por reter informação de extrema relevância e impacto direto na decisão de investimento que, quando finalmente divulgada e refletida nas demonstrações financeiras, reverteu dramaticamente o desempenho da Companhia.

51. E nesse contexto, assiste razão à Acusação ao afirmar que os dados oriundos da análise do GT já indicavam, no mínimo, a necessidade de divulgação, em notas explicativas, das incertezas relevantes quanto à viabilidade econômica da exploração dos Campos. Ainda que a administração não tivesse absoluta certeza com relação ao montante equivalente à perda por redução ao valor recuperável dos ativos, pois alega que naquele momento *“inexistia um conjunto de informações sólidas e reais apto a alterá-las [se referindo às demonstrações financeiras]”* (fls. 459), havia, por certo, a obrigação de informar acerca das incertezas existentes.

52. Com efeito, o CPC 00 (R1) – *Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro* (“CPC00 (R1)”), dispõe, no item 4.43, *in verbis*:

“4.43. Um item que possui as **características essenciais de elemento, mas não atende aos critérios para reconhecimento pode, contudo, requerer sua divulgação em notas explicativas**, em material explicativo ou em quadros suplementares. Isso é **apropriado quando a divulgação do item for considerada relevante para a avaliação da posição patrimonial e financeira**, do desempenho e das mutações na posição financeira da entidade por parte dos usuários das demonstrações contábeis” (grifou-se).

53. Da mesma forma dispõe o CPC 26 (R1) – *Apresentação das Demonstrações Contábeis* (“CPC26 (R1)”), que nos itens 125¹⁶ e 129¹⁷ estabelece que a entidade deve divulgar

¹⁶ 125. *A entidade deve divulgar, nas notas explicativas, informação acerca dos pressupostos relativos ao futuro e outras fontes principais de incerteza nas estimativas ao término do período de reporte que possuam risco significativo de provocar ajuste material nos valores contábeis de ativos e passivos ao longo do*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

em notas explicativas fontes de incerteza nas estimativas que possuam risco significativo de provocar ajuste material nos valores contábeis de ativos e passivos, com a finalidade de ajudar os “usuários das demonstrações contábeis a compreender os julgamentos que a administração fez acerca do futuro e sobre outras principais fontes de incerteza das estimativas”.

54. O item 131¹⁸ vai além e prevê que em situações em que não seja possível divulgar a extensão dos possíveis efeitos de um “pressuposto ou de outra fonte principal de incerteza”, a entidade deve divulgar “que é razoavelmente possível, com base no conhecimento existente, que os valores dos respectivos ativos ou passivos ao longo do próximo exercício social tenham que sofrer ajustes materiais em função da observação de uma realidade distinta em relação àqueles pressupostos assumidos”.

55. Portanto, não resta dúvida de que naquele momento, pelo menos a partir da ciência dos resultados trazidos pelo GT, a administração da OGX estava diante de uma fonte de incerteza, pois se havia dúvidas quanto à extensão do problema, por outro lado havia plena certeza de que os ativos teriam que sofrer ajustes com relação às premissas inicialmente adotadas, o que é suficiente para que a informação seja divulgada em notas explicativas, em linha com os preceitos dos CPCs citados.

56. Embora em sua manifestação preliminar Roberto Monteiro, diretor financeiro à época, tenha afirmado que o reconhecimento contábil da perda do ativo dependeria da realização dos testes pedidos pelo GT, na forma como estabelece a seção 932 do US-GAAP¹⁹ de “*Extractive Activities – Oil and Gas*”, não indicou qual dispositivo da norma americana trazida

próximo exercício social. Com respeito a esses ativos e passivos, as notas explicativas devem incluir detalhes elucidativos acerca:

(a) da sua natureza; e

(b) do seu valor contábil ao término do período de reporte. (grifou-se)

¹⁷ 129. As divulgações descritas no item 125 devem ser apresentadas de forma a ajudar os usuários das demonstrações contábeis a compreender os julgamentos que a administração fez acerca do futuro e sobre outras principais fontes de incerteza das estimativas. A natureza e a extensão da informação a ser divulgada variam de acordo com a natureza dos pressupostos e outras circunstâncias. Exemplos desses tipos de divulgação são os que seguem:

(a) a natureza dos pressupostos ou de outras incertezas nas estimativas;

(b);

(c) a solução esperada de incerteza e a variedade de desfechos razoavelmente possíveis ao longo do próximo exercício social em relação aos valores contábeis dos ativos e passivos impactados; e

(d) (grifou-se).

¹⁸ 131. Por vezes, é impraticável divulgar a extensão dos possíveis efeitos de um pressuposto ou de outra fonte principal de incerteza das estimativas ao término do período de reporte. Nessas circunstâncias, a entidade deve divulgar que é razoavelmente possível, com base no conhecimento existente, que os valores dos respectivos ativos ou passivos ao longo do próximo exercício social tenham que sofrer ajustes materiais em função da observação de uma realidade distinta em relação àqueles pressupostos assumidos. Em todos os casos, a entidade deve divulgar a natureza e o valor contábil do ativo ou passivo específico (ou classe de ativos ou passivos) afetado por esses pressupostos. (grifou-se)

¹⁹ Generally Accepted Accounting Principles (United States).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

indicaria a necessidade de aguardar os testes e, ainda que existisse tal previsão supostamente em contradição às regras do CPC00 (R1), prevaleceria o disposto na norma contábil brasileira.

57. Ainda que as defesas aleguem que em setembro de 2012 não havia certeza quanto às perdas decorrentes dos resultados do estudo do GT, o mesmo não se pode afirmar quanto à situação existente em março de 2013, quando a inviabilidade já havia sido confirmada tanto pelo relatório da RATE como pelas novas sísmicas realizadas.

58. Naquele momento, a administração já possuía uma visão mais acurada da situação dos Campos, o que permite concluir que a partir da divulgação das demonstrações financeiras do exercício findo em 2012, divulgadas em 26.03.2013 (“DF/2012”), a Companhia já dispunha de elementos suficientes para divulgar a informação e reconhecer a perda por redução ao valor recuperável dos ativos.

59. Conforme definido no CPC00 (R1), ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade. A característica mais importante de um ativo é que deve ser evidenciada é, portanto, sua capacidade de gerar benefícios futuros para a sociedade que o controla; caso ocorra perda, parcial ou total, desta capacidade, o ativo sofreu uma redução, em inglês *impairment*, que necessariamente deve ser reconhecido no resultado do exercício contábil.

60. A matéria é tratada no Pronunciamento Técnico CPC 01 (R1) – *Redução ao Valor Recuperável de Ativos* (“CPC 01 (R1)”), que tem por objetivo “*estabelecer procedimentos que a entidade deve aplicar para assegurar que seus ativos estejam registrados contabilmente por valor que não exceda seus valores de recuperação*”.

61. O item 12 do referido pronunciamento dispõe que a entidade deve “*avaliar se há alguma indicação de que um ativo possa ter sofrido desvalorização*”, devendo para isso considerar, no mínimo, indicações fornecidas por fontes externas ou internas e, dentre estas últimas, a alínea ‘g’ cita “*evidência disponível, proveniente de relatório interno, que indique que o desempenho econômico de um ativo é ou será pior que o esperado*” (grifou-se).

62. Como se vê, a previsão da alínea transcrita enquadra-se na hipótese dos autos em que havia farta evidência, ao menos em 26.03.2013, data da publicação das DF/2012, a indicar que o desempenho econômico dos Campos havia sido substancialmente reduzido.

63. A OGX, no item “i”, “Redução ao valor recuperável”, das DF/2012, menciona que “[e]specificamente em relação aos ativos relacionados às atividades de exploração de petróleo e gás, a Companhia considera alguns fatores como indicativos de que um ativo não é recuperável, como por exemplo (...) os hidrocarbonetos encontrados não são suficientes para constituírem uma reserva, ou seja, não são recuperáveis dadas as atuais condições econômicas e tecnológicas.” (fls. 712).

64. No mesmo item, a Companhia informou que “*efetua anualmente um teste específico de análise de indicativos de impairment que consiste em comparar o valor presente do fluxo de*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

caixa futuro estimado, com o valor contábil”, sendo uma das premissas utilizadas para esse cálculo o volume de produção estimado.

65. O item 8 do CPC 01 (R1) estabelece, ainda, que se houver qualquer indício de possível desvalorização do ativo, o que se verifica caso existente algum indicativo oriundo de fontes externas ou internas, a entidade deve fazer uma estimativa formal do valor recuperável.

66. Diante desses elementos, vê-se que a administração falhou ao ter deixado de realizar o *impairment*, pois, seja pelos critérios fixados no CPC 01 (R1), seja pelas premissas da Companhia, em qualquer dos casos havia uma sinalização no sentido de que o valor dos ativos registrados na contabilidade não mais representavam fidedignamente a situação financeira e patrimonial da OGX em março de 2013 (até mesmo antes, em setembro de 2012, como já mencionado), momento em que o valor contábil excedia consideravelmente o valor recuperável dos ativos imobilizados.

67. O mesmo cenário se repetiu nas informações financeiras trimestrais referentes ao 1º trimestre de 2013, entregues em 09.05.2013, em que a Companhia informa que *“exceto pelos poços secos/subcomerciais já baixados, a Companhia não identificou indicativos de impairment associados aos ativos de exploração e produção”*.

68. Sobre a necessidade de ampla divulgação de informações, Eizirik²⁰ comenta que para os acionistas de companhias abertas, *“a transparência das informações financeiras reduz o risco de atuação incompetente ou desonesta dos administradores, assim como de utilização de informações privilegiadas”*. Afirma que, para os credores, o *disclosure* também seria essencial, pois lhes *“possibilita melhor avaliar o risco de negociar com uma entidade cuja única garantia é o seu próprio patrimônio”*, sendo relevante também para o mercado, pois permitiria uma melhor precificação dos títulos emitidos.

69. A relevância da veracidade e transparência das demonstrações financeiras também restou consignada no voto proferido pela então diretora Norma Jonssen Parente no julgamento do PAS CVM nº 17/01, realizado em 16.10.2003, do qual extraio o seguinte trecho:

De outro lado, os balanços representam um instrumento de proteção dos acionistas e de terceiros. São praticamente o único meio do qual dispõem para acompanhar o desenvolvimento da sociedade e conhecer sua situação econômico-financeira.

Dessa forma a transparência informativa é o pilar básico sobre o qual os investidores assentam suas decisões, já que sem uma contabilidade regular, que de certo modo permita prever os futuros resultados da atividade empresária, não é possível dar passos seguros no terreno movediço dos negócios.

Assim é imprescindível que as empresas elaborem demonstrações financeiras capazes de informar de forma correta, consoante normas contábeis convencionalmente aceitas, sob pena de induzir a erro o seu leitor.

²⁰ EIZIRIK, Nelson. A Lei das S.A. Comentada. Volume II - Arts. 121 a 188. São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 385-386.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

70. Em relação à necessidade de *impairment*, Eike Batista alegou que registrar uma perda nos ativos relacionados aos referidos Campos, baseando-se no cenário pessimista do GT para depois, eventualmente, reverter-la ao constatar-se sua viabilidade comercial, desestabilizaria o mercado.

71. O argumento não merece prosperar. Em primeiro lugar, ainda que a Companhia acreditasse que a viabilidade dos Campos fosse possível, deveria ter observado a regra do *full disclosure* e ter informado aos investidores os entraves encontrados para sua exploração, esclarecendo que estudos estavam sendo conduzidos para tentar encontrar um projeto viável.

72. Em segundo lugar, como já foi analisado no início deste voto, o GT analisou os aspectos técnicos e econômicos do projeto exploratório da Companhia e concluiu que a concepção inicialmente idealizada não mais se sustentava, tendo afirmado que as condições reais dos Campos se assemelhavam àquelas apontadas pela área de reservatórios já em 2011. Isso em nada se assemelha a adotar um “*cenário pessimista do GT*”, como quer fazer crer a defesa, tratando-se, na verdade, de números reais corroborados por técnicos especializados.

73. Na verdade, a administração, ao criar uma situação de extrema assimetria informacional, em que investidores tomaram decisões de comprar ou vender as ações de emissão da OGX com base em dados incorretos e inverídicos, é que levou a uma desestabilização do mercado e trouxe um clima de desconfiança com relação ao sistema como um todo. Além do mais, a desvalorização de que trata este voto é relacionada aos ativos de maior valor da Companhia, tanto é assim que a descoberta da inviabilidade dos Campos levou a OGX a apresentar pedido de recuperação judicial, além de ter tido grande contribuição no declínio do chamado “Grupo X”.

74. Verifica-se, portanto, que já havia informações suficientes para concluir que o valor dos ativos em questão não era mais aquele informado inicialmente e, não estando a administração confortável em reconhecer as perdas ainda em 2012, como alegam os Acusados, o mínimo exigido era que a informação fosse divulgada nas notas explicativas por serem de extrema relevância para a “avaliação da posição patrimonial e financeira da entidade”.

III.2.1 Interesse legítimo da Companhia

75. Como já tive oportunidade de destacar ao analisar o PAS CVM RJ2014/12710²¹, prevalece no nosso ordenamento jurídico o princípio do *full disclosure*, segundo o qual as companhias emissoras são obrigadas a dar total publicidade de atos e fatos que possam influir de

²¹ Processo julgado em sessão realizada em 05.12.2017, em que se apurou eventual responsabilidade de Gelson da Silva Batista, na qualidade de diretor de relações com investidores e diretor presidente da CCX Carvão da Colômbia S.A., pelo suposto descumprimento ao parágrafo único do art. 6º da Instrução CVM nº 358/02 c/c o art. 157, §4º, da Lei nº 6.404/76 e art. 3º, caput e §5º, da Instrução CVM nº 358/02.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

modo ponderável na cotação de valores mobiliários e/ou na decisão dos investidores de negociar ou exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titulares de tais ativos.

76. Considerando que os investidores são livres para tomar suas decisões de investimento, a lógica do sistema consiste no fornecimento de todas as informações relevantes e disponíveis pela companhia, a fim de propiciar uma tomada de decisão bem informada, o que contribui para promover a integridade e a eficiência do mercado de capitais, na medida em que os preços negociados irão refletir exatamente as legítimas expectativas dos investidores.

77. Tal dever de informar dos administradores de companhias abertas está previsto no art. 157 da Lei nº 6.404/76, cabendo ressaltar o disposto nos parágrafos 4º e 5º, a seguir transcritos:

Art. 157. (...)

§4º Os administradores da companhia aberta são obrigados a comunicar imediatamente à bolsa de valores e a divulgar pela imprensa qualquer deliberação da assembléia-geral ou dos órgãos de administração da companhia, ou fato relevante ocorrido nos seus negócios, que possa influir, de modo ponderável, na decisão dos investidores do mercado de vender ou comprar valores mobiliários emitidos pela companhia.

§ 5º Os administradores poderão recusar-se a prestar a informação (§ 1º, alínea e), ou deixar de divulgá-la (§ 4º), se entenderem que sua revelação porá em risco interesse legítimo da companhia, cabendo à Comissão de Valores Mobiliários, a pedido dos administradores, de qualquer acionista, ou por iniciativa própria, decidir sobre a prestação de informação e responsabilizar os administradores, se for o caso. (...) (grifou-se)

78. A matéria é regulada pela Instrução CVM nº 358/02 que, além de trazer uma definição do que seria relevante para fins da instrução e listar alguns exemplos de atos ou fatos potencialmente relevantes, prevê a obrigação de divulgação de qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos negócios da companhia.

79. Não obstante, a norma faculta aos administradores ou controladores deixarem de divulgar, excepcionalmente, os atos ou fatos relevantes, caso entendam que sua revelação porá em risco “interesse legítimo da companhia”. Entretanto, essa faculdade cessa quando a informação escapar ao controle ou ocorrer oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos valores mobiliários, nos termos do art. 6º da Instrução CVM nº 358/02²², hipótese na qual deverá o fato relevante deverá ser divulgado imediatamente.

²² Art. 6º Ressalvado o disposto no parágrafo único, os atos ou fatos relevantes podem, excepcionalmente, deixar de ser divulgados se os acionistas controladores ou os administradores entenderem que sua revelação porá em risco interesse legítimo da companhia. Parágrafo único. As pessoas mencionadas no caput ficam obrigadas a, diretamente ou através do Diretor de Relações com Investidores, divulgar imediatamente o ato ou fato relevante, na hipótese da



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

80. Voltando ao caso dos autos, os Acusados sustentam que a inclusão de notas explicativas sobre as incertezas relacionadas à viabilidade econômica dos campos de Tubarão Tigre, Areia e Gato no 3º ITR/12, DF/2012 e 1º ITR/13 colocaria em risco interesse legítimo da OGX, uma vez que desqualificaria o projeto de exploração em curso antes mesmo de serem obtidos os resultados definitivos dos estudos e projeções que ocorriam em paralelo.

81. A norma não define exatamente o que é interesse legítimo, deixando o conceito aberto para que a própria administração, diante do caso concreto, defina a sua aplicabilidade. Ao analisar os precedentes desta casa, vê-se que, ainda que a definição do termo “interesse legítimo” não fosse a questão central objeto da análise, em alguns julgados foram fixados parâmetros considerados válidos para que a administração deixasse de divulgar a informação.

82. Ao proferir voto no PAS CVM nº RJ2006/4776, em 17.01.2007, o diretor relator Pedro Marcílio destacou que deve haver um “*legítimo propósito empresarial na manutenção do sigilo*”, não se enquadrando no conceito a ausência de divulgação em decorrência do impacto negativo no preço das ações da Companhia:

56. Assim, se a divulgação de uma informação que deveria ser tornada pública, de acordo com as regras de divulgação de informação, pode impedir a conclusão de um negócio, a conquista de um cliente ou o desenvolvimento de um produto ou serviço ou pode prejudicar legítimos interesses negociais da companhia, a companhia poderá, de acordo com a legislação específica, deixar de divulgar a informação.

57. Isso não significa que as companhias podem deixar de prestar informações simplesmente porque acreditam que seus negócios podem ser prejudicados pela divulgação. É preciso que haja um **legítimo propósito empresarial na manutenção do sigilo**. Assim, por exemplo, um negócio em que se beneficie um acionista específico **não pode deixar de ser divulgado porque essa informação impactaria negativamente o preço das ações da companhia**, aumentando o seu custo de captação.

58. Mesmo com relação a negócios legítimos e desinteressados, essa exceção à divulgação não é absoluta, pois, de acordo com o parágrafo único do art. 6º da Instrução 358/02, é obrigatório “divulgar imediatamente o ato ou fato relevante, na hipótese da informação escapar ao controle ou se ocorrer oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos valores mobiliários de emissão da companhia aberta ou a eles referenciados”.

83. A diretora Luciana Dias, em seu voto proferido no PAS CVM nº RJ2013/2400²³ acrescentou que “*as operações não concluídas, ainda em negociação, são os exemplos mais típicos em que a divulgação pode gerar prejuízos à companhia. Nesse sentido, as negociações sobre novos contratos ou reorganizações societárias podem e devem ser mantidas em sigilo se a*

informação escapar ao controle ou se ocorrer oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos valores mobiliários de emissão da companhia aberta ou a eles referenciados.

²³ PAS julgado em 18 de março de 2015.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

divulgação das tratativas puder pôr em risco o fechamento dos contratos ou mesmo puder prejudicar a negociação de seus termos”.

84. Da mesma forma, Alfredo Lamy Filho e Bulhões Pedreira afirmam que essa previsão do §5º do art. 157, presente na maior parte das legislações desenvolvidas, é uma cláusula de proteção que tem como objetivo equilibrar o direito à informação dos acionistas ao invés de tratá-lo de forma absoluta, citando como causas legítimas para a não divulgação possíveis prejuízos a terceiros, podendo implicar inclusive responsabilidade para a companhia, como por exemplo a divulgação de contratos confidenciais, além de situações envolvendo “*os interesses da confiança, o good will, o segredo profissional, as normas reguladoras e de salvaguarda da concorrência, o segredo industrial*” dentre outros, cuja legitimidade para recusa deve ser apreciada no caso concreto²⁴.

85. Na hipótese vertente, vê-se que a informação relevante não divulgada referia-se, em um primeiro momento, a uma grande mudança nas estimativas de volume recuperável inicialmente divulgadas e, um pouco mais adiante, à inviabilidade dos Campos detidos pela Companhia. Portanto, não se trata de informação de cunho concorrencial ou cuja revelação poderia atrapalhar interesses da Companhia em concluir um negócio específico ou o desenvolvimento de um produto.

86. Pelo contrário, tratava-se, como já ressaltado anteriormente neste voto, de informação de suma importância para a Companhia e para a continuidade de suas atividades, não sendo legítima a retenção da informação por receio dos efeitos no preço do papel, até porque, na grande maioria dos casos, a divulgação de um fato relevante tem esse poder, uma vez que tem potencial para afetar a decisão de compra ou venda dos valores mobiliários de emissão daquela companhia.

87. Além disso, soam contraditórias as alegações dos Acusados no sentido de que existiria legítimo interesse da Companhia a ser preservado enquanto tais estudos estavam sendo desenvolvidos, sendo que o administrador que divulgasse ao mercado informações suspeitas sem a necessária análise criteriosa instauraria “*uma situação absolutamente inadmissível*”.

88. Por um lado, a administração decide revelar estimativas otimistas a partir de 2010, com base em estudos preliminares, ainda que não tivesse certeza absoluta do real valor das reservas e diante de uma divergência interna quanto aos números, levando os investidores a acreditarem que aqueles números eram possíveis e bem prováveis. Por outro, diante de um cenário negativo para a OGX, quando as incertezas começam a se confirmar após o recebimento das conclusões do Grupo de Trabalho, informando que a situação inicial havia sido substancialmente modificada, a administração decide não revelar os números negativos pois

²⁴ LAMY FILHO, Alfredo e BULHÕES PEDREIRA, José Luiz (coord.), Direito das Companhias, Rio de Janeiro: Forense, 2017, 2ª edição, p. 856.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

afetaria “interesse legítimo” da Companhia. Exsurge evidente, no mínimo, falta de coerência por parte dos executivos.

89. Em verdade, o interesse legítimo a ser tutelado é o do investidor em obter informações verdadeiras, completas, consistentes e que não o induzam a erro, não sendo dado a administração de uma companhia aberta apresentar informações financeiras incorretas ou incompletas a fim de não revelar a depreciação de seus ativos. Para as companhias abertas, que escolheram captar poupança pública no âmbito do mercado de capitais, prevalece a regra da publicidade e transparência de suas informações.

90. Em casos que tais, no momento da divulgação das demonstrações financeiras, as informações relevantes que forem do conhecimento da administração e que puderem ser identificadas como de risco significativo de provocar ajuste material imediato nos valores contábeis de ativos da Companhia, devem necessariamente ser contempladas nas notas explicativas, não se aplicando a hipótese de sigilo que faculta, em tese, aos administradores deixar de divulgar a informação caso entendam que sua revelação porá em risco interesse legítimo da companhia.

91. Portanto, restou caracterizada a infração, por parte da administração da OGX, ao, tendo conhecimento das fundadas incertezas relacionadas à viabilidade econômica da exploração dos Campos, fazer elaborar demonstrações financeiras omitindo informações de extrema relevância para a compreensão da situação financeira e patrimonial da Companhia, em inobservância ao disposto no item 4.43 do Pronunciamento Técnico CPC 00 (R1) e nos itens 125, 129 e 131 do Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1).

III.3 AUTORIA DO DELITO

III.3.1 DA RESPONSABILIDADE DO DIRETOR ROBERTO MONTEIRO

92. Como visto no relatório, a Acusação propôs a responsabilização de todos os integrantes da diretoria estatutária da Companhia pelas irregularidades apontadas nas demonstrações financeiras em questão. Com relação a Roberto Monteiro, diretor financeiro e de relações com investidores da OGX à época dos fatos, não resta dúvidas de que fazia parte de suas atribuições preparar as demonstrações financeiras, sendo o responsável pela contabilidade da Companhia com relação ao atendimento das determinações legais, conforme previsão estatutária:

Art. 14 (...) (e) Cabe ao Diretor Financeiro: (...) (ix) preparar as demonstrações financeiras da Companhia; (x) responsabilizar-se pela contabilidade da Companhia para atendimento das determinações legais; e (xi) exercer outras funções ou atribuições que lhe forem, de tempos em tempos, determinadas pelo Diretor Presidente;

93. Assim, a ele cabia, além de fazer elaborar todas as informações financeiras da OGX, zelar para que atendessem às normas aplicáveis, empregando todo o cuidado e diligência para



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

que o documento revelasse a verdadeira situação da Companhia aos usuários das demonstrações contábeis, devendo divulgar fontes de incerteza que constituíssem risco significativo de provocar ajuste material nos valores contábeis, conforme estabelece o CPC 26 (R1).

94. Isso porque a inclusão dessas incertezas nas demonstrações, além de colocar os investidores a par das alterações ocorridas com relação os números inicialmente divulgados, e de possíveis ajustes nos ativos da OGX, permitiria que o destinatário entendesse “os julgamentos que a administração fez acerca do futuro e sobre outras principais fontes de incerteza das estimativas”²⁵. E nada disso se verifica no caso concreto.

95. Em sua defesa, o acusado alega a ausência de má-fé, pois teria atuado de forma diligente e de boa-fé, visando à consecução do objeto social e ao atendimento dos interesses da Companhia. Nesse sentido, e considerando que o administrador possui poder discricionário na condução dos negócios da Companhia e que a *business judgment rule* confere proteção ao administrador que age de boa-fé e no interesse da sociedade, o acusado não poderia ser responsabilizado pela irregularidade em questão.

96. Os argumentos trazidos pelo Acusado não merecem prosperar.

97. Inicialmente, convém ressaltar que a comprovação de má-fé não é requisito para a configuração da irregularidade aqui apreciada, bastando a comprovação do descumprimento dos preceitos contidos nos dispositivos, conforme indicados pela Acusação. Ademais, o padrão de revisão de conduta da *business judgment rule* tem como um dos requisitos para sua aplicação a existência de uma decisão negocial, o que não se vislumbra no caso concreto.

98. Como afirmado pela ex-diretora Luciana Dias²⁶, “a doutrina da decisão negocial não diz respeito a toda e qualquer decisão da administração de uma companhia, mas volta-se a decisões de cunho negocial e afasta decisões relacionadas a questões organizacionais, ou ao mero cumprimento de obrigações impostas pela regulamentação ou pelo estatuto da companhia”.

99. Com efeito, a decisão de divulgar ou não um fato relevante ou, para melhor adequar ao que aqui se analisa, ajustar ou não as demonstrações financeiras de forma a refletir informação de extrema relevância para a Companhia e para o mercado e, mais importante, exigida por lei e pela regulamentação, em nada se assemelha a uma decisão negocial. Trata-se de cumprimento de uma determinação legal, não cabendo ao administrador, como já afirmado, juízo de valor acerca da divulgação.

100. Quanto ao argumento de que as demonstrações não estariam eivadas de quaisquer irregularidades, pois foram preparadas pelos contadores da Companhia e submetidas aos auditores independentes, que não fizeram qualquer observação, tenho que esse fato não é

²⁵ Nos termos do CPC 26(R1).

²⁶ Nos termos do voto proferido em 21.07.2015, no âmbito do PAS CVM nº 09/2009.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

suficiente para elidir a responsabilidade dos administradores, conforme já decidido por esta Comissão²⁷.

101. Na verdade, a existência de ressalvas pode constituir sinal ou indício de irregularidade contábil, entretanto sua ausência não tem o condão de afastar o dever do administrador de agir de forma diligente, não os isentando dos deveres de se informar, investigar e vigiar.

102. Nesse sentido, ao fazer elaborar as demonstrações financeiras da OGX de 31.12.2012 e os ITRs referentes aos períodos encerrados em 30.09.2012 e 31.03.2013 omitindo informações relevantes para uma correta avaliação da situação financeira e patrimonial da Companhia, em desacordo com as normas contábeis citadas neste voto, Roberto Monteiro não agiu com a devida diligência, tendo violado suas obrigações estatutárias e a lei societária (153, 176 c/c 177, §3º), assim como os arts. 14²⁸, 26²⁹ e 29³⁰ da Instrução CVM nº 480/09.

III.3.2 DA RESPONSABILIDADE DO DIRETOR LUIZ CARNEIRO

103. Luiz Carneiro exerceu o cargo de diretor presidente da OGX de junho de 2012 a outubro de 2013, exatamente durante o período em que os estudos relativos aos Campos foram conduzidos e chegou-se à conclusão que eram inviáveis economicamente.

104. Inicialmente, cabe ressaltar que o diretor presidente exerce cargo de extrema importância dentro de uma companhia e espera-se que alguém que exerça tal função esteja ciente, ainda que sem grande aprofundamento em todos os casos, de todas as questões relevantes que estejam em andamento, especialmente aquelas de cunho estratégico, que possam impactar diretamente a continuidade dos negócios da companhia ou a sua sustentabilidade financeira.

105. Nesse sentido, entendo oportuno citar trecho do voto do então diretor Gustavo Borba que, ao abordar o assunto, fez as seguintes ponderações, com as quais me filio³¹:

Gostaria de ressaltar, contudo, em relação ao Diretor Presidente, que embora não fosse sua atribuição estatutária fazer elaborar as demonstrações financeiras (que foi a acusação contra ele formulada), poder-se-ia cogitar, diante das

²⁷ PAS CVM nº RJ2014/2426, julgado em 12.07.2018; PAS CVM nº 18/08, julgado em 14.12.2010.

²⁸ Art. 14. O emissor deve divulgar informações verdadeiras, completas, consistentes e que não induzam o investidor a erro.

²⁹ Art. 26. As demonstrações financeiras de emissores nacionais devem ser:

I – elaboradas de acordo com a Lei nº 6.404, de 1976 e as normas da CVM; e

II – auditadas por auditor independente registrado na CVM.

³⁰ Art. 29. Ao final de cada trimestre, a diretoria fará elaborar o formulário de informações trimestrais – ITR, documento eletrônico que deve ser:

I – preenchido com os dados das informações contábeis trimestrais elaboradas de acordo com as regras contábeis aplicáveis ao emissor, nos termos dos arts. 25 a 27 da presente Instrução; e

II – entregue pelo emissor no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contados da data de encerramento de cada trimestre.

³¹ Voto proferido no âmbito do PAS CVM nº RJ2014/7072, julgado em 27.03.2018.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

atribuições mais panorâmicas de qualquer Presidente de companhia, de eventual violação ao dever fiduciário de se aprofundar na análise e na discussão das relevantes questões contábeis que foram objeto de ressalva pelo auditor independente.

106. A própria defesa comenta que por conta das divergências entre duas áreas da Companhia sobre a estimativa de volume de óleo recuperável nos Campos, foi proposta uma reestruturação da administração tendo, inicialmente, P.M. assumido o cargo de diretor presidente no lugar de Eike Batista e, em junho de 2012, o acusado assumiu a presidência. Sobre esse momento, a defesa destaca:

(...) imediatamente após ser empossado, [Luiz Carneiro] promoveu uma importante mudança na OGX, ao transferir a área de reservatórios, que se reportava anteriormente ao Diretor de Exploração, para a própria Presidência da Companhia (...).

(...)

A primeira tarefa que o Sr. Luiz Carneiro designou ao novo gerente executivo de reservatórios foi a avaliação criteriosa de alguns *assets* da Companhia, o que gerou o relatório ‘Valoração dos Ativos Bacias de Campos e Parnaíba’ de julho de 2012, o qual questionava alguns dados considerados até então como verdadeiros, inclusive aqueles resultantes do workshop.

De posse desse relatório, o Sr. Luiz Carneiro convocou a nova Diretoria da OGX e deu ciência do seu resultado a todos os seus membros, tendo recomendado a criação de um grupo de trabalho com o objetivo de ‘avaliação de oportunidade de desenvolvimento da produção das acumulações de *Pipeline*, *Fuji*, *Illimani* e *Osorno*’, sugestão aprovada por unanimidade.

107. Entendo particularmente importante ressaltar esses pontos trazidos pela defesa porque demonstram que acusado estava não só administrando os ativos e investigando possíveis problemas que pudessem afetar as atividades da OGX, no âmbito de suas funções de administrar e gerir os negócios da Companhia; mais do que isso, Luiz Carneiro estava diretamente envolvido e à frente dos esforços envolvendo as questões relativas às divergências técnicas relativas aos Campos e às possíveis alternativas para tentar solucionar o problema.

108. Tanto foi assim que o acusado imediatamente alterou a estrutura para que a área de reservatórios, a mais conservadora quanto às estimativas, passasse a responder diretamente a ele, a demonstrar, primeiro, que havia indícios de possível distorção das avaliações e reportes quando a referida área era subordinada à diretoria de exploração; e, segundo, que o seu ingresso na OGX estava intimamente ligado às questões envolvendo a exploração dos Campos, ativos extremamente valiosos para a Companhia, competindo a ele, portanto, acompanhar de perto as análises e os estudos conduzidos.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

109. Neste sentido, não há dúvidas de que o acusado acompanhava os estudos e seus resultados, ações esperadas à luz de suas atribuições estatutárias³², e participava ativamente das decisões ligadas à matéria. Seguindo esse raciocínio, esperava-se de um administrador minimamente diligente que, diante das conclusões do GT e, mais tarde, com os resultados das análises da RATE e as sísmicas adicionais, tomasse as providências necessárias para assegurar que essa mudança de cenário – em que os dados inicialmente divulgados, extremamente otimistas, deram lugar a números bem mais modestos (set/12) e, posteriormente, à declaração de inviabilidade – fosse divulgada ao mercado, assim como refletida nas informações financeiras da OGX.

110. Como ressalta Flávia Parente, ao analisar o dever de diligência dos administradores³³:

(...) o dever de investigar impõe aos administradores a obrigação de analisarem criticamente as informações que lhes foram fornecidas a fim de detectar potenciais problemas que possam vir a afetar as atividades desenvolvidas pela companhia”.

(...)

Ou seja, o dever de investigar obriga os administradores não apenas a examinarem se as informações disponíveis são suficientes ou se devem ser complementadas, como também lhes impõem o dever de averiguar se os fatos ou informações de que tenham conhecimento possam causar algum prejuízo à sociedade, hipótese em que deverão tomar as providências necessárias para evita-lo.

111. Portanto, resta claro que o acusado, na qualidade de diretor presidente da OGX, ao não ter adotado as providências necessárias para que nas demonstrações financeiras da OGX de

³² Nos termos do Estatuto Social da OGX (aprovado em assembleia geral ordinária e extraordinária em 26.04.2012): “Artigo 14 - A Diretoria é composta de, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 9 (nove) membros, acionistas ou não, todos residentes no país, eleitos pelo Conselho de Administração da Companhia, dos quais poderão ser designados um Diretor-Presidente, um Diretor Geral, um Diretor de Exploração, um Diretor de Produção, um Diretor Financeiro, um Diretor de Relações com Investidores, um Diretor Jurídico, e os demais Diretores terão a designação indicada pelo Conselho de Administração à época de sua eleição. Os Diretores da Companhia terão as seguintes atribuições: (a) Cabe ao Diretor Presidente administrar e gerir os negócios da Companhia, especialmente: (i) fazer com que sejam observados o presente Estatuto Social e as deliberações do Conselho de Administração e da Assembleia Geral; (ii) submeter, anualmente, à apreciação do Conselho de Administração, o Relatório da Administração e as contas da Diretoria, juntamente com o relatório dos auditores independentes, bem como a proposta para alocação dos lucros auferidos no exercício fiscal precedente; (iii) elaborar e propor, para o Conselho de Administração, o orçamento anual e plurianual, os planos estratégicos, projetos de expansão e programas de investimento; e (iv) conduzir e coordenar as atividades dos Diretores no âmbito dos deveres e atribuições estabelecidos para os respectivos Diretores pelo Conselho de Administração e pelo presente Estatuto Social, convocando e presidindo as reuniões da Diretoria;” (grifou-se)

³³ PARENTE, Flávia. O dever de diligência dos administradores de sociedades anônimas. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 120-121.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

31.12.2012 e nos ITRs referentes aos períodos encerrados em 30.09.2012 e 31.03.2013 constassem informações de extrema relevância para uma correta avaliação da situação financeira e patrimonial, não agiu com a devida diligência, tendo induzido investidores e o mercado a erro e, conseqüentemente, violado suas obrigações estatutárias e a lei societária (arts. 153, 176 c/c 177, §3º), assim como os arts. 14, 26 e 29 da Instrução CVM nº 480/09.

III.3.3 DA RESPONSABILIDADE DOS DIRETORES REINALDO VARGAS E JOSÉ CAVALCANTI

112. Assim como os acusados anteriormente citados, Reinaldo Vargas e José Cavalcanti, que exerciam, respectivamente, os cargos de diretor de produção e diretor jurídico na OGX, são acusados por terem omitido as informações relativas às incertezas relacionadas à viabilidade econômica da exploração dos Campos das demonstrações financeiras de encerramento do exercício de 31.12.2012 e demonstrações financeiras intermediárias relativas aos períodos encerrados em 30.09.2012 e 31.03.2013.

113. Com relação a esses acusados, inicialmente cabe ressaltar que, de fato, não lhes cabia fazer elaborar as demonstrações financeiras, atribuição, conforme definido no estatuto, do diretor financeiro. No que diz respeito ao comportamento dos acusados diante dos acontecimentos que levaram à declaração pública de inviabilidade dos Campos apenas em 01.07.2013, não se verifica que os diretores não tenham agido com a devida diligência ou de forma descuidada.

114. Ao examinar o estatuto da OGX, vê-se que os acusados tinham as seguintes funções:

(d) Cabe ao **Diretor de Produção**: (i) auxiliar o Diretor Geral em suas funções; (ii) coordenar as atividades de Desenvolvimento da Produção e dos investimentos aprovados pelo Conselho de Administração; (iii) gerenciar a implantação dos projetos da Companhia; e (iv) planejar, coordenar, desenvolver e controlar as atividades e projetos que compõem o portfólio da Companhia de forma otimizada;

(...)

(g) Cabe ao **Diretor Jurídico**: (i) auxiliar o Diretor Geral em suas funções; e (ii) planejar, coordenar, organizar, supervisionar e dirigir as atividades e assuntos de natureza jurídica (Contratos, Societário, Cível, Trabalhista, Penal, Ambiental e Tributário) da Companhia, através da definição e/ou execução de planos, metas e estratégias, garantindo a observância dos requisitos legais e regulatórios vinculados às atividades da Companhia e de suas subsidiárias, realizadas de forma independente ou em parceria com terceiros;

115. Neste contexto, tem-se que ambos exerciam atividades extremamente técnicas e específicas em suas áreas de atuação, com foco, no caso de Reinaldo Vargas, na produção da Companhia, e, no caso de José Cavalcanti, nas questões jurídicas afetas à OGX.

116. Com efeito, verifica-se que as funções desempenhadas pelos acusados não estavam ligadas diretamente à descoberta e delimitação de acumulações de hidrocarbonetos, como no caso da diretoria de exploração, motivo pelo qual não me parece razoável exigir que ambos



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

tivessem tomado qualquer atitude diferente com relação ao que foi divulgado nas demonstrações financeiras analisadas.

117. Ademais, o fato de constar uma relação com todos os nomes dos diretores ao final das demonstrações financeiras não tem, por si só, o condão de responsabilizá-los pela elaboração das informações e seu conteúdo. Tampouco o fato de constar a declaração dos membros da diretoria executiva no sentido de que discutiram, reviram e concordaram com a opinião expressa nos relatórios dos auditores independentes e com as respectivas demonstrações financeiras (fls. 778-780), em observância às disposições do art. 25, da Instrução CVM nº 480/09, implica em responsabilização automática de toda diretoria pelas irregularidades identificadas nas demonstrações financeiras da OGX.

118. Conclui-se então que, no caso concreto, tal obrigação não era exigível dos diretores Reinaldo Vargas e José Cavalcanti, não tendo os referidos acusados violado os preceitos dos artigos 153, 176 c/c 177, § 3º, da Lei nº 6.404/76 e 14, 26 e 29 da Instrução CVM nº 480/09.

III.3.1.3 DA RESPONSABILIDADE DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

119. A Acusação afirma que Eike Batista tinha conhecimento, ao menos quando da divulgação das demonstrações financeiras intermediárias de 31.03.2013, que se deu em 09.05.2013, das relevantes incertezas quanto à viabilidade econômica da exploração dos Campos.

120. Nesse sentido, na qualidade de presidente do conselho de administração da Companhia, o acusado teria descumprido o disposto nos arts. 142, inciso III, 153 da Lei nº 6.404/76, ao ter deixado de adotar as providências compatíveis com a relevância e natureza da matéria, de modo a assegurar que o 1º ITR/2013 evidenciasse tais informações relevantes para a compreensão da situação financeira e patrimonial da Companhia, em desacordo com os CPCs 00 (R1) e 26 (R1).

121. A Acusação acredita que o acusado detinha a informação porque em 15.04.2013, ao participar, na qualidade de presidente do conselho de administração da OSX, de reunião com a diretoria executiva da mencionada companhia para discutir uma atualização no seu plano de negócios (fls. 760-767), uma das ações discutidas era o ajuste da tripulação do OSX-2 “*para condição de fundeio temporário na Ásia*” (fls. 762v), plataforma que seria utilizada no desenvolvimento dos Campos, conforme o Fato Relevante de 01.07.2013.

122. A SEP ressaltou que não teria sido informada a razão aparente, naquele momento, para a OSX manter a plataforma OSX-2 fundeada temporariamente na Ásia e, além disso, Eike Batista era o único participante da citada reunião que tinha vínculo formal com a OGX, sociedade afretadora da plataforma.

123. Além disso, afirma a área técnica que ao tempo das primeiras análises em que a área de reservatórios afirmou que a compartimentação e os volumes poderiam ser diferentes da



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

interpretação inicial e das divergências entre as áreas técnicas da OGX, em 2011, Eike Batista ocupava o cargo de presidente da Companhia.

124. Portanto, a Acusação concluiu que dado que os estudos versavam sobre um tema crucial para determinar a viabilidade econômica e financeira futura da Companhia e cujos primórdios remontavam ao período em que era o diretor presidente da mesma, não se apresentaria consistente a hipótese de que o acionista controlador e presidente do conselho de administração não tivesse sido mantido a par e/ou buscado manter-se informado, como decorreria de seu dever legal e estatutário como conselheiro, a respeito dos resultados dos estudos, os quais se revelariam adversos quando da apresentação efetuada pelo GT à diretoria executiva em 24.09.2012, condição essa corroborada com as conclusões do estudo da RATE em fevereiro de 2013.

125. Não nego assistir razão ao Acusado no tocante às delimitações de suas atribuições, que não alcançariam o acompanhamento do dia a dia da gestão, e, por isso, não seria dele esperado participar da decisão, por exemplo, de criar o GT ou de contratar terceiros para buscar alternativas para viabilizar a exploração dos Campos. No entanto, não considero que Eike Batista estivesse completamente alheio aos resultados técnicos produzidos que demonstravam a inviabilidade econômica dos Campos.

126. Neste particular, forçoso reconhecer que os problemas detectados na exploração dos Campos tinham potencial de impactar o fluxo de caixa e os resultados da OGX, que, caso confirmasse aquele contexto, poderia vir a enfrentar problemas significativos em seus negócios, como posteriormente restou materializado. Deste modo, o insucesso daquela empreitada tinha reflexos na própria continuidade da Companhia, a demonstrar que não se tratava de mera questão operacional restrita aos técnicos da Companhia, como alega Eike Batista.

127. Como já extensamente abordado ao longo deste voto, ao final de março de 2013 a Companhia já detinha a informação de que não seria viável economicamente a exploração dos Campos, respaldada por farta documentação, cuja consequência afetava a continuidade dos negócios da OGX e, por isso, de ciência obrigatória da alta administração da Companhia.

128. Nesta direção, na reunião realizada em 15.04.2013, foi discutida a alteração do plano de negócios da OSX, sendo que o novo plano estratégico previa um cenário extremamente difícil no tocante às atividades sociais da companhia, com a necessidade de vender participações nas plataformas em operação e em construção relacionadas justamente à exploração dos Campos, bem como concluir junto a OGX o pagamento de despesas com os projetos de plataformas paralisados (fls. 752-767).

129. Com efeito, os problemas da OGX relacionados ao desenvolvimento dos Campos estavam sendo discutidos e, principalmente, decididos no âmbito do conselho de administração da OSX, do qual Eike Batista fazia parte, a demonstrar que a matéria era não somente de sua ciência como também já estava repercutindo severamente no desempenho de outras companhias do grupo.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

130. O assunto em questão versava não somente sobre a direção e condução geral dos negócios sociais da Companhia; mais do que isso, era questão vital para a continuidade da OGX, com potencial de definir o sucesso ou o fracasso da sociedade, como de fato aconteceu, tanto é que aproximadamente três meses após a divulgação do fato relevante informando sobre a inviabilidade dos Campos, a OGX publicou novo comunicado informando que havia ajuizado pedido de recuperação judicial (fls. 174).

131. Portanto, é possível afirmar, com convicção, que o acusado, principal executivo e idealizador de todo o chamado “Grupo X”, acionista controlador e presidente da OGX até abril de 2012, além de presidente do conselho de administração à época dos fatos, era um dos maiores interessados em acompanhar a matéria, e que seriam de seu conhecimento quaisquer informações relevantes sobre os negócios da Companhia, ainda não divulgadas ao público.

132. Diante do exposto, concluo que Eike Batista tinha conhecimento das questões envolvendo a inviabilidade econômica da exploração de óleo e gás dos Campos quando da divulgação do 1º ITR/13, em 09.05.2013.

133. Passo a analisar o papel do conselho de administração e das obrigações de Eike Batista, na qualidade de presidente do conselho da OGX, na elaboração e divulgação de informações financeiras da OGX.

134. Como se sabe, cabe aos membros do conselho de administração, nos termos do art. 142, incisos III e V³⁴, da Lei nº 6.404/76, fiscalizar a gestão da diretoria e manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da diretoria. Apesar de ser, por definição, órgão de deliberação colegiada, merece reparo o argumento da defesa no sentido de que Eike Batista não poderia responder isoladamente por uma atribuição de um órgão colegiado.

135. De fato, trata-se de órgão de deliberação colegiada, nos termos do art. 138, §1º, da lei societária, o que não significa que cada membro, individualmente, não tenha poderes-deveres de fiscalização dos atos da diretoria.

136. Sobre essa matéria já me manifestei ao analisar o PAS CVM 01/2011, no qual ressaltei que *“embora o conselho de administração seja um órgão de deliberação colegiada, isto é, o conselheiro não tem poder individual de isoladamente manifestar a vontade do órgão, nos termos do art. 138, §1º, da Lei 6.404/76³⁵, as responsabilidades de seus membros podem ser individualizadas, desde que existam elementos aptos a justificar a diferenciação das condutas,*

³⁴ Art. 142. Compete ao conselho de administração: (...)

III - fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos; (...) V - manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da diretoria;

³⁵ Art. 138. A administração da companhia competirá, conforme dispuser o estatuto, ao conselho de administração e à diretoria, ou somente à diretoria. §1º O conselho de administração é órgão de deliberação colegiada, sendo a representação da companhia privativa dos diretores.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

como ocorre no presente caso”. Marcelo Adamek analisa a questão e faz os seguintes apontamentos³⁶⁻³⁷:

(...) A LSA não prevê competência individual para os membros do conselho de administração, mas pressupõe, e previu, **deveres próprios de sua atuação isolada**. O exemplo talvez mais evidente patenteia-se no dever geral de fiscalização (pautado pelo *standard* legal de diligência) que cabe a cada um dos conselheiros e de cujo descumprimento resulta a responsabilidade solidária (LSA, art. 158, §1º). (grifou-se)

137. Desse modo, havendo elementos aptos a justificar sua atuação individualizada, como ocorreu no presente caso, o membro do conselho de administração pode, e deve, agir.

138. Cabendo-lhe fiscalizar os atos da diretoria e acompanhar a gestão dos negócios da Companhia, esperava-se do acusado, ao tomar conhecimento de que a exploração dos principais ativos da OGX na Bacia de Campos era economicamente inviável, uma atuação diligente no sentido de, no mínimo, verificar junto à diretoria quais as providências estavam sendo tomadas para tratar a questão, tanto *interna corporis* como externamente.

139. E dentre essas providências estava a correta e adequada divulgação das demonstrações financeiras de modo a refletir a real situação patrimonial e financeira da Companhia, de acordo com a lei e a regulamentação aplicável, o que claramente não ocorreu. Diante de matéria de extrema relevância para as atividades da Companhia, de grande impacto no *core business* da OGX, esperava-se uma conduta muito mais proativa por parte do administrador e acionista controlador da sociedade.

³⁶ ADAMEK, Marcelo Von. *Responsabilidade Civil dos Administradores de S.A.* São Paulo: Saraiva, 2009, p. 22.

³⁷ No mesmo sentido, o REsp 512.418-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 07.12.2004, em que a ministra relatora decidiu: “*Devidamente prequestionada a matéria, cinge-se a controvérsia em saber se é permitido ao membro do conselho de administração de sociedade empresária exercer o poder de fiscalização de forma individual, mesmo quando detentor de percentual de ações inferior aos 5% estabelecidos pela Lei das S/As. O TJSP afastou a aplicação do art. 105 da Lei n.º 6.404/76, por entender que o pedido formulado pelo recorrido está fundamentado no art. 142 da mesma lei, ao postular “na condição de membro integrante do conselho de administração da sociedade” (fl. 218), entendimento esse que adoto para afastar de plano a violação alegada.*

No tocante ao art. 142 da Lei das S/As, verifica-se que o exercício individual das atribuições conferidas ao conselho de administração é decorrência lógica das funções de fiscalização inerentes ao órgão do qual fazem parte os seus membros. Por certo, não se pode conceber a restrição aventada pelo recorrente sob pena de redução da capacidade do próprio conselho em fiscalizar os atos da diretoria.

Fiscalização importa, entre outras condições, em agilidade e flexibilidade por parte dos agentes que estejam encarregados dessa função, mesmo porque advém da pronta execução dessa atividade a possibilidade de se interromper atos danosos à estrutura da sociedade empresária. (...)

Impõe-se então, o reconhecimento de que o exercício da fiscalização outorgada ao conselho de administração somente se dará a contento se os seus componentes tiverem condições de, agindo individualmente, fiscalizarem os atos da diretoria para, na presença de indícios de possível ilegalidade ou ato contrário aos interesses da sociedade, alçar à debate a questão perante o colegiado.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

140. Questão similar foi por mim analisada ao verificar a responsabilidade dos membros do conselho de administração do Banco Panamericano acusados de não terem analisado criticamente as demonstrações financeiras do banco³⁸. Naquela oportunidade, ressaltai que “*o dever de diligência do administrador deve ser avaliado em relação a sua atuação nas **atividades de maior relevo da companhia**, na medida em que estas operações podem causar **maiores impactos nos resultados da sociedade**. Em outros termos, a monitoração exigida pela lei aos conselheiros deve levar em consideração as características operacionais e os riscos mais relevantes enfrentados pela companhia, a **demandar atenção nas atividades que podem comprometer a continuidade da companhia**” (grifou-se).*

141. Pelo exposto, resta claro que Eike Batista, na qualidade de presidente do conselho de administração da OGX, faltou com seu dever de diligência, violando o padrão de conduta exigido pelo art. 153 da lei societária, ao, tendo conhecimento, ao menos a partir de 15.04.2013, das incertezas relacionadas à viabilidade econômica da exploração dos Campos, ter deixado de adotar as providências compatíveis com a relevância e natureza da matéria de modo a assegurar que as demonstrações financeiras intermediárias que serviram de base para o preenchimento do Formulário 1º ITR/2013 (divulgado em 09.05.2013) evidenciassem tais informações relevantes para a compreensão da situação financeira e patrimonial da Companhia.

IV. CONCLUSÃO E PENALIDADES

142. Por todo o exposto, com fundamento no art. 11 da Lei nº 6.385/76, considerando a gravidade das infrações, os antecedentes dos acusados³⁹, a alta dispersão acionária da Companhia e grande volume de negócios à época⁴⁰, além dos danos à imagem do mercado de valores mobiliários, voto pela condenação de:

- i) **Eike Fuhrken Batista**, na qualidade de presidente do conselho de administração da OGX, à penalidade de multa pecuniária, no valor de **R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)**, por infração ao artigo 142, inciso III, e artigo 153 da Lei nº 6.404/76, ao, tendo conhecimento, ao menos a partir de 15.04.2013, das incertezas relacionadas à viabilidade econômica da exploração dos Campos de Tubarão Tigre, Gato e Areia, deixar de adotar as providências compatíveis com a relevância e natureza da matéria, de modo a assegurar que as demonstrações financeiras intermediárias que serviram de base para o preenchimento do Formulário 1º

³⁸ PAS CVM 01/2011, julgado em 27.02.2018.

³⁹ Eike Batista foi condenado em diversos processos no âmbito da CVM (PAS CVM RJ2013/10321, julgado em 18.03.2015; PAS CVM RJ2013/7916, julgado em 18.03.2015; PAS CVM RJ2013/2400, julgado em 18.03.2015; PAS CVM RJ2013/10909, julgado em 18.03.2015; PAS CVM RJ2013/10060, julgado em 10.11.2015; PAS CVM RJ2013/13172, julgado em 18.06.2017); Roberto Bernardes Monteiro e Luiz Eduardo Guimarães Carneiro foram condenados no PAS CVM RJ2013/7916, julgado em 18.03.2015.

⁴⁰ A ação OGXP3, ação ordinária de emissão da OGX, chegou a integrar a carteira teórica de ativos do IBOVESPA, que leva em consideração, além de outros elementos, critérios como volume financeiro e índice de negociabilidade.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

ITR/2013 (divulgado em 09.05.2013) evidenciassem tais informações relevantes para a compreensão da situação financeira e patrimonial da Companhia, fato que caracterizou a inobservância ao disposto no item 4.43 do Pronunciamento Técnico CPC 00 (R1) e nos itens 125, 129 e 131 do Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1), aprovados, respectivamente, por meio das Deliberações CVM 675/11 e 676/11;

- ii) **Roberto Bernardes Monteiro**, na qualidade de diretor financeiro, à penalidade de multa pecuniária, no valor de **R\$500.000,00 (quinhentos mil reais)**, por infração aos artigos 153, 176 c/c 177, §3º, da Lei nº 6.404/76 e 14, 26 e 29 da Instrução CVM nº 480/09 ao, tendo conhecimento das incertezas relacionadas à viabilidade econômica da exploração dos Campos de Tubarão Tigre, Gato e Areia, fazer elaborar demonstrações financeiras de encerramento do exercício de 31.12.2012 e demonstrações financeiras intermediárias relativas aos períodos encerrados em 30.09.2012 e 31.03.2013, omitindo tais informações relevantes para a compreensão da situação financeira e patrimonial da Companhia, em inobservância ao disposto no item 4.43 do Pronunciamento Técnico CPC 00 (R1) e nos itens 125, 129 e 131 do Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1), aprovados, respectivamente, por meio das Deliberações CVM 675/11 e 676/11; e
- iii) **Luiz Eduardo Guimarães Carneiro**, na qualidade de diretor presidente, à penalidade de multa pecuniária, no valor de **R\$400.000,00 (quatrocentos mil reais)**, por infração aos artigos 153, 176 c/c 177, §3º, da Lei nº 6.404/76 e 14, 26 e 29 da Instrução CVM nº 480/09 ao, tendo conhecimento das incertezas relacionadas à viabilidade econômica da exploração dos Campos de Tubarão Tigre, Gato e Areia, fazer elaborar demonstrações financeiras de encerramento do exercício de 31.12.2012 e demonstrações financeiras intermediárias relativas aos períodos encerrados em 30.09.2012 e 31.03.2013, omitindo tais informações relevantes para a compreensão da situação financeira e patrimonial da Companhia, em inobservância ao disposto no item 4.43 do Pronunciamento Técnico CPC 00(R1) e nos itens 125, 129 e 131 do Pronunciamento Técnico CPC 26(R1), aprovados, respectivamente, por meio das Deliberações CVM 675/11 e 676/11.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

143. Por fim, voto pela extinção da punibilidade de **Paulo de Tarso Martins Guimarães**, em razão do seu falecimento em 07.09.2018, e pela absolvição de **Reinaldo José Belotti Vargas** e **José Roberto Penna Chaves Faveret Cavalcanti** da acusação de violação aos artigos 153, 176 c/c 177, § 3º, da Lei nº 6.404/76 e 14, 26 e 29 da Instrução CVM nº 480/09.

É o voto.

Rio de Janeiro, 27 de maio de 2019.

HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA
DIRETOR RELATOR



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2014/12838

Acusados: Eike Fuhrken Batista
José Roberto Penna Chaves Faveret Cavalcanti
Luiz Eduardo Guimarães Carneiro
Paulo de Tarso Martins Guimarães
Reinaldo José Belotti Vargas
Roberto Bernardes Monteiro

Assunto: Apurar responsabilidade de ex-membros da Diretoria e do Conselho de Administração da OGX Petróleo e Gás Participações S.A. (atual Dommo Energia S.A.) por não terem tomado as providências necessárias para que as demonstrações financeiras evidenciassem informações relevantes para a compreensão da situação financeira e patrimonial da companhia. Infração aos arts. 142, III, 153 e 176 c/c 177, § 3º, da Lei nº 6.404/76 e dos arts. 14, 26 e 29 da Instrução CVM nº 480/09.

Diretor Relator: Henrique Machado

MANIFESTAÇÃO DE VOTO

1. Pedi vistas do presente processo administrativo sancionador por entender necessário analisar mais detidamente os fundamentos da acusação formulada com base na ausência de cuidado e diligência na preparação de determinadas informações financeiras da OGX Petróleo e Gás Participações S.A. (“OGX” ou “Companhia”), notadamente, o Formulário 3º ITR/2012, as Demonstrações Financeiras anuais referentes ao exercício social de 2012 (“DF2012”) e o Formulário 1º ITR/2013 (em conjunto, “Informações Financeiras”), bem como as razões consideradas pelo Diretor Relator para sua conclusão pela condenação do Diretor Presidente e do Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

Contexto

2. A acusação busca responsabilizar, pelo descumprimento dos arts. 153 e 176 c/c 177, § 3º, da Lei nº 6.404/76 e dos arts. 14, 26 e 29 da Instrução CVM nº 480/09, (i) o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da OGX à época dos fatos, Roberto Monteiro, bem como (ii) Luiz



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Carneiro, na qualidade de Diretor Presidente da OGX; (iii) Reinaldo Vargas, na qualidade de Diretor de Produção da OGX; (iv) José Roberto Faveret, na qualidade de Diretor Jurídico da OGX; e (v) Paulo Guimarães, na qualidade de Diretor de Exploração da Companhia.

3. Segundo consta do termo de acusação, os acusados, *“tendo conhecimento das incertezas relacionadas à viabilidade econômica da exploração dos Campos de Tubarão Tigre, Gato e Areia”* (“Fatos” ou “Incertezas”), teriam feito elaborar *“demonstrações financeiras de encerramento do exercício de 31.12.2012 e demonstrações financeiras intermediárias relativas aos períodos encerrados em 30.09.2012 e 31.03.2013, omitindo tais informações relevantes para a compreensão da situação financeira e patrimonial da Companhia, em inobservância ao disposto no item 4.43 do Pronunciamento Técnico CPC 00(R1) e nos itens 125, 129 e 131 do Pronunciamento Técnico CPC 26(R1), aprovados, respectivamente, por meio das Deliberações CVM 675/11 e 676/11”* (fls. 809).

4. Tais Incertezas teriam sido identificadas em estudos preliminares da companhia (vide apresentação feita pelo GT¹ em setembro de 2012), que indicariam redução substancial da estimativa de volume de óleo recuperável em relação aos volumes originalmente divulgados ao mercado, bem como retornos negativos para o desenvolvimento da exploração dos Campos, tendo se confirmado ao longo do período de elaboração das Informações Financeiras, na medida em que análises adicionais (estudo da RATE² e estudos sísmicos adicionais³) foram sendo realizadas e concluídas.

5. Além dos Diretores acima identificados, o então Presidente do Conselho de Administração da OGX, Eike Batista, também foi acusado no âmbito deste processo, por infração aos arts. 142, III, e 153 da Lei nº 6.404/76, ao, *“tendo conhecimento, ao menos a partir de 15.04.2013”* das Incertezas, *“deixa[do] de adotar as providências compatíveis com a relevância e natureza da matéria, de modo a assegurar que”* o Formulário 1º ITR/2013 (divulgado em 09.05.2013) evidenciasse *“tais informações relevantes para a compreensão da situação*

¹ Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados nesta manifestação de voto e que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes foi atribuído no Relatório.

² Em 06 de fevereiro de 2013 (fls. 458), a RATE encerrou seus trabalhos, concluindo que o projeto de exploração dos Campos demandaria *“equipamentos de grandes dimensões e consequentemente elevados custos”*, sugerindo que *“fossem avaliadas outras tecnologias buscando a viabilidade do projeto”* (fls. 307).

³ A OGX afirmou que *“em março de 2013 foi entregue à Companhia o reprocessamento da sísmica dos reservatórios localizados nestes quatro campos, feito pela empresa CGG Brasil, com dados mais precisos sobre as características da área, para permitir à OGX uma melhor avaliação do modelo geológico dos campos, tendo em vista os comportamentos distintos dos poços perfurados e concluídos para produção”* (fls. 113-119).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

financeira e patrimonial da Companhia”, fato que caracterizaria inobservância aos mesmos pronunciamentos técnicos referidos acima (fls. 127).

6. Na sessão de julgamento iniciada em 27.05.2019, o Diretor Relator votou (i) pela extinção da punibilidade de Paulo Guimarães, (ii) pela absolvição de Reinaldo Vargas e José Roberto Faveret e (iii) pela condenação de Roberto Monteiro, Luiz Carneiro e Eike Batista.

7. De minha parte, tenho dúvidas se a alegada falha por parte de Luiz Carneiro e Eike Batista, no que toca ao conteúdo de determinadas informações financeiras da Companhia, pode ser atribuída a uma suposta falta de cuidado e diligência de que trata o art. 153 da Lei das S.A. por parte desses acusados. Como procurarei deixar claro, embora entenda que a decisão dos administradores da OGX sobre a divulgação dos Fatos não se deu de modo tempestivo ou completo, penso que o enquadramento escolhido pela acusação (falta de diligência) requer a consideração de elementos específicos distintos, os quais, a meu ver, não foram suficientemente explorados nos autos a ponto de levar à conclusão de que Luiz Carneiro e Eike Batista faltaram com seu dever de diligência.

8. Neste ponto, entendo pertinente destacar que as seguintes ponderações feitas em minha manifestação de voto no PAS CVM nº RJ2014/6517 – cujos fatos são coincidentes com os deste processo – não são de forma alguma afetadas pelas razões que serão esposadas abaixo, senão para reforçá-las: (i) Luiz Carneiro se desincumbiu de seus deveres de se informar, investigar e vigiar naquilo que concerne à exploração dos Campos; (ii) Luiz Carneiro se mostrou, na prática, responsável pela forma indevida (incompleta e intempestiva) que foi realizada a divulgação dos Fatos ao mercado, juntamente com o Diretor de Relações com Investidores da Companhia; e (iii) a avaliação sob a ótica da diligência pode ser feita no âmbito de seu dever de revelar ao mercado atos ou fatos relevantes sobre os negócios da Companhia, constante do art. 157 da Lei das S.A. e da Instrução CVM nº 358/02, escolha esta que não foi feita pela acusação nem naquele, nem neste caso⁴.

Dever de diligência

9. À semelhança do que fiz em minha manifestação no âmbito do PAS CVM nº RJ2014/6517, em benefício da clareza, farei algumas observações a respeito do dever de

⁴ Conforme será melhor analisado no item V desta manifestação de voto, entendo que o processo decisório que levou à não divulgação de um fato relevante específico a respeito dos Fatos e à sua não divulgação no fato relevante de 13 de março de 2013 não necessariamente coincide com o processo decisório sobre a inclusão de tais fatos em notas explicativas ou demais registros contábeis específicos.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

diligência que julgo relevantes. A importância do dever de diligência no sistema disciplinar da lei societária mais do que justifica, impõe o estabelecimento de parâmetros conceituais claros que permitam sua compreensão e aplicação.

10. O legislador de 1976 optou por definir o dever de diligência como um conceito aberto, conferindo ao intérprete ampla liberdade para conformá-lo às circunstâncias e à realidade do caso concreto. A lei, portanto, não reflete uma escolha por abordagem mais prescritiva ou exaustiva do conceito, com requisitos apresentados de forma detalhada, o que permite melhor adaptabilidade às mudanças impostas pela rápida evolução das práticas empresariais, impulsionadas pelas mudanças culturais e tecnológicas⁵.

11. Naturalmente, por ser estabelecido como um padrão aberto, é de se esperar que o atendimento do dever de diligência seja possível, via de regra, de múltiplas formas. Se é verdade que cada decisão ou ato tomado pelo administrador deve refletir uma convicção formada no interesse da companhia ao final da devida reflexão, isso não quer dizer que todo administrador, diante da mesma situação, somente terá um caminho a seguir⁶. Igualmente, a razoabilidade e adequação dos esforços empregados na supervisão de determinado assunto ou pessoa podem ser alcançadas através de diversos meios empregados pelo administrador.

12. Por outro lado, o que torna determinada conduta questionável sob o ponto de vista da diligência é a ausência dos elementos necessários para o atingimento do padrão de cuidado exigido pelo art. 153 da Lei das S.A. A doutrina e o Colegiado elencaram, respeitadas algumas variações⁷⁻⁸, três principais ordens de comportamentos que compõem o padrão de diligência previsto na lei e, por isso, são empregados como parâmetros para a aferição da diligência das condutas adotadas pelos administradores, em sede de revisão jurisdicional⁹.

⁵ Sobre esse padrão, ver ZANINI, Carlos Klein. A doutrina dos “*fiduciary duties*” no direito norte-americano e a tutela das sociedades e acionistas minoritários frente aos administradores das sociedades anônimas. In: *Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro*. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 109, 1998, p. 139. Ver ainda IA CVM 04/99, j. 17.04.02.

⁶ Em outras palavras, o sistema da lei societária aceita uma pluralidade de respostas diante das mesmas situações, e o que diferencia uma resposta de outra não impede que sejam ambas legítimas e adequadas à moldura da lei.

⁷ Vide RIBEIRO, Renato Ventura. *Dever de diligência dos administradores de sociedades*. São Paulo: Quartier Latin, 2006, pp. 221-231; EIZIRIK, Nelson. *A Lei das S/A Comentada – Artigos 138 ao 205*. 2ª ed. São Paulo: Quartier Latin, 2015. v. III, pp. 120-124; PARENTE, Flávia. *O Dever de Diligência dos Administradores de Sociedades Anônimas*. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, pp. 101-131; BRIGAGÃO, Pedro Henrique Castello. *A Administração de Companhias e a Business Judgment Rule*. São Paulo: Quartier Latin, 2017, pp. 60-68).

⁸ Vide: PAS CVM nº 21/04, j. em 15.05.2007; PAS CVM nº RJ2008/9574, j. em 27.11.2012; PAS CVM nº 11/2002, j. em 26.02.2013; e PAS CVM nº 02/2008, j. em 05.03.2013, entre outros.

⁹ A respeito, veja-se voto do Diretor Gustavo Gonzalez: “*De plano, parece-me importante registrar – sem nenhuma pretensão, todavia, de esgotar o assunto – a importante distinção entre os padrões de conduta e os padrões de revisão adotados para verificar, ex post, o cumprimento dos deveres fiduciários. (...) Embora por vezes inadvertidamente*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

13. Refiro-me, aqui, aos deveres do administrador de se informar, vigiar e investigar, os quais lhe impõem, em linhas muito gerais, a obrigação de, respectivamente, pautar seus atos e tomar decisões de maneira informada, monitorar as políticas e atividades da companhia – dirigidas ou fiscalizadas pelo administrador – e investigar fatos quando surjam sinais de alerta que venham a conhecer ou que devam conhecer.

14. Pelo que se vê, a análise da aderência de determinada conduta ao padrão de diligência previsto em lei deve ser feita com foco no aspecto procedimental. Ou seja, o que deve ser objeto de exame para aferir o cumprimento desses ditos subdeveres – e, por consequência, do dever de diligência – é a forma segundo a qual o administrador atua e não o conteúdo final de suas decisões¹⁰. Não seria mesmo possível admitir outra interpretação, uma vez que esta é a única que se coaduna com a natureza do dever de diligência. Isso significa que importa para a aferição do cumprimento deste dever que seja verificado, na prática, o emprego, pelo administrador, de esforços necessários e suficientes para o alcance de determinado resultado. Se o resultado não tiver sido satisfatório, isso não servirá, portanto, como demonstração de falta de diligência.

15. Tipicamente, a diligência de determinada conduta é usualmente examinada sob dois aspectos: negocial ou fiscalizatório¹¹. O primeiro refere-se às decisões tipicamente negociais, tomadas pelo próprio administrador, em face das quais impõe-se o teste da *business judgment rule*. O segundo abarca dimensão voltada à supervisão das mais variadas atividades da companhia, primariamente dirigidas por outros administradores, no âmbito da qual, a princípio, a diligência é aferida a partir da verificação da razoabilidade e adequação dos esforços despendidos pelo administrador no desempenho de sua função fiscalizatória.

considerados como intercambiáveis, o dever de diligência é padrão de conduta, que não se confunde com um padrão de revisão. A regra da decisão negocial, por sua vez, é um padrão de revisão, que em nossa jurisprudência administrativa protege decisões tomadas de modo informado, refletido e desinteressado. Confundir o dever de diligência com a business judgment rule conduziria à conclusão de que uma decisão interessada não poderia ser considerada diligente, o que, a toda evidência, não corresponde à realidade, nem reflete o sistema da nossa lei. O administrador interessado que toma uma decisão negocial pode não estar protegido pela business judgment rule, fato que não lhe exime, de modo algum, de atuar de forma diligente e tampouco permite concluir, sozinho, pela falta de diligência". (PAS CVM nº RJ2013/11703, j. em 31.07.2018)

¹⁰ Sobre o tema: CAMPOS, Luiz Antonio de Sampaio. Deveres e responsabilidades. In: LAMY FILHO, Alfredo; PEDREIRA, José Luiz Bulhões (Coords.). *Direito das Companhias*. 2ª Edição. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 805; GONZALEZ, Jesus Quijano. *La responsabilidad civil de los administradores de la sociedad anonima: aspectos sustantivos*. Universidade de Valladolid, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Salamanca, 1985, pp. 186/187.

¹¹ Conforme expôs o então Diretor Otavio Yazbek, "o conteúdo do dever de diligência possui duas naturezas distintas: uma de cunho negocial, sujeita ao teste da business-judgment rule; e outra de natureza fiscalizatória, sujeita a uma análise de razoabilidade e de adequação" (PAS CVM nº 24/2006, j. em 18.02.2013). Esta lógica foi explorada com mais detalhe por referido Diretor em artigo sobre o tema: YAZBEK, Otavio. Representações do Dever de Diligência na Doutrina Jurídica Brasileira. In: KUYVEN, Luiz Fernando Martins (Coord.). *Temas essenciais de direito empresarial – Estudos em homenagem a Modesto Carvalhosa*. São Paulo: Saraiva, 2012, vide p. 944.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

16. E nesse ponto cabe notar que o dever de diligência vale para todos os administradores, independentemente de suas funções e poderes¹², inclusive sob o prisma fiscalizatório. Quero com isso dizer que, não obstante a Lei das S.A. ser expressa no que toca ao dever dos Conselheiros de fiscalizar a gestão dos Diretores (art. 142, III), é natural que um Diretor atento à gestão da Companhia tenha ciência de iniciativas que estejam sendo conduzidas por outros Diretores e que, por suas características, mereçam sua atenção e postura vigilante¹³.

17. Dito isso, entendo que, neste caso, consideradas todas suas circunstâncias, a verificação da observância, por Luiz Carneiro e Eike Batista, de seu dever de diligência, consistirá, essencialmente, em um exercício de análise de sua atuação na supervisão dos atos relacionados à preparação das Informações Financeiras.

A situação dos Diretores da OGX

18. Conforme consta do termo de acusação, *“em 24.09.2012, foram levadas formalmente ao conhecimento de administradores da Companhia informações cuja relevância, pela natureza e materialidade dos dados apontados, é inquestionável”* (fls. 807). Apurou-se que todos os membros da Diretoria da OGX à época dos fatos *“tiveram acesso à apresentação do GT de 24.09.2012 e ao relatório da RATE de fevereiro/2013”*, havendo, ainda, assinado as Informações Financeiras e declarado que *“discutiram, reviram e concordaram com a opinião expressa nos relatórios dos auditores independentes”* e com as referidas informações (fls. 809).

19. Em seu voto, o Diretor Relator absolveu Reinaldo Vargas e José Roberto Faveret por entender que a elaboração das demonstrações financeiras não estava compreendida em suas atribuições estatutárias, as quais seriam pertinentes a domínio técnico estranho a seu cargo e não estariam relacionadas *“diretamente à descoberta e delimitação de acumulações de hidrocarbonetos, como no caso da diretoria de exploração”*, não parecendo razoável lhes exigir que *“tivessem tomado qualquer atitude diferente com relação ao que foi divulgado nas demonstrações financeiras analisadas”* (§§116-117). Também considerou que a assinatura e

¹² Nesse sentido, ver RIBEIRO, Renato Ventura. *Dever de diligência dos administradores de sociedades*. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 218.

¹³ O papel fiscalizatório dos diretores é reconhecido no Direito das Companhias: *“[a]s atribuições [dos Diretores] em geral são definidas segundo cargos usualmente designados, entre outros, Diretor-Presidente, industrial, financeiro, comercial e administrativo, que compreendem a direção e fiscalização de determinadas atividades e serviços da empresa. Os poderes de diretores são de gestão ou administração e de representação.”* (DE SOUZA JR., Luciano. Título VI - Órgãos Sociais In: LAMY FILHO, Alfredo; PEDREIRA, José Luiz Bulhões (Coords.). *Direito das Companhias*. 2ª Edição. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 772).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

declaração acima mencionadas não seriam suficientes para responsabilizá-los pela elaboração e conteúdo das Informações Financeiras.

20. No entanto, a conclusão foi distinta no caso do Diretor Presidente da Companhia. Segundo o Relator, *“o diretor presidente exerce cargo de extrema importância dentro de uma companhia e espera-se que alguém que exerça tal função esteja ciente, ainda que sem grande aprofundamento em todos os casos, de todas as questões relevantes que estejam em andamento, especialmente aquelas de cunho estratégico, que possam impactar diretamente a continuidade dos negócios da companhia ou a sua sustentabilidade financeira”*. A fim de reforçar tal afirmação, foi feita referência ao voto do ex-Diretor Gustavo Borba no âmbito do PAS CVM nº RJ2014/7072, julgado em 27.03.2018¹⁴.

21. Referindo-se ao caso concreto, o Diretor Relator concluiu que o acusado estava *“diretamente envolvido e à frente dos esforços envolvendo as questões relativas às divergências técnicas relativas aos Campos e às possíveis alternativas para tentar solucionar o problema”*, bem como que *“acompanhava os estudos e seus resultados, ações esperadas à luz de suas atribuições estatutárias, e participava ativamente das decisões ligadas à matéria”*¹⁵.

22. Para o Diretor Relator, um administrador minimamente diligente deveria, diante das conclusões do GT, da RATE e dos dados sísmicos da CGC, ter tomado *“as providências necessárias para assegurar que essa mudança de cenário – em que os dados inicialmente divulgados, extremamente otimistas, deram lugar a números bem mais modestos (set/12) e, posteriormente, à declaração de inviabilidade – fosse divulgada ao mercado, assim como refletida nas informações financeiras da OGX”* (§109 do Voto).

23. Não tenho dúvidas quanto à maior amplitude dos encargos daquele que é investido no cargo de Diretor Presidente de uma companhia. De tal pessoa legitimamente se espera ciência e envolvimento em um espectro de questões bem mais abrangente do que de qualquer outro executivo. Entretanto, disso não decorre, necessariamente, que se poderá exigir do Diretor

¹⁴ Vide §111 do Voto: *“...embora não fosse sua atribuição estatutária fazer elaborar as demonstrações financeiras (que foi a acusação contra ele formulada), poder-se-ia cogitar, diante das atribuições mais panorâmicas de qualquer Presidente de companhia, de eventual violação ao dever fiduciário de se aprofundar na análise e na discussão das relevantes questões contábeis que foram objeto de ressalva pelo auditor independente”* (trecho do voto do ex-Diretor Gustavo Borba no âmbito do PAS CVM nº RJ2014/7072, julgado em 27.03.2018, grifos meus).

¹⁵ Vide §§ 107 e 109 do Voto. Nesse tocante, ressaltou-se ainda o fato de que o acusado *“imediatamente alterou a estrutura para que a área de reservatórios, a mais conservadora quanto às estimativas, passasse a responder diretamente a ele”* o que demonstraria *“primeiro, que havia indícios de possível distorção das avaliações e reportes quando a referida área era subordinada à diretoria de exploração; e, segundo, que o seu ingresso na OGX estava intimamente ligado às questões envolvendo a exploração dos Campos, ativos extremamente valiosos para a Companhia, competindo a ele, portanto, acompanhar de perto as análises e os estudos conduzidos”* (§108 do Voto).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Presidente o mesmo grau de conhecimento e envolvimento sobre todos os assuntos afetos aos demais Diretores.

Pontos de análise do dever de diligência

24. Com efeito, na análise do cumprimento do dever de diligência por determinado administrador – inclusive se este for o Diretor Presidente – deve-se considerar, ao menos:

(i) suas competências legais e estatutárias (e, eventualmente, atribuições adicionais desempenhadas na prática), as quais definirão se o acusado tinha um dever de conduzir pessoalmente determinado assunto ou realizar determinado ato, ou se sua atribuição consistia em fiscalizar a execução de referido trabalho;

(ii) o grau de tecnicidade da matéria analisada, cuja medida determinará o envolvimento direto do administrador nas discussões a respeito ou então exigirá e justificará a contratação de especialistas internos ou a contratação de externos (*reliance defense*¹⁶); e

(iii) a existência de sinais de alerta que apontem para a irregularidade posteriormente identificada pela acusação, os quais justificarão a exigência de uma fiscalização mais atenta e assídua quanto a assuntos ou atos específicos.

25. Assim, a análise desses três aspectos permitirá aferir o cumprimento dos já referidos subdeveres de se informar, vigiar e investigar, e determinar se os acusados escolheram meios adequados e empregaram esforços proporcionais aos esperados de um administrador diligente na mesma função, considerando-se os fatos e ambiente então vigentes¹⁷.

¹⁶ Teoria que resulta de construção jurisprudencial norte-americana, segundo a qual um administrador pode alegar, em resposta a acusação por conduta negligente, que contava com a atuação de outro administrador, de especialista ou de comitê de assessoramento, por exemplo, para o tratamento do assunto em questão. Obviamente, tal defesa não pode ser utilizada irrestritamente nem servirá para que um administrador a empregue por mera conveniência. Vejamos exemplo de aplicação desta defesa: “...o conselho de administração buscou o auxílio de profissionais externos e especializados para confirmar a razoabilidade dos termos negociados. Dentre tais profissionais encontram-se tanto advogados externos quanto um consultor de recrutamento, que em sua análise concluiu que os tipos de gatilho e os valores propostos estavam em linha com as práticas de mercado. Não existe nenhum elemento nos autos que desabone o aconselhamento prestado ou que indique que os administradores não atuaram de boa-fé, ignorando sinais de alerta, razão pela qual esse aconselhamento também deve ser reconhecido como defesa.” (Manifestação de Voto apresentada pelo Dir. Gustavo Gonzalez, em 31.07.2018, nos autos do PAS CVM nº RJ2013/11703).

¹⁷ Cabe lembrar que: “[a]o contrastar a conduta do administrador à luz do dever de diligência, o intérprete não pode olvidar a necessidade de, em sede de juízo retrospectivo, aferir as alternativas disponíveis por ocasião da tomada da decisão, à luz da realidade e dos fatos da época, e não depois dos fatos consumidos. Não há de perquirir propriamente se a decisão tomada foi a melhor possível, à vista do que posteriormente sucedeu. Deve-se analisar, sim, se, por ocasião da tomada da decisão, a conduta do administrador foi razoável e apropriada à luz dos fatos e do ambiente então vigentes.” (ADAMEK, Marcelo Vieira Von. *Responsabilidade Civil dos Administradores de S/A e as ações correlatas*. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 128)



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

26. No caso concreto, a acusação sustenta que a falta de diligência na conduta de Luiz Carneiro, bem como na dos demais Diretores acusados, consistiu em ter feito elaborar as Informações Financeiras de modo incompleto, sem conter informações a respeito das Incertezas (sobre as quais teria ciência), que seriam relevantes para a compreensão da situação financeira e patrimonial da Companhia (de acordo com os CPCs 00(R1) e 26(R1)) e, portanto, não poderiam ser omitidas das Informações Financeiras.

27. Neste ponto, portanto, cabe nos determos na análise dos três elementos acima identificados, de forma a podermos, ao final, atingir alguma conclusão a respeito da acusação.

Atribuições legais e estatutárias e o aspecto fiscalizatório

28. O art. 176 da Lei das S.A. dispõe que compete à Diretoria fazer elaborar as demonstrações financeiras, o que não significa dizer que caberá a um ou mais integrantes da Diretoria o trabalho de elaborá-las, mas ao órgão, de maneira geral, assegurar que os técnicos responsáveis executem a tarefa de forma adequada, de modo a que tais informações fundamentais sejam preparadas de acordo com a boa técnica.

29. Afinal, cabe lembrar que a Lei das S.A. não exige do administrador de sociedades anônimas nenhum atributo técnico específico, como, por exemplo, conhecimentos em contabilidade. Me parece, por outro lado, que o Diretor Presidente da Companhia, Luiz Carneiro, tinha conhecimento e experiência tanto na área de exploração de petróleo, quanto em gestão empresarial. Sendo assim, entendo que cumpriu com o que dele se poderia esperar conforme o padrão estabelecido na lei societária¹⁸.

30. Ao mesmo tempo, e conforme reconhecido nos autos, o estatuto social da Companhia atribuía diretamente ao Diretor Financeiro da Companhia a incumbência de fazer elaborar suas demonstrações financeiras.

¹⁸ Sobre tal padrão legal: *“O mais apropriado meio de operacionalização do standard do dever de diligência, segundo penso, é o de considera-lo em relação aos cânones da ‘ciência’ da administração de empresas. (...) Diligente, de acordo com esta solução, é o administrador que observa os postulados daquele corpo de conhecimentos técnicos, fazendo o que nele se recomenda e não fazendo o que se desaconselha. Tal forma de operacionalizar a norma do art. 153 da LSA parece-me extremamente objetiva, de modo a tornar o cumprimento do dever passível de aferição através de perícia. Ou seja, se o administrador adotou determinada providência na condução dos negócios sociais, a indagação jurídica acerca do atendimento ao dever de diligência na hipótese deve ocupar-se em compará-la ao que é assente entre os experts em administração de empresa.”* COELHO, Fábio Ulhoa. *Código comercial e legislações complementares anotadas*. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 244.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

31. Por outro lado, não há nos autos evidências de que, além de suas atribuições estatutárias, Luiz Carneiro também se envolvia diretamente com a elaboração das demonstrações financeiras da Companhia (como verifiquei no que toca à elaboração dos fatos relevantes da OGX)¹⁹. Com efeito, como era de se esperar, a acusação somente trouxe evidências sobre o acompanhamento da elaboração das Informações Financeiras que cobrem toda a Diretoria da OGX à época dos fatos (vide §18 acima).

32. Considerando os fatos relacionados ao caso e havendo os arts. 142, inciso II e 143, IV da Lei das S.A. expressamente permitido que o estatuto social atribua competências específicas aos Diretores, bem como o art. 158, §3º disposto que a responsabilidade por *“prejuízos causados em virtude do não cumprimento dos deveres impostos por lei para assegurar o funcionamento normal da companhia”* aberta ficará restrita aos *“administradores que, por disposição do estatuto, tenham atribuição específica de dar cumprimento àqueles deveres”*, não há razões para se diferenciar a aplicação de tal dispositivo legal entre membros do mesmo órgão.

33. Do raciocínio acima decorre que, se é verdade que fazer elaborar as demonstrações financeiras de uma companhia é atribuição colegiada da Diretoria, devem ser somados, no contexto de uma apreciação de responsabilidades em caso concreto, outros fatores importantes. Por exemplo, a competência estatutária específica atribuída ao Diretor Financeiro.

34. Sendo assim, não se deveria ter imputado responsabilidade a toda a Diretoria pelo cometimento das mesmas infrações²⁰. Isto é, deveria a acusação ter diferenciado a situação do Diretor Financeiro da OGX (responsável pelo descumprimento do art. 176 e afins) daquela dos responsáveis por supervisionar o papel deste de fazer elaborar as Informações Financeiras (nos termos do art. 153 da Lei das S.A.).

35. Partindo-se da premissa de que Luiz Carneiro não era corresponsável pela elaboração de demonstrações financeiras, é necessário reforçar que eventual falta de diligência de sua parte deve ser analisada sob um viés fiscalizatório, conforme feito pelo Diretor Relator quanto aos acusados Reinaldo Vargas e José Roberto Faveret.

¹⁹ Conduta que aqui não se pretende de forma alguma incentivar.

²⁰ Em que pese minha opinião pessoal, me parece que o Diretor Relator entendeu suficiente e adequada a construção feita pela acusação: *“Há uma descrição detalhada das informações que teriam sido omitidas nas demonstrações financeiras e que fizeram com que não corresponderem à verdadeira situação econômica da Companhia. Constatadas as infrações a normas que regem a divulgação de informações em demonstrações financeiras, consta no documento a identificação dos administradores que, na visão da Acusação, teriam sido responsáveis por sua elaboração e/ou revisão e, por consequência, pelas omissões apontadas.”* (§§27-28 do Voto, grifou-se).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

36. Esse é, aliás, o entendimento que o Colegiado vem adotando em casos análogos²¹. A título de exemplo, vejamos que a ex-Diretora Ana Novaes, nos autos do PAS CVM nº RJ2014/918, j. em 04.11.2014, optou por absolver Diretores da acusação de elaboração das demonstrações financeiras em desrespeito às regras contábeis aplicáveis, tendo em vista que o estatuto social atribuía essa responsabilidade exclusivamente ao Diretor Financeiro (os Diretores absolvidos não foram acusados de descumprimento do art. 153). Não obstante – e tal como proponho neste voto – a Diretora analisou o descumprimento do dever de diligência dos demais administradores (acusados de infringirem o art. 153) sob o aspecto fiscalizatório. Nas palavras da Relatora:

“A Acusação corretamente pontuou infração a vários pronunciamentos contábeis (CPCs) que foram devidamente aprovados por Deliberações desta CVM e que devem ser seguidos pelas companhias abertas na preparação de suas demonstrações contábeis, conforme exige o art. 177, § 3º da Lei nº 6.404/76. (...) A elaboração das demonstrações financeiras de uma sociedade anônima é uma obrigação da diretoria, enquanto órgão da administração da companhia, nos termos do art. 176 da Lei nº 6.404/76. Quando o Estatuto atribui a um determinado diretor as funções de Diretor Responsável pelas informações financeiras e eventuais a serem enviadas a CVM, a responsabilização recai apenas sobre este diretor especificamente. (...) Com base no entendimento de que apenas a diretora-financeira deva ser responsabilizada pela preparação das demonstrações financeiras, absolvo todos os demais diretores e os conselheiros de administração de infração ao art. 176 c/c 177, e ao art. 26, I e ao art. 29, I. 21. Contudo, entendo que os conselheiros de administração devam ser responsabilizados pela sua falta de diligência. A infração ao art. 153 c/c o art. 142, V fica clara nos autos. (...) Faz parte das competências do conselho de administração fiscalizar a gestão dos diretores e manifestar-se sobre o relatório de administração (art. 142, incisos II e V da Lei nº 6.404/1976).”

37. Trazendo tal lógica jurisprudencial para o presente caso, em verdade, não se trata de analisar se Luiz Carneiro fez tudo que estava a seu alcance para que as Informações Financeiras elaboradas após a identificação dos Fatos os refletissem contabilmente. Esta função não lhe competia, mas ao Diretor Financeiro.

38. Isso posto, do mesmo modo que o Diretor Relator, entendo pela responsabilidade de Roberto Monteiro pelo ocorrido, seja por não ter feito informações sobre as Incertezas chegarem ao conhecimento dos auditores independentes, seja pelo fato de que não procurou se informar adequadamente sobre o eventual enquadramento dos Fatos sobre os quais tomou ciência em

²¹ Note-se que, talvez em razão do enquadramento genérico feito pela acusação, acima apontado, bem como da atribuição fiscalizatória prevista no art. 142, III da Lei das S.A., na maioria dos precedentes em que se abordou o viés fiscalizatório do dever de diligência foram feitas acusações contra conselheiros de administração. No mais, por óbvio, não se está tratando aqui dos precedentes sobre irregularidades em demonstrações financeiras em que não havia atribuição específica ao Diretor Financeiro. Em tais casos, justificadamente, o Colegiado condenou toda a diretoria por infração ao art. 153 da Lei das S.A., inclusive o Diretor Presidente. Vide PAS CVM nº RJ2015/6280, RJ2015/2651, RJ2015/4456 e RJ2015/1823.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

24.09.2012 nos normativos atinentes ao desempenho de sua atribuição de “fazer elaborar” as Informações Financeiras²².

39. Com efeito, não se questiona nesta manifestação a regularidade do ocorrido. O que se busca analisar aqui é a extensão da responsabilidade decorrente, que não deve ser estendida a outros administradores sem justificativa plausível, sob pena de se criar incentivos indesejáveis à administração empresarial.

40. Essa interpretação mais ampla pode produzir efeitos práticos relevantes, como por exemplo dificultar sobremaneira a compreensão, pelos próprios administradores, dos padrões de conduta que a lei lhes impõe, afastando pessoas capazes e honestas da administração das companhias²³. Por esse motivo, entendo que a responsabilização de administradores de companhias abertas por falta de diligência deve ser construída nos exatos contornos que a lei conferiu a este dever – e que a doutrina e a jurisprudência da CVM esmiuçou –, notadamente quando se avalia determinada conduta sob a perspectiva procedimental e quando ausentes os elementos que demonstram o cuidado necessário por parte do administrador. Deve-se, assim, reconhecer que o descumprimento de um dispositivo legal ou regulamentar específico nem sempre será motivado pela falta de diligência.

41. Dessa forma, ausente indicação clara de falta de diligência, corre-se o risco de alargar o conceito de um dever fiduciário previsto em lei que, a despeito de sua centralidade no sistema disciplinar dos administradores de companhias, não pode se prestar a garantir responsabilização que, embora possa parecer adequada em uma primeira análise, é genérica e não se sustenta tanto mais em sede de formação de juízo sancionador.

42. Feitas as ponderações acima sobre o dever previsto no art. 153 da Lei das S.A., cabe assinalar que o envolvimento de Luiz Carneiro com a temática da viabilidade econômica dos

²² A título de exemplo, o item 131 do Pronunciamento Técnico CPC 26(R1), apontado pela acusação, dispõe que: “[p]or vezes, é impraticável divulgar a extensão dos possíveis efeitos de um pressuposto ou de outra fonte principal de incerteza das estimativas ao término do período de reporte. Nessas circunstâncias, a entidade deve divulgar que é razoavelmente possível, com base no conhecimento existente, que os valores dos respectivos ativos ou passivos ao longo do próximo exercício social tenham que sofrer ajustes materiais em função da observação de uma realidade distinta em relação àqueles pressupostos assumidos.”

²³ Ao discorrer sobre a individualidade dos deveres dos integrantes do conselho de administração, Luiz Antonio Sampaio Campos constrói lógica que se aplica a essa consideração: “[a] estrutura dualista na administração da companhia não pode ser ignorada, sob pena de afugentar pessoas capazes, honestas e competentes, de aceitarem participar do Conselho de Administração, por conta da eventual extensão dos deveres e responsabilidades dos administradores a excessos utópicos, que tornaria o risco da posição inaceitável à luz das contrapartidas que teriam no exercício do cargo e culminaria por desvirtuar, por completo, a estrutura do Conselho de Administração. Esses preceitos devem pautar a atuação do intérprete e do aplicador da lei” (CAMPOS, Luiz Antonio de Sampaio. Deveres e responsabilidades. In: LAMY FILHO, Alfredo; PEDREIRA, José Luiz Bulhões (Coords.). *Direito das Companhias*. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 798).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Campos não pode ser confundido com seu envolvimento na elaboração das Informações Financeiras. Afinal, a ciência sobre os Fatos por parte do Diretor Presidente da Companhia não lhe atribui automaticamente o suposto dever de saber a melhor forma de refletir contabilmente tais Fatos nos documentos financeiros da OGX ou que certos normativos contábeis demandariam sua evidenciação imediata nos documentos financeiros da OGX.

43. E, como visto, a responsabilidade por “fazer elaborar” as Informações Financeiras deve ser imputada ao Diretor Financeiro. Ainda que assim não fosse, tanto o modo como liderou e conduziu a análise dos Fatos (a qual se revelou informada, refletida e desinteressada, como visto em minha manifestação de voto no âmbito do PAS CVM nº RJ2014/6517) quanto o grau de especificidade técnica da matéria objeto da acusação e a inexistência de sinais de alerta, conforme explicarei adiante, tampouco indicam que Luiz Carneiro não atingiu o padrão de conduta dele esperado.

44. Estando claro que cabia a Luiz Carneiro a atividade de fiscalização, falta entender o que era razoável se esperar do Presidente de uma companhia aberta como a OGX em seu exercício de supervisão sobre “fazer elaborar” as Informações Financeiras e se houve alguma falha nesse percurso.

45. Partindo das balizas identificadas acima, entendo que a responsabilização do acusado por violação ao dever de diligência de que trata o art. 153 da Lei nº 6.404/76 requer o convencimento de que: (i) houve uma falha por parte de Luiz Carneiro em seu dever de diligência; (ii) tal falha contribuiu para a produção inadequada das Informações Financeiras; e (iii) tal falha é aquela apontada pela acusação e igualmente destacada no voto do Diretor Relator como violadora do art. 153 da Lei nº 6.404/76. Em outras palavras, a falta de diligência terá que estar compreendida em seu dever de fiscalizar a atuação do Diretor Financeiro quanto à elaboração das Informações Financeiras.

O grau de especificidade técnica do tema e a ausência de sinais de alerta

46. É perceptível o caráter eminentemente técnico-contábil do conteúdo dos itens do Pronunciamento Técnico CPC 00(R1) e do Pronunciamento Técnico CPC 26(R1) (mais



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

especificamente, sobre o item 4.43 do primeiro e itens 125, 129 e 131 do segundo), os quais a acusação apontou terem sido inobservados na elaboração das Informações Financeiras²⁴.

47. Não por outro motivo, as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade - CFC e nos pronunciamentos técnicos do Instituto Brasileiro de Contadores – IBRACON, para que sejam de observância obrigatória pelos regulados da CVM, têm que ser aprovadas pela CVM e internalizadas como Deliberações. Tais normas são destinadas aos contadores da sociedade, realizadores diretos dos registros contábeis – os quais inclusive têm que assinar as demonstrações financeiras –, aos auditores independentes, que têm o papel de revisar com uma visão independente a fotografia contábil da sociedade e, finalmente, à própria companhia elaboradora do documento, bem como aos administradores designados para dirigir tal intrincado procedimento – no caso da OGX, seu Diretor Financeiro. Nessa linha, cabe novamente a remissão ao art. 176 da Lei das S.A., que dispõe caber à Diretoria “*fazer elaborar*” as demonstrações financeiras e não elaborar diretamente tal documento financeiro, possivelmente fora da competência dos administradores incumbidos de dirigir sua preparação.

48. Vejamos também que, conforme apontado nas defesas dos acusados, a própria regulamentação da CVM contém normativo dispondo ser “*facultativa*” a divulgação de “*estimativas*” nas demonstrações financeiras da Companhia (art. 20 da Instrução CVM nº 480/09), sendo as Incertezas justamente sobre estimativas contábeis. Na mesma linha, observo que a própria acusação deixou aberta a possibilidade de a Companhia ter feito o *impairment* dos Campos ou incluído os Fatos descobertos em notas explicativas, seja em razão dos resultados preliminares do GT em setembro de 2012, seja em razão dos estudos concluídos em fevereiro e março de 2013, o que milita em favor do reconhecimento da subjetividade e complexidade da matéria.

49. Ademais, a acusação não identificou a existência de informações falsas ou de evidências de fraude contábil na conduta dos acusados, de modo que a análise *a posteriori* feita pela acusação e corroborada pelo Diretor Relator envolve informações que, na opinião de ambos, deveriam ter sido refletidas nas demonstrações financeiras da Companhia antes do que o foram.

50. Diante desse contexto, a não ser que se comprove a inércia frente a sinais de alerta, ou outra circunstância que os dotasse de conhecimento sobre a necessidade de evidenciação das

²⁴ Em vista da tecnicidade contábil da matéria em tela, pensando em casos futuros, entendo recomendável o envolvimento da Superintendência de Normas Contábeis e de Auditoria da CVM – SNC na apuração dos fatos. Seguindo a mesma lógica, em casos envolvendo companhias abertas do setor de petróleo ou de outros setores no âmbito de competência da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, agregaria ao processo uma relação mais próxima da área técnica acusadora com a ANP.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Incertezas, entendo não ser razoável estender a Diretores que não o Diretor Financeiro a responsabilidade de assegurar a observância dos Pronunciamentos Técnicos indicados pela acusação.

51. E, no caso em tela, diferentemente do que ocorreu em um dos precedentes considerados pelo Diretor Relator para concluir pela responsabilização do Presidente da Companhia, acima citado²⁵, os auditores independentes da OGX não apresentaram ressalvas às Informações Financeiras, o que seria um típico sinal de alerta em casos envolvendo informações técnico-contábeis como as presentes²⁶. E me parece que, nesse ponto, a acusação não apontou nenhuma falha da administração da Companhia no que toca ao fornecimento de informações sobre os Fatos para os auditores independentes. Não constam dos autos a análise de eventuais papéis de trabalho que revelariam alguma impropriedade nesse sentido.

52. Nesse tocante, vale notar que, em 05 de agosto de 2013, a Companhia encaminhou manifestação da Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S. contendo a seguinte afirmação: *“com base em nossa revisão sobre o 1º ITR/2013 efetuada de acordo com a NBCTR2410, nada chegou a nosso conhecimento até a data de 06 de maio de 2013 (data de emissão de nosso relatório), que indicasse a não recuperação dos ativos da Companhia (...)”* (fls. 12). Diante do exposto, não se pode desconsiderar na presente análise a falta de ressalvas por parte dos auditores independentes.

53. Não me parece plausível tratar as conclusões do GT como sinais de alerta para fins de identificação de possível irregularidade contábil. Em verdade, os resultados preliminares do GT – e até antes disso, a ciência sobre as divergências entre a Área de Exploração e a Área de Reservatórios – foram exatamente os fatos que justificaram a realização dos estudos subsequentes (RATE, CGC, estudos sísmicos, etc.). Ou seja, a administração os enxergou como indicativos de que providências adicionais deveriam ser tomadas, mas em outro contexto e com outros objetivos.

54. Assim, inexistindo sinais de alerta, não me parece razoável sustentar que Luiz Carneiro – ainda que ocupante do cargo de Presidente da Companhia – deveria ter aprofundado seu

²⁵ Vide §111 do Voto e §20 acima: *“...embora não fosse sua atribuição estatutária fazer elaborar as demonstrações financeiras (que foi a acusação contra ele formulada), poder-se-ia cogitar, diante das atribuições mais panorâmicas de qualquer Presidente de companhia, de eventual violação ao dever fiduciário de se aprofundar na análise e na discussão das relevantes questões contábeis que foram objeto de ressalva pelo auditor independente”* (trecho do voto do ex-Diretor Gustavo Borba no âmbito do PAS CVM nº RJ2014/7072, julgado em 27.03.2018, grifos meus).

²⁶ No sentido de ter sido determinante para a condenação de administradores, com base na falta de diligência verificada na inércia dos administradores diante da existência de ressalvas dos auditores independentes ver: PAS CVM nº RJ2014/918 citado no §36 acima e PAS CVM nº RJ2015/6280, RJ2015/2651, RJ2015/4456, nº RJ2015/1823 e nº RJ2016/2159.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

conhecimento sobre o conteúdo dos referidos Pronunciamentos Técnicos ou mesmo questionado o Diretor Financeiro ou os auditores independentes a respeito da potencial não observância de normativos contábeis, em vista da ocorrência dos Fatos²⁷.

55. Ainda que não pareça razoavelmente exigível de Luiz Carneiro a adoção das providências acima, vale notar que o Diretor Presidente da OGX não se esquivou de mencionar no Relatório de Administração que acompanhou as DF2012 o fato de que a Companhia estava enfrentando desafios no que toca à exploração do Campo de Tubarão Azul – primeiro a produzir na região dos Campos e cuja análise da evolução da produtividade serviu de base para se concluir por sua inviabilidade –, que o volume total de barris recuperáveis seria reduzido e que a Companhia continuava com seus “*estudos para definir a melhor maneira de realizar seu desenvolvimento*” (fls. 699)²⁸.

56. Com base nessa conjuntura, a dificuldade que enxergo em relação à configuração do descumprimento do art. 153 da Lei nº 6.404/76 no caso concreto é justamente a ausência dos elementos caracterizadores da falta de diligência na conduta do acusado, seja na condução de atividade crucial para o êxito da Companhia – exploração dos Campos –, seja na tradução deste tema para informações técnico-contábeis, a serem inseridas nas Informações Financeiras.

57. Não encontrei no termo de acusação o apontamento de nenhuma falha procedimental que seria atribuível ao acusado. Tampouco avaliou-se em que medida o referido administrador teria agido com inércia em seu dever de monitorar as atividades contábeis em tela. Desse modo, diversamente do que entendeu o Diretor Relator²⁹, não estou convencido de que a não execução, por Luiz Carneiro, de seu “dever de informar” através de notas explicativas nas Informações Financeiras denotaria falta de diligência; não sendo possível identificar nos autos em que medida

²⁷ Não há que se falar, tampouco, que o acusado deveria ter requerido pareceres de outros *experts* externos à Companhia sobre como e quando refletir os Fatos nas Informações Financeiras. Observo que, ainda que fosse este o caso, a acusação não se debruçou sobre essas hipóteses. A esse respeito, transcrevo voto da ex-Presidente e Diretora Maria Helena dos Santos: “*Uma vez detectados sinais de alerta que levem o administrador a suspeitar de que algo não está correto, incide sobre ele o dever de investigar esses pontos buscando esclarecimentos até que esteja seguro de que está lidando com a situação corretamente. Esse dever de investigar, naturalmente, não incide sobre toda e qualquer informação disponibilizada ao administrador, tendo em vista que ele goza do direito de confiar na opinião de terceiros, inclusive de especialistas contratados por disporem dessa qualidade. O dever de investigação torna-se imperioso somente diante da presença dos citados sinais de alerta, revelados por meio da análise crítica obrigatória.*” (PAS CVM nº 25/03, j. em 25.03.2008).

²⁸ Valendo a ressalva de que uma coisa é entendermos que teria sido uma boa prática de governança corporativa o Diretor Presidente ir além e demandar a evidenciação contábil de tais informações e outra coisa é dizer que havia um dever por parte do Diretor Presidente de assegurar que tal informação estivesse refletida em notas explicativas.

²⁹ Sobre os requisitos que deverão estar demonstrados para uma condenação com base em falhas no dever de fiscalizar e investigar a atuação de administradores, ver PAS 01/2007, j. em 22.09.2016, de relatoria do ex-Diretor Pablo Renteria.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

o acusado deixou de adotar “*as providências necessárias*”, havendo contribuído para a ocorrência da irregularidade verificada e “*induzido investidores e o mercado a erro*” (cf. §111 do Voto).

58. Diante do quadro acima descrito, concluo que a conduta que a acusação esperava que fosse adotada por Luiz Carneiro não resultou de falta de diligência em seu exercício fiscalizatório.

A situação do Presidente do Conselho da OGX

59. Em processo julgado recentemente por este Colegiado, o Diretor Gustavo Gonzalez suscitou questão relevante a respeito de acusações de falta de diligência imputadas a Conselheiros de administração, tendo alertado para a necessidade de se ter cuidado para que “*as diversas representações do dever de diligência – em especial, aquela associada ao dever de fiscalizar – não sejam construídas de modo excessivamente abrangente, o que fatalmente resultaria na criação de expectativas irreais de comportamento e de parâmetros despropositadamente rigorosos de revisão*”³⁰. A meu ver, como se percebe pelas considerações feitas acima, tal preocupação se justifica neste caso³¹.

60. A acusação indica que, em 15 de abril de 2013 (i.e., antes da divulgação do Formulário 1º ITR/2013 em 09 de maio de 2013), teria havido uma reunião entre a Diretoria da OSX e o Presidente do Conselho de Administração da mesma companhia, Eike Batista, para discutir uma atualização no plano de negócios daquela sociedade (fls. 809), tendo-se deliberado, sem “*razão aparente*”³², pela “*(i) permanência da plataforma OSX-2, que seria utilizada no desenvolvimento dos Campos TTGA, na Ásia, e (ii) manutenção dos empregos das 60 pessoas vinculadas à plataforma OSX-2*”. No entender da acusação, tendo em vista a decisão tomada e sua condição

³⁰ Trecho da manifestação de voto apresentada pelo Diretor Gustavo Gonzalez no âmbito do julgamento do PAS nº RJ2013/8880, j. em 11 de junho de 2019.

³¹ É útil entender a referência adotada pelo legislador brasileiro ao estabelecer os contornos do dever de diligência de conselheiros de administração. Me refiro, como se sabe, ao direito norte-americano: “*The characteristics of directorship ‘duties’ are determined by the corporate context. Court decisions are determined on a case-by-case review and with consideration of the unique structure of a particular corporation. Case-by-case review has led to the creation of subsidiary duties as courts define the parameters of proper director behavior. For example, the duty of care gives rise to the duty to monitor and to exercise oversight, the duty to remain informed about the corporation, the duty to regularly review financial statements and devote attention to board duties and the duty to inquire into corporate affairs. (...) These subsidiary duties often overlap. Although directors are always expected to discharge their obligations in accordance with their fiduciary duties and in the best interests of the corporation, the standard of conduct to which directors are to aspire traditionally has been defined by legally binding case law and statute and by non-binding standards of business best practice.*” (BURCH, Regina Frances. *Director Oversight and Monitoring: The Standard of Care and the Standard of Liability Post-Enron*. Wyoming Law Review, v. 6, nº 2, 2006, pp. 487-488)

³² Segundo a acusação, “[n]ão foi informada a razão aparente, naquele momento, para a OSX manter a plataforma OSX-2 fundeada temporariamente na Ásia e o Sr. Eike Fuhrken Batista era o único participante da citada reunião que tinha vínculo formal com a OGX, sociedade afretadora da plataforma. Assim sendo, pode-se concluir que, ao menos em 15.04.2013, o Sr. Eike Fuhrken Batista já possuía a informação de que a plataforma OSX-2 poderia não ser efetivamente utilizada nos Campos TTGA, considerando, inclusive, a inviabilidade econômica dos mesmos, indicada no relatório da Schumberger de 21.09.2012, objeto de apresentação do GT de 24.09.2012”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

de “*acionista controlador e Presidente do Conselho de Administração e, até 27.04.2012, Diretor-Presidente da Companhia, não seria razoável supor*” que Eike Batista não tivesse tomado conhecimento dos Fatos e dos “*divergentes pontos de vista quanto ao referido potencial entre as Áreas de Exploração e de Reservatórios da Óleo e Gás*” (fls. 810)³³.

61. Com base nesses fatos, concluiu-se que o acusado teria descumprido o disposto nos arts. 142, inciso III e 153 da Lei nº 6.404/76, ao ter deixado de adotar as providências compatíveis com a relevância e natureza da matéria, de modo a assegurar que o 1º ITR/2013 evidenciasse tais informações relevantes para a compreensão da situação financeira e patrimonial da Companhia, em desacordo com os CPCs 00 (R1) e 26 (R1).

62. Já quanto aos demais membros do Conselho de Administração da Companhia, a acusação afirmou que não obteve evidências de que o GT e seus estudos sobre a viabilidade dos Campos “*tivessem sido objeto de deliberações de reuniões*” entre seus membros (fls. 811-812), não lhes incluindo no pólo passivo deste sancionador.

63. Segundo o Diretor Relator, seria “*possível afirmar, com convicção, que o acusado, principal executivo e idealizador de todo o chamado ‘Grupo X’, acionista controlador e presidente da OGX até abril de 2012, além de presidente do conselho de administração à época dos fatos, era um dos maiores interessados em acompanhar a matéria, e que seriam de seu conhecimento quaisquer informações relevantes sobre os negócios da Companhia, ainda não divulgadas ao público*”³⁴.

64. Considerando o conhecimento do acusado sobre os Fatos e dado que lhe cabia supervisionar os atos da Diretoria e acompanhar a gestão dos negócios da Companhia, entendeu

³³ Adicionalmente, para a construção da autoria da infração, a acusação considerou que em resposta à Ofício enviado a Eike Batista, o acusado “*não declarou ter tomado conhecimento dos temas ali abordados somente por ocasião da RCA de 28.06.2013*” (fls. 811).

³⁴ Cf. § 131 do Voto. O Diretor Relator manifestou-se, ademais, nos seguintes termos quanto ao conhecimento de Eike Batista sobre os Fatos: “*[n]ão nego assistir razão ao Acusado no tocante às delimitações de suas atribuições, que não alcançariam o acompanhamento do dia a dia da gestão, e, por isso, não seria dele esperado participar da decisão, por exemplo, de criar o GT ou de contratar terceiros para buscar alternativas para viabilizar a exploração dos Campos. No entanto, não considero que Eike Batista estivesse completamente alheio aos resultados técnicos produzidos que demonstravam a inviabilidade econômica dos Campos. Neste particular, forçoso reconhecer que os problemas detectados na exploração dos Campos tinham potencial de impactar o fluxo de caixa e os resultados da OGX, que, caso confirmasse aquele contexto, poderia vir a enfrentar problemas significativos em seus negócios, como posteriormente restou materializado. Deste modo, o insucesso daquela empreitada tinha reflexos na própria continuidade da Companhia, a demonstrar que não se tratava de mera questão operacional restrita aos técnicos da Companhia, como alega Eike Batista. Como já extensamente abordado ao longo deste voto, ao final de março de 2013 a Companhia já detinha a informação de que não seria viável economicamente a exploração dos Campos, respaldada por farta documentação, cuja consequência afetava a continuidade dos negócios da OGX e, por isso, de ciência obrigatória da alta administração da Companhia*” (§§125-127, grifou-se).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

o Diretor Relator que uma atuação diligente exigiria uma conduta muito mais proativa do acusado, de modo que este deveria, no mínimo, ter verificado junto à Diretoria “*quais as providências que estavam sendo tomadas para tratar a questão, tanto interna corporis como externamente*” (§138), inclusive “*a correta e adequada divulgação das demonstrações financeiras de modo a refletir a real situação patrimonial e financeira da Companhia, de acordo com a lei e a regulamentação aplicável*” (§139).

65. A leitura que faço dos fatos é diferente. É indiscutível que a responsabilização de membros do Conselho de Administração por irregularidades verificadas na elaboração das demonstrações financeiras da Companhia deve ser analisada sob a ótica fiscalizatória³⁵. Com efeito, feitas as necessárias adaptações, entendo cabível aqui o mesmo raciocínio utilizado anteriormente para a análise da situação de Luiz Carneiro.

66. Em primeiro lugar, não me parece razoável presumir que sua posição de acionista controlador e Presidente do Conselho de Administração automaticamente lhe atribuiria “super-deveres” de vigilância neste particular e, mais que isso, a ciência de exigências normativas técnico-contábeis. Como visto, a mera ciência sobre os Fatos não impõe, necessariamente, cuidados adicionais na fiscalização da feitura do Formulário 1º ITR/2013 da Companhia, como investigações sobre como e quando os Fatos seriam refletidos em tal documento contábil³⁶.

67. Além disso, não identifiquei nos autos apontamento de falhas específicas por parte de Eike Batista no que toca à supervisão da elaboração do Formulário 1º ITR/2013 ou sinais de alerta aptos a elevar o padrão de conduta esperado de Eike Batista em seu dever de fiscalizar a elaboração das demonstrações financeiras da OGX e, assim, justificar eventual inquirição do Diretor Financeiro ou do auditor independente ou investigações quanto à (técnica) decisão sobre a necessidade ou o modo de inclusão das Incertezas.

³⁵ Nesse sentido: “[d]iferentemente dos diretores, os membros do conselho de administração não são direta e primariamente responsáveis pela correta elaboração das demonstrações contábeis da companhia. Desta feita, a constatação da infração contábil, por si só, não enseja a responsabilidade do conselheiro. A questão deve ser examinada sob a perspectiva do dever de fiscalização da gestão dos diretores, que recai sobre os membros do conselho de administração, nos termos do artigo 142, incisos III e V, da Lei nº 6.404/1976, bem como sob a perspectiva do dever de diligência dos membros do conselho de administração, nos termos do artigo 153 da Lei nº 6.404/1976. Especificamente em relação às demonstrações financeiras, o conselheiro pode, a princípio, confiar nas informações recebidas dos diretores, de modo que os deveres de fiscalização e diligência se impõem quando há sinais de alerta a respeito da provável ocorrência de infrações contábeis.” (PAS RJ2015/6229, j. em 20.03.2018, Relator Diretor Gustavo Gonzalez). No mesmo sentido: PAS CVM nº RJ2014/12056, j. em 12.12.2017 e PAS RJ2015/2651, j. em 26.05.2017.

³⁶ Lembremos aqui que não se está discutindo eventual fiscalização do Presidente do Conselho quanto à elucidação dos Fatos ao mercado com base em seu dever de informar, questão por mim analisada no âmbito do PAS CVM nº RJ2014/6517.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

68. Como se viu, era do Diretor Financeiro da Companhia a responsabilidade primária pela condução dos trabalhos tendentes à elaboração das demonstrações financeiras, devendo-se a ele imputar a responsabilidade pela irregularidade contábil verificada e os resultantes danos. Atribuir tal responsabilidade, na mesma medida, ao Presidente do Conselho de Administração, me parece excessivo.

69. Aqui vale a ressalva de que não se está de forma alguma defendendo a ausência de responsabilidade de Eike Batista no que toca ao uso indevido de informações relacionadas aos Fatos ou mesmo à derrocada da OGX como um todo. Como se sabe, tais questões foram apuradas em outros processos, tanto na CVM quanto em outras esferas, havendo inclusive resultado na condenação de Eike Batista pelo Colegiado em 27.05.2019. Mas o presente processo não trata dessas questões.

70. Seguindo em minha análise, tampouco vislumbro que a não observância de disposições contidas em Pronunciamentos Técnicos pode ser considerada como evidência suficiente de flagrante irregularidade na gestão da Companhia — traduzidas na não inclusão dos Fatos nas notas explicativas —, perceptível pelo Presidente do Conselho³⁷ com base em um exame perfunctório.

71. No mais, vale mencionar que o Colegiado³⁸ já se manifestou em mais de uma ocasião pela importância da instalação de mecanismos de monitoramento, como comitês de auditoria ou

³⁷ A título de exemplo, situação diversa ocorreu no PAS 07/2014, j. em 26.03.2019, em que membro do Conselho de Administração foi condenado por falta de diligência no processo de fixação da remuneração da administração. Conforme apontado pelo Diretor Relator Gustavo Gonzalez, nesse caso havia um erro flagrante: *“a discrepância entre o valor aprovado e o efetivamente praticado era enorme e deixa a impressão de que a administração sequer analisou os documentos que aprovou e submeteu à assembleia geral. Esse mesmo motivo me leva a rechaçar de plano a possibilidade de afastar a responsabilidade da conselheira sob o argumento de que essa se fiou em documentos preparados por terceiros. Não se está aqui dizendo que os membros do conselho de administração precisam preparar pessoalmente os documentos, nem que não possam se fiar no trabalho preparado por terceiros, fato já consagrado na nossa jurisprudência administrativa. Todavia, a defesa somente é disponível quando o administrador analisou os documentos e não encontrou sinais de alerta. No caso em tela, o erro era flagrante e a simples leitura do documento indicaria que havia algo errado. Afinal de contas, nenhum administrador recebia mensalmente apenas um salário mínimo”*. Na mesma linha, no âmbito do PAS RJ2016/7389, j. em 2018, o ex-Diretor Pablo Renteria concluiu pela responsabilidade dos membros do conselho de administração, posto que comprovado que eles *“não fiscalizavam minimamente a gestão da diretoria da Ferrifera, uma vez que se mantiveram omissos ante as graves e flagrantes irregularidades cometidas pelos diretores”* quanto o preenchimento dos livros sociais obrigatórios da companhia administrada e sua escrituração contábil.

³⁸ Merecem transcrição trechos do voto do Diretor Otavio Yazbek, proferido nos autos do PAS CVM nº 18/08, julgado em 14.12.2010: *“[S]e os conselheiros não podem fiscalizar diretamente, se muitas vezes lhes falta habilidade técnica, que se criem mecanismos que lhes permitam, de maneira mediada, apreender essa realidade e deliberar, ao cabo, de maneira informada. É aí que entram comitês consultivos e uma série de outros mecanismos, regras e procedimentos, usualmente caracterizados sob a rubrica “controles internos”. (...) Não é razoável que se presuma que conselheiros que não raro nem tem expertise financeira sequer reconheçam, em alguns casos, red flags que, para especialistas, seriam evidentes. Mas esses conselheiros devem, por outro lado, preocupar-se com a adequação dos controles internos, com a capacidade que estes têm de impedir determinadas situações ou de gerar sinais de alerta. Vale dizer, diligência é, também, zelar pela estruturação dos controles internos, daqueles mecanismos com que se lidará com a*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

sistemas de controle interno efetivos e eficientes, os quais podem, inclusive, funcionar como meios de prova de que agiram de acordo com o padrão de diligência esperado³⁹. Todavia, esse aspecto não foi explorado pela acusação, não cabendo, por conseguinte, explorá-lo em sede de julgamento.

72. Em síntese, não logrei identificar, na narrativa da acusação, elementos que permitissem o enquadramento da conduta de Eike Batista como falta de diligência em relação ao seu dever de fiscalizar a atuação do Diretor Financeiro sobre a elaboração do Formulário 1º ITR/2013.

Os limites da exceção legal prevista no art. 157, parágrafo 5º, da Lei das S.A.

73. Conforme observado, este processo trata de determinados Fatos que foram não apenas analisados sob a ótica da diligência na elaboração das demonstrações financeiras de uma companhia aberta (e em sua consequente divulgação por meio de tais documentos), mas também sob o aspecto da divulgação de tais informações econômico-financeiras por meio de fatos

complexidade do ambiente em que a companhia atua. E isso, a bem da verdade, não é invencionice: trata-se tão somente de leitura dos deveres de 'bem administrar' e de 'vigiar', que sempre estiveram no núcleo do mais amplo dever de diligência. (...) [A] mera criação de comitês consultivos, em si, não exime os administradores de sua responsabilidade. Mas os casos devem ser julgados tendo em vista as condições concretas e acredito que a constituição de mecanismos adequados de controle pode, quando devidamente comprovada, demonstrar que as obrigações cabíveis foram cumpridas e até mesmo afastar a responsabilização dos conselheiros. Tudo depende do que se apurar no caso concreto, das condições materiais, das condutas identificadas." Na mesma linha: "A diligência é um dos mais recorrentes argumentos de defesa nos processos instaurados pela CVM. A tese é geralmente construída a partir de citações doutrinárias e precedentes. Muito mais raros são os casos em que os acusados trazem elementos que comprovam sua diligência, muito embora essa se manifeste, sobretudo, a partir da adoção de procedimentos razoáveis e adequados. (...) Nesse contexto, parece-me evidente que um diretor com relações com investidores pode, em certas situações, se eximir de responsabilidade administrativa por não ter divulgado fato relevante quando a notícia fugiu do controle mediante demonstração de que a companhia possuía controles razoáveis para monitorar o mercado que, todavia, não identificaram um pequeno vazamento. A decisão final, naturalmente, dependerá das circunstâncias específicas do caso concreto." (PAS CVM nº RJ2014/3402, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, j. em 13.12.2018). Também para ilustrar esse ângulo do dever de diligência, vejamos a seguinte passagem de voto proferido pelo então Diretor Otavio Yazbek: "[s]e não por outro motivo porque, ao proceder dessa maneira, ignora-se que o dever de diligência não se resume ao dever de tomar decisões negociais diligentes, envolvendo, também, toda uma dimensão voltada à supervisão das atividades da companhia, à qual não se aplicam os mesmos parâmetros (i.e., se se trata de decisões tomadas de maneira informada, refletida e desinteressada). (...) Em casos como esse, mais do que uma ênfase no procedimento, a apuração da conduta dos administradores, ao que me parece, deve passar pela análise concreta da forma pela qual se 'procedimentalizaram' as atividades dentro da sociedade. Há que se avaliar se os procedimentos criam uma razoável segurança para as atividades da companhia e, para que isto aconteça, é necessário verificar se a 'procedimentalização' dos controles internos é razoável e adequada" (PAS CVM nº 24/2006, j. em 18.02.2013).

³⁹ Aqui cabe notar que a ausência de tais mecanismos não denota, por si, uma infração a seus deveres fiduciários.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

relevantes. Nesse contexto, acusação⁴⁰, defesas⁴¹ e Diretor Relator⁴² terminaram por relacionar conceitos de relevância a meu ver distintos, valendo, assim, algumas considerações teóricas a respeito, que em nada mudam as conclusões desta manifestação quanto às imputações feitas a Luiz Carneiro e Eike Batista.

74. Ao regular o dever de informar previsto no art. 157, §4º da Lei das S.A., o art. 2º da Instrução CVM nº 358/02 dispõe que se considera relevante, para os fins de tal Instrução (*i.e.*, de divulgação ao mercado de comunicado de fato relevante), qualquer ato ou fato de caráter econômico-financeiro ocorrido ou relacionado aos seus negócios que possa influir de modo

⁴⁰ Segundo a acusação, ao menos a partir da apresentação do GT em 24.09.12, os administradores da Companhia “dispunham de uma informação relevante, nos termos do art. 2º da I-CVM no. 358/02”, mas que, não obstante a previsão nas “normas que tratam de divulgação de informações relevantes” da licitude de se deixar de divulgar informação relevante caso se entenda que sua revelação porá em risco interesse legítimo da companhia (vide art. 157, § 5º da Lei nº 6.404/76 e no art. 6º da I-CVM nº 358/02), “ao divulgar a informação sobre a matéria, essa divulgação deve atender aos princípios contidos nos artigos 14 e 19 da I-CVM 480/09, notadamente no que diz respeito à necessidade de divulgação de informações verdadeiras, completas, consistentes e que não induzam o investidor a erro” (fls. 804). No que se refere às demonstrações financeiras, a acusação destacou que “as normas contábeis aplicáveis estabelecem que qualquer informação considerada relevante para a avaliação da posição patrimonial e financeira, do desempenho e das mutações na posição financeira da entidade deve ser divulgada” (fls. 804) e que “no momento de divulgação das demonstrações financeiras, as informações relevantes, que sejam do conhecimento da administração que possam ser identificadas como risco significativo de provocar ajuste material nos valores contábeis de ativos e passivos ao longo do exercício social seguinte, devem necessariamente ser contempladas nas notas explicativas.” Dessa forma, concluiu a acusação que: “[n]ão caberia, quando da divulgação dessas demonstrações financeiras, a alegação da necessidade de sigilo até que confirmasse com absoluta certeza a total inviabilidade dos campos. Admitir essa alegação corresponderia a admitir a divulgação de demonstrações financeiras com informações sabidamente incompletas, com o potencial de induzir o investidor a erro e expressamente contrárias às normas contábeis mencionadas” (fls. 806).

⁴¹ Segundo os diretores acusados, o termo de acusação pareceria sustentar “que a legislação societária apresenta 2 (dois) tratamentos diferentes no que se refere ao dever dos administradores de divulgar informações relevantes: o primeiro, sobre a publicação de fatos relevantes propriamente ditos, e, o segundo, sobre a elaboração das demonstrações financeiras. Com relação à publicação de fatos relevantes, caso a divulgação coloque em risco interesses legítimos da companhia, existe uma exceção para o dever de pronta divulgação; porém, no que tange à elaboração das demonstrações financeiras, não vigora igual tolerância: o administrador é obrigado a refletir a informação relevante neste documento imediatamente”. Com efeito, sustentou-se que “se existe o direito de não divulgar uma informação por força do artigo 157, § 4º, da Lei das S.A., surge como corolário o direito de não refletir essa informação nas demonstrações financeiras” (fls. 968-970). Em outras palavras, “às obrigações relativas às notas explicativas de demonstrações contábeis de companhias abertas, constantes de pronunciamentos aprovados por meio de Deliberações da CVM, aplica-se o disposto no artigo 157, § 5º (sic), da Lei das S.A. e no artigo 6º da Instrução CVM nº 358/2002, especialmente no que diz respeito à proteção de informações relevantes que, se divulgadas, podem por (sic) em risco interesses legítimos da companhia” (fls. 984).

⁴² Especificamente quanto ao argumento de que haveria legítimo interesse em não divulgar as Incertezas, o Diretor Relator entendeu que “a informação relevante não divulgada referia-se, em um primeiro momento, a uma grande mudança nas estimativas de volume recuperável inicialmente divulgadas e, um pouco mais adiante, à inviabilidade dos Campos detidos pela Companhia. Portanto, não se trata de informação de cunho concorrencial ou cuja revelação poderia atrapalhar interesses da Companhia em concluir um negócio específico ou o desenvolvimento de um produto. Pelo contrário, tratava-se, como já ressaltado anteriormente neste voto, de informação de suma importância para a Companhia e para a continuidade de suas atividades, não sendo legítima a retenção da informação por receio dos efeitos no preço do papel, até porque, na grande maioria dos casos, a divulgação de um fato relevante tem esse poder, uma vez que tem potencial para afetar a decisão de compra ou venda dos valores mobiliários de emissão daquela companhia” (§§85-86). Nesse sentido, complementou: “[e]m casos que tais, no momento da divulgação das demonstrações financeiras, as informações relevantes que forem do conhecimento da administração e que puderem ser identificadas como de risco significativo de provocar ajuste material imediato nos valores contábeis de ativos da Companhia, devem necessariamente ser contempladas nas notas explicativas, não se aplicando a hipótese de sigilo que faculta, em tese, aos administradores deixar de divulgar a informação caso entendam que sua revelação porá em risco interesse legítimo da companhia” (§90).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

ponderável: “(i) na cotação dos valores mobiliários de emissão da companhia aberta ou a eles referenciados; (ii) na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter aqueles valores mobiliários; ou (iii) na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titular de valores mobiliários emitidos pela companhia ou a eles referenciados”.

75. Diversamente, os normativos contábeis vigentes – dentre os quais se encontram aqueles que embasaram a acusação sob exame – contêm uma série de critérios específicos para fins de aferição da necessidade de incluir novas informações econômico-financeiras nas demonstrações financeiras ou de se alterar informações presentes em documentos pretéritos, as quais o regulador entende relevantes para que os usuários das demonstrações financeiras consigam avaliar a situação econômico-financeira de uma companhia aberta adequadamente.

76. Portanto, de fato estamos diante de duas análises de relevância apartadas, com embasamento normativo, responsáveis, propósitos e destinatários distintos. Com efeito, apesar de ser possível que a inclusão de determinada informação nas demonstrações financeiras de uma companhia também se enquadre na definição de fato relevante da Instrução CVM nº 358/02 e, assim, enseje a divulgação de uma comunicação específica a respeito, simultaneamente à publicação das demonstrações financeiras, não há uma correlação necessária entre elas.

77. Mas há também a hipótese do caso em tela: determinada informação econômico-financeira satisfaz os dois critérios de relevância tratados acima, porém, com base na faculdade prevista no art. 157, §5º da Lei das S.A. e no art. 6º da Instrução CVM nº 358/02, a administração da sociedade decide não divulgá-la ao mercado imediatamente.

78. Defendem os acusados que, nessa situação, a divulgação da informação relevante por meio das demonstrações financeiras tornaria inócua tal disposição normativa. Por outro lado, apesar de utilizarem embasamentos distintos, acusação e relator concluíram pela inaplicabilidade de tal faculdade no caso concreto. Na minha opinião, tanto os argumentos utilizados pela acusação quanto aqueles da defesa têm mérito, sendo possível e necessária sua compatibilização. Afinal, é certo que a interpretação sistemática da Lei das S.A. e da regulamentação da CVM deve ser feita de forma a alcançar um resultado de harmonia entre seus dispositivos.

79. Não obstante o art. 6º, parágrafo único da Instrução CVM nº 358/02 prever apenas duas hipóteses em que cessa a possibilidade de não revelação de fato relevante (oscilação atípica e a informação escapar do controle), tal exceção sempre estará suscetível à existência de um terceiro elemento limitador: outras obrigações legais e regulamentares que, por sua natureza, não



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

permitem que a administração da sociedade discricionariamente postergue seu cumprimento ou as realize de forma parcial.

80. Afinal, não há, nesses casos, margem de discricionariedade para decidir quanto ao cumprimento de tais obrigações. A Lei existe e deve ser cumprida, não podendo o administrador alegar que uma decisão informada e refletida tomada com base em permissivo legal genérico o levou a concluir pela violação de comando específico que estava obrigado a cumprir.

81. Este é o caso da obrigação de fazer elaborar e publicar as demonstrações financeiras anuais e intermediárias da companhia, em até 3 meses⁴³ depois do fim do período sobre o qual se refere. E, publicando-se tais documentos⁴⁴, recai sobre a administração o dever de garantir que a companhia divulgue *“informações verdadeiras, completas, consistentes e que não induzam o investidor a erro”*, nos termos do art. 14 da Instrução CVM nº 480/09. Sobre este caso específico, vale lembrar que a demonstração financeira é, provavelmente, a informação periódica mais relevante que uma companhia aberta disponibiliza ao público⁴⁵.

82. Com efeito, no caso em tela, entendo que a exceção à imediata divulgação encontra um limite temporal objetivo, de modo que a divulgação de *“informações econômico-financeiras relevantes”* relativas aos Fatos se tornou inadiável diante das obrigações previstas nos arts. 176 e 177 da Lei das S.A., bem como nos arts. 14 e 29 da Instrução CVM nº 480/09, deixando de ser juridicamente aceitável.

Conclusão

⁴³ Art. 25 da Instrução CVM nº 480/09: *“O emissor deve entregar as demonstrações financeiras à CVM na data em que forem colocadas à disposição do público. (...) § 2º A data a que se refere o caput não deve ultrapassar, no caso de emissores nacionais, 3 (três) meses, ou, no caso de emissores estrangeiros, 4 (quatro) meses do encerramento do exercício social.”*

⁴⁴ Veja-se aqui que o mesmo raciocínio pode ser aplicado no que toca à divulgação de fatos relevantes.

⁴⁵ Quanto à importância da inclusão de informações adequadas e suficientes nas demonstrações financeiras, veja-se o que dispõe Alexandre Broedel Lopes a respeito do tratamento contábil trazido com a Lei alteradora nº 11.638/2007: *“A nova contabilidade altera o ambiente informacional do mercado de capitais, na medida em que as demonstrações financeiras, especialmente as notas explicativas, passam a conter um volume mais completo de informações sobre o desempenho das companhias. As IFRS são direcionadas especificamente para investidores atuantes dentro de mercados ativos, de forma que a evidência ganha peso em relação à mensuração. (...) Descrições detalhadas de operações com instrumentos financeiros, transações com partes relacionadas, impairment de ativos, somente para citar alguns exemplos, passam a fazer parte das demonstrações financeiras. Temos, então, um aumento importante do volume de informações obrigatórias que a companhia deve levar ao mercado. Tais informações têm como objetivo propiciar que os usuários possam extrapolar a situação presente da companhia e projetar fluxos futuros de caixa oriundos de suas operações.”* LOPES, Alexandre. O Novo Regime Jurídico das Demonstrações Financeiras In: KUYVEN, Luiz Fernando Martins (Coord.). *Temas essenciais de direito empresarial – Estudos em homenagem a Modesto Carvalhosa*. São Paulo: Saraiva, 2012, pp. 444-445.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

83. Embora reconheça que a atuação de Luiz Carneiro e de Eike Batista não atendeu ao que deles se poderia esperar, com base na lei societária, do ponto de vista informacional⁴⁶, não vejo como responsabilizá-los pelo descumprimento do art. 153 da Lei nº 6.404/76 no que toca ao acompanhamento da elaboração das Informações Financeiras da OGX, pilar da acusação contra ambos.

84. Sendo assim, pelas razões expostas ao longo desta manifestação, voto: (i) pela absolvição de Luiz Carneiro da acusação de infração aos arts. 153 e 176 c/c 177, § 3º, da Lei nº 6.404/76 e dos arts. 14, 26 e 29 da Instrução CVM nº 480/09; e (ii) pela absolvição de Eike Batista da acusação de infração aos arts. 142, III, e 153 da Lei nº 6.404/76.

85. Por fim, ressalto que, com relação aos demais acusados deste processo, acompanho as conclusões do voto do Diretor Relator.

É como voto.

Rio de Janeiro, 25 de junho de 2019.

Marcelo Barbosa

Presidente

⁴⁶ Vide manifestação de voto que apresentei no âmbito do PAS CVM nº RJ2014/6517, ressaltando-se que não caberia, neste momento, depois de iniciado o julgamento, propor nova definição jurídica aos fatos objeto deste processo, nos termos do art. 25 da Deliberação CVM nº 538/08 e, tampouco, alterar a tese acusatória, o que seria inoportuno e contrário ao regime que rege a tramitação dos processos sancionadores no âmbito desta autarquia.